

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1

BÀI GIẢNG
LUẬT KINH DOANH

BIÊN SOẠN: TS. LÊ MINH TOÀN

Hà Nội - 2015

LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh gần hơn với pháp luật của các nền kinh tế phát triển, đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập càng trở nên cấp thiết. Trong nhiều năm qua, để góp phần đẩy mạnh quá trình đổi mới và hội nhập, Chính phủ đã tích cực ban hành các văn bản quy phạm pháp luật kinh doanh phù hợp với các yêu cầu và cam kết với WTO như: Luật Chứng khoán năm 2006, Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Luật Phá sản doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 ..v.v. Đây là các căn cứ pháp lý hết sức quan trọng trong việc xây dựng và hình thành hệ thống pháp luật kinh doanh minh bạch, hiệu quả, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Để góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Luật kinh doanh cho sinh viên, học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính- Kế toán, Marketing ở các bậc, hệ đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Khoa Quản trị kinh doanh 1 tổ chức biên soạn Bài giảng Luật kinh doanh với những cập nhật mới nhất về khung pháp luật hiện hành. Nội dung bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về môi trường pháp luật kinh doanh Việt Nam cho sinh viên nhằm giúp cho sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất khi làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan quản lý hay làm chủ doanh nghiệp. Nội dung bài giảng bao gồm: *Pháp luật về Doanh nghiệp, Pháp luật về Đầu tư, Pháp luật về Hợp đồng, Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, Pháp luật về phá sản.*

Hà Nội, 12 - 2015

Ts. Lê Minh Toàn

MỤC LỤC

	TRANG
LỜI NÓI ĐẦU	2
MỤC LỤC	3
Chương 1: PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP	4
1.1. TỔNG QUAN VỀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP	4
1.2. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP	13
1.3. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN	24
1.4. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC	46
1.5. CÔNG TY CỔ PHẦN	58
1.6. CÔNG TY HỢP DANH	96
1.7. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN	102
1.8. NHÓM CÔNG TY	103
1.9. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP	105
Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ	117
2.1. TỔNG QUAN VỀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM	117
2.2. BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ	123
2.3. ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ	125
2.4. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM	128
2.5. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI	142
Chương 3: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG	150
3.1. SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA KHUNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG	150
3.2. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG	151
3.3. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG	156
3.4. SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG	159
3.5. MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG	161
Chương 4: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH	184
4.1. KHÁI QUÁT CHUNG	184
4.2. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI	190
4.3. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN	202
Chương 5: PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN	229
5.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁ SẢN VÀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN	229
5.2. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁ SẢN	233
5.3. ĐƠN VÀ THỦ LÝ ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN	238
5.4. MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN	244
5.5. NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN	247
5.6. CÁC BIỆN PHÁP BẢO TOÀN TÀI SẢN	249
5.7. HỘI NGHỊ CHỦ NỢ	253
5.8. THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	257
5.9. TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN	261
TÀI LIỆU THAM KHẢO	265

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia, 2013.
2. Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, 2015.
3. Luật phá sản doanh nghiệp 2014, Nxb. Chính trị quốc gia, 2014.
4. Luật Đầu tư năm 2014, Nxb. Chính trị quốc gia, 2014.
5. Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nxb. Chính trị quốc gia, 2014.
6. Luật Chứng khoán năm 2006 (sửa đổi, bổ sung 2010), Nxb. Chính trị quốc gia, 2010.
7. TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên), *Luật Kinh doanh Việt Nam* (Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng), 2 tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 2009.
8. Ts. Lê Minh Toàn; Ts. Vũ Quang, *Luật kinh doanh (Dùng cho đào tạo ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng)*, Nxb. Chính trị quốc gia, 2012.
9. Lê Minh Toàn (Chủ biên), *Luật Kinh tế Việt Nam* (Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng), Nxb. Chính trị quốc gia, 2002.
10. TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên), *Pháp luật đại cương* (Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng), Tái bản lần thứ 14, Nxb. Chính trị quốc gia, 2015 (cập nhật hàng năm).
11. Các Giáo trình: Luật Kinh tế (Khoa Luật – ĐHQG HÀ NỘI); Luật Kinh tế (Trường Đại học Luật Hà Nội) xuất bản.
12. Tạp chí: *Nghiên cứu kinh tế, Chứng khoán, Nhà nước và pháp luật, Tài chính, Ngân hàng, Luật học, Kinh tế và dự báo, Chứng khoán Việt Nam, Tài chính, Tạp chí Cộng sản, Dân chủ và pháp luật, Toà án nhân dân...*
11. Các báo: *Thời báo kinh tế Việt Nam, Báo Đầu tư, Đầu tư - chứng khoán, Thời báo kinh tế Sài Gòn, VietnamNet, Nhân dân, Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ...*
13. Website: Chính phủ www.chinhphu.vn; Quốc hội www.qh.gov.vn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư www.mpi.gov.vn; Bộ Tài chính www.mof.gov.vn; Bộ Công thương www.moit.gov.vn; Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước www.ssc.gov.vn; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh www.hsx.vn; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội www.hnx.vn ; Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam www.viac.org.vn; Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI) www.vcci.com.vn; Tòa án nhân dân tối cao www.toaan.gov.vn; Viện kiểm sát nhân dân tối cao www.vksndtc.gov.vn; .

CHƯƠNG 1: PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

1.1. TỔNG QUAN VỀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

Ở Việt Nam, các loại hình doanh nghiệp đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài, đầy biến động. Quá trình lịch sử phát triển các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam được chia thành ba giai đoạn: thời kỳ trước năm 1987, thời kỳ từ năm 1987 đến 30/6/2006; thời kỳ từ 1/7/2006 đến nay.

Thời kỳ trước năm 1987: Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám và chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Chính phủ đã ban hành sắc lệnh xoá bỏ mọi sự hạn chế của chế độ thực dân Pháp đối với các thủ tục đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, Chính phủ cũng đồng ý để các công ty ngoại quốc được tiếp tục tiến hành các hoạt động kinh doanh như trước. Nước Việt Nam độc lập xuất hiện loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thời kỳ này, các chủ doanh nghiệp cũng đóng góp nhiều công sức và tài sản cho cuộc kháng chiến. Điểm khác biệt lớn nhất trong thời kỳ này là các loại hình doanh nghiệp từ chỗ chịu sự điều chỉnh của luật nước Pháp sang chịu sự điều chỉnh của luật nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Sau năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền hoàn toàn khác nhau về chính trị, kinh tế và do vậy việc hình thành những loại hình doanh nghiệp ở hai miền cũng hoàn toàn khác nhau... Từ năm 1979 đến năm 1986, trên lãnh thổ nước Việt Nam thống nhất chỉ có các doanh nghiệp quốc doanh và các cơ sở sản xuất sở hữu tập thể và các hợp tác xã. Tính đến năm 1986, ở Việt Nam có khoảng 10.000 doanh nghiệp quốc doanh, một con số rất nhỏ so với dân số 65 triệu người.

Thời kỳ từ năm 1987 đến 30/6/2006: Từ Đại hội VI, Đảng ta đã khẳng định sự tồn tại của các thành phần kinh tế cá thể và tư doanh trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân bên cạnh kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác. Các hoạt động kinh tế của các thành phần kinh tế này thực hiện dưới ba hình thức: (i) hộ cá thể, (ii) hộ tiểu công nghiệp và (iii) xí nghiệp tư doanh. Tuy nhiên, các quy định về hình thức kinh doanh này không rõ ràng, cụ thể, và rất chung chung. Luật pháp không xác định rõ chế độ trách nhiệm, tổ chức quản lý, và bị hạn chế rất nhiều trong hoạt động kinh doanh.

Ngày 21/12/1990, Quốc hội khoá VIII của nước ta đã thông qua hai đạo luật quan trọng là Luật Công ty 1990 và Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990. Hai đạo luật đã tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta, là một mốc quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong quá trình đổi mới kinh tế, chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty được ban hành đã quy định ba loại hình doanh nghiệp cho khu vực kinh tế tư nhân là: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân.¹

¹ Trong hơn 10 năm (tính đến trước khi ban hành Luật Doanh nghiệp năm 1999), khung khổ pháp lý nói chung và khung khổ pháp lý về doanh nghiệp nói riêng đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Sản phẩm doanh nghiệp và các luật khác về doanh nghiệp như: Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, v.v. đã được ban hành. Luật Đầu tư nước ngoài cũng được sửa đổi, bổ sung theo hướng thu hẹp sự khác biệt, tiến tới tiến trình hình thành một khung khổ pháp lý bình đẳng đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia ASEAN (AFTA, chương trình AIA, AICO), APEC, ký kết hiệp định thương mại với Hoa Kỳ và đang cam kết để gia nhập WTO...

Sự phát triển của nền kinh tế làm cho những quy định trong Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân ban hành trước đây không còn thích hợp với nội dung tương ứng của một số luật khác có liên quan, đặc biệt là Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Thương mại... Điều đó đòi hỏi một sự sửa đổi về hai đạo luật này và đi tới một đạo luật chung thống nhất điều chỉnh các loại hình công ty và doanh nghiệp tư nhân theo hướng mở rộng thêm các loại hình doanh nghiệp khác, đơn giản hoá thủ tục đăng ký kinh doanh, v.v.. Điều này sẽ tăng cường tính linh hoạt cho các nhà đầu

Ngày 12/6/1999, Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Doanh nghiệp 1999. Theo số liệu thống kê của Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm 2000 (từ sau khi Luật Doanh nghiệp 1999 có hiệu lực thi hành) cho đến hết năm 2005, đã có 160.752 doanh nghiệp được thành lập, gấp 3,3 lần số doanh nghiệp được thành lập giai đoạn 1991 - 1999. Số vốn đăng ký mới đạt 321,2 nghìn tỷ đồng (khoảng 20 tỷ USD), chưa kể số vốn đăng ký bổ sung trong quá trình hoạt động khoảng 103,4 nghìn tỷ đồng (khoảng 6,3 tỷ USD). Ngoài ra còn có hàng chục nghìn chi nhánh, văn phòng đại diện và hơn 2 triệu hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Số doanh nghiệp mới này cũng tạo thêm gần 2 triệu việc làm mới, nâng tổng số lao động khu vực này lên khoảng 6 triệu lao động (chiếm 17% lực lượng lao động).²

Thời kỳ từ 1/7/2006 đến nay:

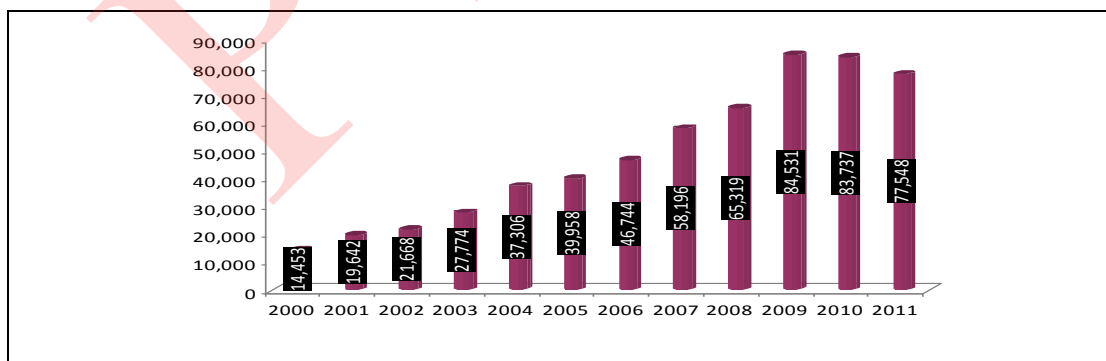
Kế thừa những thành tựu của Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006) đã tạo ra bước đột phá mới với các quy định mới như:

- Quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

- Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp.³

Số liệu thống kê cho thấy số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hàng năm tiếp tục tăng nhanh năm sau cao hơn năm trước kể từ khi Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành. Năm 2009, số lượng doanh nghiệp đạt mức kỷ lục 84.531 doanh nghiệp, gấp 2,1 lần so với năm 2006 và gấp 5,8 lần so với năm 2000. Tuy nhiên, từ năm 2010 do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế số lượng doanh nghiệp thành lập lần đầu tiên có xu hướng giảm xuống hơn với 83.000 doanh nghiệp năm 2010 và 77.548 doanh nghiệp năm 2011 (Hình 1.1).

Hình 1.1: Số liệu doanh nghiệp thành lập giai đoạn 2000-2011



Nguồn: Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT

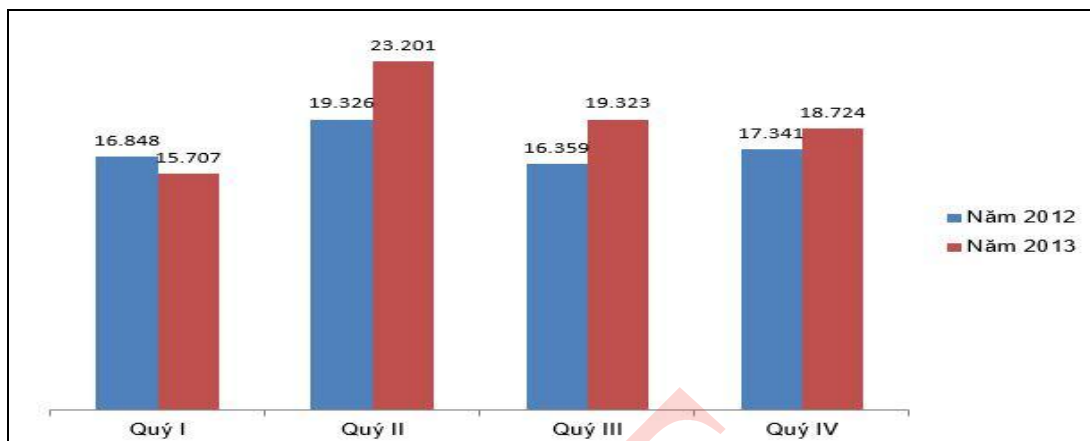
tư trong việc lựa chọn hình thức và cơ hội đầu tư phù hợp nhất với khả năng của họ và tăng cường vai trò quản lý nhà nước, giám sát bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

² Xem thêm: Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, "6 năm thi hành Luật Doanh nghiệp: Những vấn đề nổi bật và bài học kinh nghiệm", Hà Nội, 2-2006, tr. 8-11.

³ Luật này thay thế Luật Doanh nghiệp năm 1999; Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2000). Xem thêm bình luận về Luật doanh nghiệp 2005 tại: Lê Minh Toàn (chủ biên), *Luật Kinh doanh Việt Nam* (2 tập), Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, 2009.

Trong năm 2013, cả nước có 76.955 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 398.681 tỷ đồng, tăng 10,1% về số doanh nghiệp và giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2012 (Hình 1.2).⁴

Hình 1.2: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo Quý năm 2012-2013



Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT

Trong năm 2014, cả nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 432.286 tỷ đồng, giảm 2,7% về số doanh nghiệp và tăng 8,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2014 đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo công việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2014 là 1.091 nghìn lao động, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2014, có 22.758 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 595.707 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2014 là 1.027.993 tỷ đồng.⁵

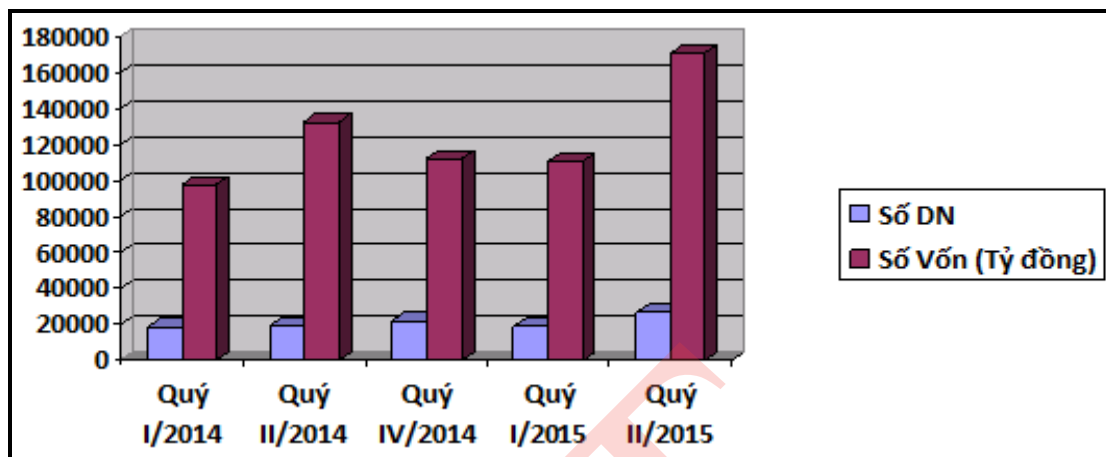
Trong 6 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 45.406 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 282.396 tỷ đồng, tăng 21,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2015, có 10.988 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 308.809 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6

⁴ Về số doanh nghiệp dừng hoạt động trong năm 2013, cả nước có 60.737 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động (trong đó, số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể là 9.818 doanh nghiệp, số doanh nghiệp gặp khó khăn và rơi vào trạng thái tạm ngừng hoạt động là 50.919 doanh nghiệp) tăng 11,9 % so với cùng kỳ năm trước. Về số doanh nghiệp gặp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong năm 2013 là 14.402 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động tăng dần theo các tháng. Về số doanh nghiệp giải thể và gặp khó khăn phải ngừng hoạt động trong năm 2013 vẫn tăng so với năm 2012, tuy nhiên qua theo dõi số liệu các tháng trong năm 2013, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động đã có chiều hướng giảm dần đi qua từng tháng. Đây là dấu hiệu tích cực và là cơ sở cho việc phục hồi phát triển nền kinh tế trong thời gian tới. Nguồn: Bộ KH&ĐT www.mpi.gov.vn

⁵ Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm 2014 của cả nước là 9.501 doanh nghiệp, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 58.322 doanh nghiệp, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 11.723 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 46.599 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong năm 2014, cả nước có 15.419 doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là con số đáng khích lệ cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế đã tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Nguồn: Bộ KH&ĐT www.mpi.gov.vn

tháng đầu năm 2015 là 591.205 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2015 là 651.398 lao động, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước (Hình 1.3).⁶

Hình 1.3: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới Quý I, II năm 2015



Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT.

Ngày 28/11/2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua Hiến pháp 2013 với những quy định quan trọng liên quan đến mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và doanh nghiệp; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được đối xử bình đẳng, cùng hoạt động trong một hành lang pháp lý chung và theo cơ chế thị trường, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm; quyền sở hữu tư nhân được pháp luật bảo hộ⁷... Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật doanh nghiệp 2005 là cần thiết nhằm thực thi các quy định của Hiến pháp 2013; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; tạo điều kiện và động lực mới cho sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu khắc phục những hạn chế, bất cập cản trở sự gia nhập thị trường của doanh nghiệp trong thực tiễn. Từ đó, đòi hỏi Luật doanh nghiệp trở thành đạo luật chung về thành lập, tổ chức quản lý và tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp; tạo khuôn khổ chung cho doanh nghiệp hoạt động trên thương trường theo nguyên tắc công khai, minh bạch thông tin, tạo cơ chế tự kiểm soát lẫn nhau, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các đối tác, chủ sở hữu và xã hội.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật doanh nghiệp 2014 thay thế cho Luật doanh nghiệp 2005. Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,

⁶ Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh www.dangkykinhdoanh.gov.vn. Đây là số liệu tính đến thời điểm Luật doanh nghiệp 2005 hết hiệu lực thi hành (30/6/2015).

⁷ Xem thêm các Điều 33, 50, 51 và 52 Hiến pháp năm 2013.

công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.⁸ Về đối tượng áp dụng, Luật doanh nghiệp 2014 áp dụng với các doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT), trong 11 tháng đầu năm 2015, cả nước có 86.853 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 538.671 tỷ đồng, tăng 28,12% về số doanh nghiệp và tăng 37,66% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước (so sánh 2014/2013: doanh nghiệp giảm 4,5%; vốn tăng 8,9%). Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng đầu năm 2015 là 1.280.855 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 538.671 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 742.184 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2015 đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2015 là 1.318,4 nghìn lao động, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước.⁹

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp, kinh doanh

Khái niệm doanh nghiệp: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

1.1.2. Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh.

- Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

- Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của doanh nghiệp; trường hợp trưng mua thì doanh nghiệp được thanh toán, trường hợp trưng dụng thì doanh nghiệp được bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc

⁸ Lưu ý: Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

⁹ Nguồn số liệu: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp.

1.1.3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

1.1.3.1. Quyền của doanh nghiệp

- Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
- Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
- Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
- Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
- Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
- Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
- Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
- Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
- Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật
- Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
- Quyền khác theo quy định của luật có liên quan.

1.1.3.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

- Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
- Khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

- Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

1.1.4. Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

a) Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;

b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; giấy phép và giấy chứng nhận khác;

c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;

d) Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;

đ) Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;

e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;

g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định trên tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

1.1.5. Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

- Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

1.1.6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định trên.

1.1.7. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp.¹⁰ Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

a) Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện;

b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.

Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

b) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

¹⁰ Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

c) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

Về trách nhiệm, Luật doanh nghiệp quy định (Điều 16): Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền. Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

1.1.8. Các hành vi bị nghiêm cấm

Luật doanh nghiệp quy định các hành vi bị cấm bao gồm (Điều 17):

- Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Kê khai không vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

- Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

- Rửa tiền, lừa đảo.

1.2. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1.2.1. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

- a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;¹¹
- b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
- c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
- d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp sau đây:

- a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;¹²
- b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

1.2.2. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp

¹¹ Khoản 4, Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014: Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào một trong các mục đích sau đây:

- a) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 18;
- b) Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
- c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

¹² Xem Khoản 4, Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.

doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

1.2.3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Bảng 1.1. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp¹³

Loại hình doanh nghiệp	Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
Doanh nghiệp tư nhân	1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.
Công ty hợp danh	1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên.¹⁴ 4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên. 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
Công ty trách nhiệm hữu hạn	1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên. 4. Bản sao các giấy tờ sau đây: a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân; b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký

¹³ Xem thêm hướng dẫn chi tiết vấn đề này tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

¹⁴ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (Điều 26 Luật doanh nghiệp 2014):

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần được lập phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên là cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần;
2. Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;
3. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;
4. Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn phần vốn góp của từng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

	doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự; c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
Công ty cổ phần	1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. 4. Bản sao các giấy tờ sau đây: a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự; c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

1.2.4. Điều lệ công ty

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

h) Thẻ thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thẻ thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

1.2.5. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.¹⁵

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật doanh nghiệp;¹⁶

¹⁵ Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

¹⁶ Điều 38. Tên doanh nghiệp

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.¹⁷

ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

2. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Điều 39. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều 40. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

2. Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Điều 42. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e và g của khoản này không áp dụng đối với trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký.

¹⁷ Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều 29 Luật doanh nghiệp):

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:¹⁸

- a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
- b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;
- c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
- d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
- đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

1.2.6. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

- a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;
- b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

1.2.7. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

- a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Vốn điều lệ.

¹⁸ Khoản 1 Điều 211 Luật doanh nghiệp

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội dung sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính:

b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi Thông báo đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo, phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung, sửa đổi thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

1.2.8. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và cung cấp thông tin

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và

phải trả phí theo quy định.¹⁹ Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

- a) Ngành, nghề kinh doanh;
- b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Về cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định.

1.2.9. Tài sản góp vốn; chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn; định giá tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, Luật doanh nghiệp quy định (Điều 36):

(i) Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

- a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

¹⁹ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp <https://dangkykinhdoanh.gov.vn/>

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

(ii) Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

(iii) Thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp và nhận cổ tức của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn của nhà đầu tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản.

Về định giá tài sản góp vốn, Luật doanh nghiệp quy định (Điều 37):

(i) Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

(ii) Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

(iii) Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận. Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

1.2.10. Trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, Luật doanh nghiệp quy định: Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.²⁰

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.²¹

1.2.11. Con dấu của doanh nghiệp

²⁰ Hồ sơ bao gồm:

a) Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

²¹ Xem thêm Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

Luật doanh nghiệp quy định: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

- a) Tên doanh nghiệp;
- b) Mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.²²

1.3. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

1.3.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1.3.1.1. Khái niệm

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

- a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
- b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật doanh nghiệp;
- c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

1.3.1.2. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.²³

²² Xem thêm Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015.

²³ Khoản 2 Điều 48 của Luật doanh nghiệp

Sau thời hạn quy định này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

- a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
- b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
- c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều 48 Luật doanh nghiệp. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.²⁴

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.²⁵ Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

1.3.1.3. Sổ đăng ký thành viên

Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
- c) Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

²⁴ Khoản 4 Điều 48 của Luật doanh nghiệp

²⁵ Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- b) Vốn điều lệ của công ty;
- c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
- d) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;
- đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
- e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

1.3.1.4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

1.3.1.4.1. Quyền của thành viên:

- Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

- Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật doanh nghiệp.

- Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.

- Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

- Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác theo quy định tại Điều 72 của Luật doanh nghiệp.

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 50 Luật doanh nghiệp,²⁶ thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:²⁷

a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;

d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

- Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

²⁶ Khoản 9 Điều 50 Luật doanh nghiệp: “9. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 8 Điều này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này”.

²⁷ Khoản 8 Điều 50 Luật doanh nghiệp.

1.3.1.4.2. Nghĩa vụ của thành viên:

- Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật doanh nghiệp.

- Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật doanh nghiệp.

- Tuân thủ Điều lệ công ty.

- Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

- Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

c) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

- Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

1.3.1.5. Mua lại, chuyển nhượng phần vốn góp; xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

1.3.1.5.1. Mua lại phần vốn góp:²⁸

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Khi có yêu cầu của thành viên quy định trên, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định trên thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.²⁹

²⁸ Điều 52 Luật doanh nghiệp

1.3.1.5.2. Chuyển nhượng phần vốn góp:³⁰

Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật doanh nghiệp, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

1.3.1.5.3. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt:³¹

(i) Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty.

(ii) Trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.

(iii) Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên;

b) Người được tặng cho theo quy định tại khoản (v) này không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên;

c) Thành viên là tổ chức đã giải thể hoặc phá sản.

(iv) Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị tước quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

(v) Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác. Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người

²⁹ Khoản 3 Điều 52 Luật doanh nghiệp

³⁰ Điều 53 Luật doanh nghiệp

³¹ Điều 54 Luật doanh nghiệp

có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

(vi) Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:

- a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
- b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật doanh nghiệp.

1.3.1.6. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

1.3.1.6.1. Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
- b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;
- c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;
- d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
- đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;
- e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;
- h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

- k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- l) Quyết định tổ chức lại công ty;
- m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
- n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty.

1.3.1.6.2. Chủ tịch Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
- c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
- d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
- đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

1.3.1.6.3. Giám đốc, Tổng giám đốc

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.³² Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
- b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
- c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

³² Về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc, xem Điều 66 Luật doanh nghiệp.

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.

1.3.1.6.4. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

(i) Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật doanh nghiệp. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Chủ tịch Hội đồng thành viên chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và triệu tập họp Hội đồng thành viên. Thành viên có quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp bằng văn bản. Kiến nghị phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, chữ ký của thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền;

b) Tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

c) Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp;

d) Lý do kiến nghị.

Chủ tịch Hội đồng thành viên phải chấp thuận kiến nghị và bổ sung chương trình họp Hội đồng thành viên nếu kiến nghị có đủ nội dung theo quy định được gửi đến trụ sở chính của công ty chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng thành viên; trường hợp kiến nghị được trình ngay trước khi họp thì kiến nghị được chấp thuận nếu đa số các thành viên dự họp tán thành.

(ii) Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp.

Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho thành viên công ty trước khi họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày họp. Thời hạn gửi các tài liệu khác do Điều lệ công ty quy định.

(iii) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

(iv) Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định tại khoản (iii) này phải bằng văn bản và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên yêu cầu;

b) Lý do yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên và vấn đề cần giải quyết;

c) Dự kiến chương trình họp;

d) Họ, tên, chữ ký của từng thành viên yêu cầu hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ.

(v) Trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên không có đủ nội dung theo quy định tại khoản (iv) này thì Chủ tịch Hội đồng thành viên phải thông báo bằng văn bản cho thành viên, nhóm thành viên có liên quan biết trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong các trường hợp khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về thiệt hại xảy ra đối với công ty và thành viên có liên quan của công ty. Trường hợp này, thành viên hoặc nhóm thành viên đã yêu cầu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.

1.3.1.6.4. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

(i) Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

(ii) Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản (i) này thì được thực hiện như sau:

a) Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản (ii) này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

(iii) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thắc thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

(iv) Trường hợp cuộc họp đủ điều kiện quy định trên không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến, thì có thể kéo dài phiên họp; thời hạn kéo dài không được quá 30 ngày, kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó.

1.3.1.6.5. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

(i) Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

(ii) Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật doanh nghiệp;

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

(iii) Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

(iv) Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

- b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
- (v) Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

1.3.1.6.6. Biên bản họp Hội đồng thành viên

Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
- b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp;
- c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
- d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;
- đ) Các quyết định được thông qua;
- e) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.

Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

1.3.1.6.7. Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định hoặc không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết được thực hiện theo quy định sau đây:

- (i) Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản để thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền;
- (ii) Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ trình về nội dung cần quyết định, dự thảo nghị quyết và phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Hội đồng thành viên;
- (iii) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, tỷ lệ phần vốn của thành viên Hội đồng thành viên;

c) Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

d) Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về công ty;

đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên công ty và được gửi về công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ;

(iv) Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty. Báo cáo kết quả kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng thành viên và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Mục đích, nội dung lấy ý kiến;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền đã gửi phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên mà không nhận được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;

c) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có);

d) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

e) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo kết quả kiểm phiếu.

1.3.1.6.8. Hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết đó.

Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết đã được thông qua thì nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực thi hành.

1.3.1.6.9. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

(i) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;

b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;

c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.

(ii) Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

(iii) Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản (i), (ii) này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng theo quy định tại khoản (i), (ii) này hoặc gây thiệt hại cho công ty.

1.3.1.6.10. Thay đổi vốn điều lệ

(i) Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

(ii) Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật doanh nghiệp. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

(iii) Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:³³

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

³³ Khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp.

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật doanh nghiệp;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật doanh nghiệp.

(iv) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.³⁴ Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

1.3.1.6.11. Điều kiện để chia lợi nhuận³⁵

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

1.3.1.6.12. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật doanh nghiệp hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều 69 của Luật doanh nghiệp thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với phần vốn đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia.

1.3.1.6.13. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác³⁶

(i) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác của công ty có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;

b) Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối;³⁷

³⁴ Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;
c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;
d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

³⁵ Điều 69 Luật doanh nghiệp.

³⁶ Điều 71 Luật doanh nghiệp.

d) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(ii) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

Việc kê khai quy định tại khoản (i) và khoản (iii) Điều 71 Luật doanh nghiệp phải được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi lợi ích liên quan. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty và các giao dịch của họ với công ty. Danh sách này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Thành viên, người quản lý, Kiểm soát viên của công ty và người đại diện theo ủy quyền của họ có quyền xem, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung thông tin quy định tại khoản (i) và khoản (iii) Điều 71 Luật doanh nghiệp trong giờ làm việc theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

1.3.1.6.14. Khởi kiện người quản lý

Luật doanh nghiệp quy định (Điều 72): Thành viên công ty tự mình, hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm, dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm quy định tại Điều 71 của Luật doanh nghiệp;

b) Không thực hiện đúng và đầy đủ hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty về các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng thành viên;

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.

1.3.2. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

1.3.2.1. Khái niệm

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

1.3.2.2. Thực hiện góp vốn thành lập công ty

³⁷ Khoản 3 Điều 71 Luật doanh nghiệp: Văn bản thông báo người có liên quan bao gồm nội dung sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp địa chỉ trụ sở chính, của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

1.3.2.3. Quyền của chủ sở hữu công ty

(i) Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:

- a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
- c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty;
- d) Quyết định dự án đầu tư phát triển;
- đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
- h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
- i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;
- k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;
- l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;
- m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;
- n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
- o) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

(ii) Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:

- a) Quyết định, nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- b) Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
- d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;
- đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;
- e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
- g) Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.3.2.4. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

- Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.
- Tuân thủ Điều lệ công ty.
- Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
- Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.
- Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
- Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
- Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.3.2.5. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.

Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật, thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế.

Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.

Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

1.3.2.6. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

(i) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

- a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
- b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

(ii) Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

(iii) Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.

1.3.2.6.1. Hội đồng thành viên

Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quyền, nghĩa vụ và quan hệ làm việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 57 và quy định khác có liên quan của Luật doanh nghiệp.

Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 58 của Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành. Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 61 của Luật doanh nghiệp.

1.3.2.6.2. Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

1.3.2.6.3. Giám đốc, Tổng giám đốc

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.³⁸ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng

³⁸ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
- b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
- c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
- d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;
- đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
- e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
- g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
- h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
- i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- k) Tuyển dụng lao động;
- l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

1.3.2.6.4. Kiểm soát viên

Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.³⁹ Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty;
- b) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định;
- c) Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty;

³⁹ Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
- b) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

d) Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên;

đ) Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong công ty;

e) Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty.

1.3.2.6.5. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

- Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty.

- Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.3.2.6.6. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên

- Người quản lý công ty và Kiểm soát viên được hưởng thù lao hoặc tiền lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

- Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

- Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của kiểm soát viên có thể do chủ sở hữu công ty chi trả trực tiếp theo quy định tại Điều lệ công ty.

1.3.2.6.7. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

1.3.2.6.7. Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan

(i) Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với những người sau đây phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định:

- a) Chủ sở hữu công ty và người có liên quan của chủ sở hữu công ty;
- b) Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
- c) Người có liên quan của những người quy định tại điểm b khoản này;
- d) Người quản lý của chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý đó;
- đ) Người có liên quan của những người quy định tại điểm d khoản này.

Người ký kết hợp đồng phải thông báo cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch đó.

(ii) Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết; người có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

(iii) Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản (i) này chỉ được chấp thuận khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;
- b) Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;
- c) Chủ sở hữu công ty tuân thủ đúng nghĩa vụ quy định tại khoản 4 Điều 76 của Luật doanh nghiệp.

(iv) Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật nếu được ký kết không đúng quy định tại các khoản (i), (ii), (iii) này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký hợp đồng và người có liên quan là các bên của hợp đồng liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh và hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

(v) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu với chủ sở hữu công ty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.

1.3.2.6.8. Thay đổi vốn điều lệ

(i) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật doanh nghiệp.

(ii) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

(iii) Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật doanh nghiệp.

1.4. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC⁴⁰

1.4.1. Cơ cấu tổ chức quản lý

Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật doanh nghiệp.⁴¹

1.4.1.1. Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội

⁴⁰ Áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước (Điều 88 Luật doanh nghiệp):

1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý theo quy định tại Chương IV Luật doanh nghiệp, các quy định tương ứng tại mục 2 Chương III và các quy định khác có liên quan của Luật doanh nghiệp. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Chương IV với Chương III và các quy định có liên quan khác của Luật doanh nghiệp, thì áp dụng quy định tại Chương IV Luật doanh nghiệp.

2. Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ thực hiện theo các quy định tương ứng tại mục 1 Chương III và Chương V của Luật doanh nghiệp.

⁴¹ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.⁴²

1.4.1.1.1. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên đối với công ty do công ty làm chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phần, phần vốn góp. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Quyết định các nội dung theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
- b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
- c) Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, chủ trương phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty;
- d) Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ của công ty.
- đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

1.4.1.1.2. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên:

(i) Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 92 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản;
- c) Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;
- d) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- đ) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.

(ii) Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau đây:

⁴² Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên (Điều 92 Luật doanh nghiệp):

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.
- Không phải là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc không phải là người quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên.
- Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

a) Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

b) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội;

c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

(iii) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

1.4.1.2. Chủ tịch Hội đồng thành viên

(i) Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty của công ty mình và các doanh nghiệp khác.

(ii) Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị chương trình, tài liệu cuộc họp hoặc lấy ý kiến Hội đồng thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên;

d) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của cơ quan đại diện chủ sở hữu và nghị quyết Hội đồng thành viên;

đ) Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của công ty, kết quả quản lý điều hành của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;

e) Tổ chức công bố, công khai thông tin về công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố;

g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

(iii) Ngoài các trường hợp quy định tại Điều 93 của Luật doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể bị miễn nhiệm, cách chức nếu không thực hiện được các nhiệm vụ quy định tại khoản (ii) này.

1.4.1.3. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên khác của Hội đồng thành viên

(i) Tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

(ii) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty.

(iii) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

1.4.1.4. Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên

- Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của công ty và Nhà nước.
- Trung thành với lợi ích của công ty và Nhà nước; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà mình và người có liên quan làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.
- Chấp hành các nghị quyết của Hội đồng thành viên.
- Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
- Trường hợp phát hiện thành viên Hội đồng thành viên có hành vi vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Hội đồng thành viên có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản với cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

1.4.1.5. Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình. Đối với những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng thành viên có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ công ty.

Hội đồng thành viên có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên. Các thành viên Hội đồng thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trình họp. Nội dung và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng thành viên và các đại biểu được mời dự họp, nếu có trước ngày họp ít nhất 03 ngày làm việc.

Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến việc kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp.

Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc các phương tiện điện tử khác và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên và đại biểu khác được mời dự họp. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp. Hình thức họp trực tuyến có thể được áp dụng khi cần thiết.

Cuộc họp lấy ý kiến các thành viên của Hội đồng thành viên họp lệ khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên tham dự. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên tham dự biểu quyết tán thành; trường hợp có số phiếu ngang nhau thì nội dung có phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền chủ trì cuộc họp là nội dung được thông qua. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình và kiến nghị lên cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty.

Trường hợp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản thì nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa tổng số thành viên tán thành. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên.

Căn cứ vào nội dung và chương trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng thành viên có quyền hoặc có trách nhiệm mời đại diện có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình cuộc họp. Đại diện các cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết. Các ý kiến phát biểu của đại diện được mời dự họp được ghi đầy đủ vào biên bản của cuộc họp.

Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các quyết định được Hội đồng thành viên thông qua và kết luận của các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng thành viên. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.⁴³

Thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý, điều hành trong công ty, công ty con do công ty nắm 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của công ty tại các doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp theo quy chế thông tin do Hội đồng thành viên quy định hoặc theo nghị quyết

⁴³ Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm, mục đích, chương trình họp; danh sách thành viên dự họp; vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
- Số phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành đối với trường hợp không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng hoặc số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với trường hợp có áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng;
- Các quyết định được thông qua; họ, tên, chữ ký của thành viên dự họp.

của Hội đồng thành viên. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng thành viên, trừ trường hợp Hội đồng thành viên có quyết định khác.

Hội đồng thành viên sử dụng bộ máy điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu của công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình. Chi phí hoạt động của Hội đồng thành viên, tiền lương, phụ cấp và thù lao khác được tính vào chi phí quản lý công ty.

Trường hợp cần thiết, Hội đồng thành viên tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong nước và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của công ty.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong nghị quyết đó, trừ các trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

1.4.1.6. Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty có nhiệm kỳ không quá 05 năm. Chủ tịch công ty có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ. Tiêu chuẩn, điều kiện và các trường hợp miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 92 và Điều 93 của Luật doanh nghiệp.

Chủ tịch công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 91 và Điều 96 của Luật doanh nghiệp. Các quyết định thuộc thẩm quyền này phải được lập thành văn bản, ký tên với chức danh Chủ tịch công ty bao gồm cả trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định và được tính vào chi phí quản lý công ty.

Chủ tịch công ty sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu của công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch công ty tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của công ty.

Quyết định của Chủ tịch công ty có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong quyết định đó, trừ trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

Trường hợp Chủ tịch công ty vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty; việc ủy quyền phải được thông báo kịp thời bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. Các trường hợp ủy quyền khác thực hiện theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ của công ty.

1.4.1.7. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

(i) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Công ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động.⁴⁴

(ii) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty;

b) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty;

c) Quyết định các công việc hằng ngày của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chấp thuận;

đ) Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

e) Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm;

i) Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty, khi xét thấy cần thiết;

k) Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

⁴⁴ Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc (Điều 100 Luật doanh nghiệp):

1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu.
3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên.
4. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.
5. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên công ty.
6. Không đồng thời là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
7. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.
8. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
9. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

- l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- (iii) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
 - a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 100 của Luật này;
 - b) Có đơn xin nghỉ việc.
- (iv) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị cách chức trong các trường hợp sau đây:
 - a) Doanh nghiệp không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật;
 - b) Doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm;
 - c) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp;
 - d) Doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật;
 - đ) Vi phạm một trong số các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 96 của Luật này;
 - e) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
- (v) Trường hợp miễn nhiệm, cách chức đối với Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý công ty khác do Điều lệ công ty quy định.

1.4.1.8. Ban kiểm soát

- (i) Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm 01 Kiểm soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát gồm 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và được bổ nhiệm lại nhưng mỗi cá nhân chỉ được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.⁴⁵
- (ii) Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a) Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của công ty;
 - b) Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;

⁴⁵ Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên (Điều 103 Luật doanh nghiệp)

1. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh được đào tạo.
2. Không phải là người lao động của công ty.
3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của đối tượng sau đây:
 - a) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty;
 - b) Thành viên Hội đồng thành viên của công ty;
 - c) Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty;
 - d) Kiểm soát viên khác của công ty.
4. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
5. Không được đồng thời là Kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước.
6. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

c) Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của công ty;

d) Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

đ) Giám sát các giao dịch của công ty với các bên có liên quan;

e) Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn hoặc giao dịch kinh doanh bất thường của công ty;

g) Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và Hội đồng thành viên;

h) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc quy định tại Điều lệ công ty.

(iii) Tiền lương, thưởng của Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định và chi trả.

(iv) Quyền của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng thành viên, các cuộc tham vấn và trao đổi chính thức và không chính thức của cơ quan đại diện chủ sở hữu với Hội đồng thành viên; có quyền chất vấn Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty về các kế hoạch, dự án hay chương trình đầu tư phát triển và các quyết định khác trong quản lý điều hành công ty.

- Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch và tài liệu khác của công ty; kiểm tra công việc quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

- Xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty, thực trạng vận hành và hiệu lực các quy chế quản trị nội bộ công ty.

- Yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người quản lý khác báo cáo, cung cấp thông tin về bất cứ việc gì trong phạm vi quản lý và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.

- Yêu cầu những người quản lý công ty báo cáo về thực trạng tài chính, thực trạng và kết quả kinh doanh của công ty con khi xét thấy cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trường hợp phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và những người quản lý khác làm trái các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái các quy định đó; hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, làm trái các quy định về quản lý kinh tế, trái quy định Điều lệ công ty hoặc các quy chế quản trị nội bộ công ty phải báo cáo ngay cho cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty, các thành viên khác của Ban kiểm soát và cá nhân có liên quan.

- Đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu thành lập đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tham mưu và trực tiếp hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

- Thực hiện các quyền khác quy định tại Điều lệ công ty.

(v) Chế độ làm việc của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty; các thành viên khác có thể tham gia Ban kiểm soát của không quá 04 doanh nghiệp nhà nước nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

- Trưởng Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý và hằng năm của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên.

- Kiểm soát viên độc lập và chủ động thực hiện các nhiệm vụ và công việc được phân công; đề xuất, kiến nghị thực hiện các nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch, ngoài phạm vi được phân công khi xét thấy cần thiết.

- Ban kiểm soát họp ít nhất mỗi tháng một lần để rà soát, đánh giá, thông qua báo cáo kết quả kiểm soát trong tháng trình cơ quan đại diện chủ sở hữu; thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động tiếp theo của Ban kiểm soát.

- Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua khi có đa số thành viên dự họp tán thành. Các ý kiến khác với nội dung quyết định đã được thông qua phải được ghi chép đầy đủ, chính xác và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu.

(vi) Trách nhiệm của Kiểm soát viên

- Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật này và Điều lệ công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty.

- Trung thành với lợi ích của Nhà nước và công ty; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định trên đây mà gây thiệt hại cho công ty thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

- Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ quy định trên đây đều phải trả lại công ty.

- Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Ban kiểm soát có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

(vi) Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 103 của Luật doanh nghiệp;

b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

c) Được cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân công thực hiện nhiệm vụ khác;

d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

(vii) Kiểm soát viên bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trong 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

1.4.1.9. Công bố thông tin định kỳ⁴⁶

(i) Công ty phải công bố định kỳ trên trang thông tin điện tử của công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu những thông tin sau đây:

a) Thông tin cơ bản về công ty và điều lệ công ty;

b) Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hằng năm;

c) Báo cáo và tóm tắt Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập trong thời hạn không quá 150 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

d) Báo cáo và tóm tắt Báo cáo tài chính giữa năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập; thời hạn công bố phải trước ngày 31 tháng 07 hằng năm;

Nội dung công bố thông tin quy định tại điểm c và điểm d khoản này bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất;

đ) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo;

e) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác;

g) Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức công ty.

(ii) Báo cáo thực trạng quản trị công ty bao gồm các thông tin sau đây:

a) Thông tin về cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu;

⁴⁶ Xem thêm hướng dẫn chi tiết về vấn đề này tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước ngày 18/9/2015.

b) Thông tin về người quản lý công ty, bao gồm trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, cách thức được bổ nhiệm, công việc quản lý được giao, mức tiền lương, thưởng, cách thức trả tiền lương và các lợi ích khác; những người có liên quan và ích lợi có liên quan của họ với công ty; bản tự kiểm điểm, đánh giá hằng năm của họ trên cương vị là người quản lý công ty;

c) Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu; các quyết định, nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

d) Thông tin về Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và hoạt động của họ;

đ) Thông tin về Đại hội công nhân, viên chức; số lượng lao động bình quân năm và tại thời điểm báo cáo, tiền lương và lợi ích khác bình quân năm trên người lao động;

e) Báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra (nếu có) và các báo cáo của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;

g) Thông tin về các bên có liên quan của công ty, giao dịch của công ty với bên có liên quan;

h) Các thông tin khác theo quy định của Điều lệ công ty.

(iii) Thông tin được báo cáo và công bố phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

(iv) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

1.4.1.10. Công bố thông tin bất thường⁴⁷

Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty về các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

a) Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;

b) Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hoạt động hoặc giấy phép khác liên quan đến kinh doanh của công ty;

c) Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc bất kỳ giấy phép, giấy chứng nhận khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

d) Thay đổi người quản lý công ty, gồm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán;

⁴⁷ Xem thêm hướng dẫn chi tiết về vấn đề này tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước ngày 18/9/2015.

đ) Có quyết định kỷ luật, khởi tố, có bản án, quyết định của Tòa án đối với một trong số các người quản lý doanh nghiệp;

e) Có kết luận của cơ quan thanh tra hoặc của cơ quan quản lý thuế về việc vi phạm pháp luật của doanh nghiệp;

g) Có quyết định thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập, hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài chính;

h) Có quyết định, thành lập, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con; quyết định đầu tư, giảm vốn hoặc thoái vốn đầu tư tại các công ty khác.

1.5. CÔNG TY CỔ PHẦN

1.5.1. Khái niệm

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

1.5.2. Vốn công ty cổ phần

(i) Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

(ii) Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

(iii) Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

(iv) Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.

(v) Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật doanh nghiệp;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật doanh nghiệp.

1.5.3. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp⁴⁸

(i) Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

(ii) Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản (i) này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

(iii) Nếu sau thời hạn quy định tại khoản (i) này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản (i) này.

(iv) Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản (i) này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản (i) và điểm d khoản (iii) này.

1.5.4. Phân loại cổ phần

⁴⁸ Điều 112 Luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

- a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
- b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;
- c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
- d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1.5.5. Quyền của cổ đông phổ thông

(i) Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp;

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;

(ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

- a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
- c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản (iii) này;
- d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
- đ) Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

(iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản (ii) này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
- b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;
- c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

(iv) Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định, tại điểm a khoản (ii) này được thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

(v) Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.5.6. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

(i) Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

(ii) Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

(iii) Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

(iv) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.5.7. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

(i) Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

(ii) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản (i) này;

b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản (iii) này.

(iii) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

1.5.8. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

(i) Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

(ii) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

a) Nhận cổ tức theo quy định tại khoản (i) này;

b) Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản (iii) này.

(iii) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1.5.9. Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại

(i) Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

(ii) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản (iii) này.

(iii) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1.5.10. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

(i) Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

Trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

(ii) Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

(iii) Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.⁴⁹

(iv) Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

1.5.11. Cổ phiếu; sổ đăng ký cổ đông

⁴⁹ Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp.

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.⁵⁰ Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.⁵¹

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.⁵² Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán, cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

1.5.12. Chào bán cổ phần

(i) *Chào bán cổ phần* là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.⁵³

Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

⁵⁰ Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
- c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
- d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
- đ) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
- e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);
- g) Sổ đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
- h) Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật doanh nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

⁵¹ Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây:

- a) Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu hủy;
 - b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
- Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.

⁵² Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
- d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
- đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

⁵³ Điều 122 Luật doanh nghiệp

- b) Chào bán ra công chúng;
- c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.⁵⁴ Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

(ii) *Chào bán cổ phần riêng lẻ:*⁵⁵

Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh.⁵⁶ Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu sau đây:

- a) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
- b) Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

(iii) *Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:*⁵⁷

Là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

b) Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký

⁵⁴ Xem thêm: Luật chứng khoán. Chi tiết xem tại www.ssc.gov.vn

⁵⁵ Điều 123 Luật doanh nghiệp

⁵⁶ Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;
- c) Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;
- d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

⁵⁷ Điều 124 Luật doanh nghiệp

mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.

Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật doanh nghiệp được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

(iv) *Bán cổ phần:*

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

- Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
- Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;
- Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.

1.5.13. Chuyển nhượng cổ phần

(i) Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

(ii) Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

(iii) Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.

(iv) Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

(v) Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty.

(vi) Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.

(vii) Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

1.5.14. Phát hành trái phiếu

(i) Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(ii) Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó sẽ không được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

(iii) Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bị hạn chế bởi quy định tại khoản (ii) này.

(iv) Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình nghị quyết của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu.

(v) Trường hợp công ty cổ phần phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

1.5.15. Mua cổ phần, trái phiếu

Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.

1.5.15.1. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông⁵⁸

⁵⁸ Điều 129 Luật doanh nghiệp

(i) Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

(ii) Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản (i) này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

1.5.15.2. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty⁵⁹

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

(i) Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

(ii) Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản (iii) này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

(iii) Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.

Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

1.5.15.3. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại⁶⁰

⁵⁹ Điều 130 Luật doanh nghiệp

⁶⁰ Điều 131 Luật doanh nghiệp

(i) Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật doanh nghiệp nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

(ii) Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật doanh nghiệp được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 111 của Luật doanh nghiệp. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

(iii) Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với công ty.

(iv) Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

1.5.16. Trả cổ tức⁶¹

(i) Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

(ii) Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

(iii) Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

(iv) Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức

⁶¹ Điều 132 Luật doanh nghiệp

bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.⁶²

(v) Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

(vi) Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các Điều 122, 123 và 124 của Luật doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

1.5.17. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức

Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật doanh nghiệp hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 132 của Luật doanh nghiệp thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

1.5.18. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

1.5.18.1. Đại hội đồng cổ đông

⁶² Thông báo phải có các nội dung sau đây:

- Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;
- Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
- Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;
- Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
- đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

1.5.18.1.1. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

(i) Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

(ii) Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
- b) Báo cáo tài chính hằng năm;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
- đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

(iii) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;
- b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(iv) Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản (iii) này.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

(v) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản (iv) này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

(vi) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản (v) này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

(vii) Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
- c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
- đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

(viii) Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các khoản (iv), (v), (vi) này sẽ được công ty hoàn lại.

1.5.18.1.3. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

1.5.18.1.4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

(i) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

(ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

(iii) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản (ii) này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

(iv) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản (ii) này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản (iii) này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

1.5.18.1.5. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

(i) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

(ii) Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty.

(iii) Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

b) Phiếu biểu quyết;

c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.

(iv) Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp quy định tại khoản (iii) này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.

1.5.18.1.5. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

(i) Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản (ii) này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật doanh nghiệp thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

(ii) Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

1.5.18.1.6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

(i) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

(ii) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản (i) này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

(iii) Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản (ii) này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

(iv) Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật doanh nghiệp.

1.5.18.1.7. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như sau:

(i) Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;

(ii) Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;

(iii) Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

(iv) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

(v) Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác;

(vi) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

(vii) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

(viii) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

(ix) Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản (viii) này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

1.5.18.1.8. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

(i) Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

(ii) Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

- b) Định hướng phát triển công ty;
- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

1.5.18.1.9. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

(i) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

(ii) Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản (i) và khoản (iii) này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

(iii) Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

(iv) Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

(v) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

1.5.18.1.10. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

(i) Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

(ii) Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật doanh nghiệp;

(iii) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

e) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty;

(iv) Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

(v) Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- đ) Các vấn đề đã được thông qua;
- e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

(vi) Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty;

(vii) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;

(viii) Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1.5.18.1.11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

(i) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

(ii) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

(iii) Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

1.5.18.1.12. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

(i) Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật doanh nghiệp;

(ii) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

1.5.18.1.13. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

(i) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

(ii) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

(iii) Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 của Luật doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

1.5.18.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật doanh nghiệp;

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

n) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty;

q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên.

1.5.18.2.1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạn cụ thể của nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Trường hợp công ty cổ phần được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp thì các giấy tờ, giao dịch của công ty phải ghi rõ “thành viên độc lập” trước họ, tên của thành viên Hội đồng quản trị tương ứng.

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

1.5.18.2.2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

(i) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

(ii) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

(iii) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản (ii) này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

1.5.18.2.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị

(i) Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản (ii) này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

(ii) Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

(iii) Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

(iv) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

(v) Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- đ) Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

(vi) Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

1.5.18.2.4. Cuộc họp Hội đồng quản trị

(i) Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

(ii) Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở chính của công ty hoặc ở nơi khác.

(iii) Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

(iv) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập;
- b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;
- d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

(v) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

(vi) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

(vii) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

(viii) Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

(ix) Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều này.
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(x) Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

1.5.18.2.5. Biên bản họp Hội đồng quản trị

(i) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- c) Thời gian, địa điểm họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Các vấn đề đã được thông qua;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

(ii) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

(iii) Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

1.5.18.2.6. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.

Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

1.5.18.2.7. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

(i) Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật doanh nghiệp;

b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn từ chức;

d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

(ii) Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(iii) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp.

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

1.5.18.3. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

(i) Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

(ii) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không

hạn chế. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật doanh nghiệp.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
- b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
- d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
- đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
- g) Tuyển dụng lao động;
- h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc: Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

- a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;
- c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

1.5.18.4. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.⁶³

Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

1.5.18.4.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp.

- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát

⁶³ Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên (Điều 164 Luật doanh nghiệp):

1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

- Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

- Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1.5.18.4.2. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

- Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

- Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc.

- Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

1.5.18.4.3. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây:

- Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợi khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức lương, thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;

- Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;

- Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

1.5.18.4.4. Trách nhiệm của Kiểm soát viên

- Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

- Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Trường hợp vi phạm quy định trên mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty.

- Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

1.5.18.4.5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

(i) Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật này;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

(ii) Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1.5.19. Công khai các lợi ích liên quan

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau đây:

(i) Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những *người có liên quan* của công ty theo quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật doanh nghiệp và các giao dịch tương ứng của họ với công ty;⁶⁴

(ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;

(iii) Việc kê khai quy định tại khoản (ii) này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng;

(iv) Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản (i) và (ii) này được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung Danh sách nói trên tại các chi nhánh của công ty;

⁶⁴ *Người có liên quan* là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty;

b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;

c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp;

d) Người quản lý doanh nghiệp;

đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của nhân viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;

h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để đầu tư phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.

c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc;

d) Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản này tiếp cận, xem, trích lục và sao chép danh sách những người có liên quan của công ty và những nội dung khác một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

(v) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty.

1.5.20. Trách nhiệm của người quản lý công ty

(i) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;

c) Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

(ii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.5.21. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc

(i) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật doanh nghiệp;

b) Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

d) Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

đ) Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(ii) Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty sẽ tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.

1.5.22. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

(i) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.

(ii) Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

(iii) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản (ii) này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

(iv) Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản (ii), (iii) này, gây thiệt

hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

1.5.23. Trình báo cáo hằng năm

(i) Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài liệu sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty.

(ii) Đối với công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán thì báo cáo tài chính hằng năm của công ty cổ phần phải được kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

(iii) Các báo cáo và tài liệu quy định tại khoản (i) này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

(iv) Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính và chi nhánh của công ty chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn.

Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư hoặc kế toán và kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét các báo cáo quy định tại Điều này trong thời gian hợp lý.

1.5.24. Công khai thông tin công ty cổ phần

(i) Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật về kế toán và pháp luật có liên quan.

(ii) Công ty cổ phần công bố trên trang thông tin điện tử (nếu có) của mình các thông tin sau đây:

- a) Điều lệ công ty;
- b) Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;
- c) Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- d) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(iii) Công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính chậm nhất 03 ngày sau khi có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại

cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài.

(iv) Công ty cổ phần đại chúng thực hiện công bố, công khai thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Công ty cổ phần mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ công bố, công khai thông tin theo quy định tại Điều 108 và Điều 109 của Luật doanh nghiệp.

1.6. CÔNG TY HỢP DANH

1.6.1. Khái niệm

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

1.6.2. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.⁶⁵ Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

1.6.3. Tài sản của công ty hợp danh

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

⁶⁵ Giấy chứng nhận phần vốn góp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- b) Vốn điều lệ của công ty;
- c) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên; loại thành viên;
- d) Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của thành viên;
- đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
- e) Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;
- g) Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.

- Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;
- Tài sản tạo lập được mang tên công ty;
- Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;
- Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

1.6.4. Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh

- Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
- Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

1.6.5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

(i) Thành viên hợp danh có các quyền sau đây:

- a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;
- b) Nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty;
- c) Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; trường hợp ứng trước tiền của mình để thực hiện công việc kinh doanh của công ty thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước;
- d) Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của chính thành viên đó;
- đ) Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty khi xét thấy cần thiết;
- e) Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

h) Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

i) Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

(ii) Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tiến hành quản lý và thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;

b) Tiến hành quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

c) Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty;

đ) Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;

e) Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;

g) Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.6.6. Hội đồng thành viên

(i) Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

(ii) Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp.

(iii) Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:⁶⁶

a) Phương hướng phát triển công ty;

⁶⁶ Khoản 3 Điều 177 Luật doanh nghiệp

- b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - c) Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;
 - d) Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;
 - đ) Quyết định dự án đầu tư;
 - e) Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;
 - g) Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;
 - h) Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận, được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;
 - i) Quyết định giải thể công ty.
- (iv) Quyết định về các vấn đề khác không quy định tại khoản (iii) này được thông qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
- (v) Quyền tham gia biểu quyết của thành viên góp vốn được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.6.7. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

- (i) Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.
- (ii) Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác. Thông báo mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.
- Các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 177 của Luật doanh nghiệp phải được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công ty quy định.
- (iii) Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ tọa cuộc họp. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản của công ty.⁶⁷

⁶⁷ Nội dung biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;
- b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- c) Thời gian, địa điểm họp;
- d) Họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp;
- đ) Các ý kiến của thành viên dự họp;
- e) Các nghị quyết được thông qua, số thành viên tán thành và nội dung cơ bản của các nghị quyết đó;
- g) Họ, tên, chữ ký của các thành viên dự họp.

1.6.8. Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

(i) Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh, trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

(ii) Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.

(iii) Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

(iv) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;

b) Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh, giữa các thành viên hợp danh;

d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;

e) Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

1.6.9. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

(i) Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

b) Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Bị khai trừ khỏi công ty;

d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

(ii) Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn

bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

(iii) Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong các trường hợp sau đây:

a) Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai;

b) Vi phạm quy định tại Điều 175 của Luật doanh nghiệp;

c) Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác;

d) Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của thành viên hợp danh.

(iv) Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng.

(v) Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.

(vi) Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó.

1.6.10. Tiếp nhận thành viên mới

Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

1.6.11. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

(i) Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;

c) Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

d) Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;

đ) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty;

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;

g) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

h) Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

(ii) Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;

b) Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;

c) Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.7. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

1.7.1. Khái niệm

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

1.7.2. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tư nhân đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

1.7.3. Quản lý doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

1.7.4. Cho thuê doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định, trong hợp đồng cho thuê.

1.7.5. Bán doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp.

1.8. NHÓM CÔNG TY

1.8.1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

1.8.2. Công ty mẹ, công ty con

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
- b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
- c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

1.8.3. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

(i) Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(ii) Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

(iii) Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

(iv) Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản (iii) này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.

(v) Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản (iii) này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có

quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh, công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

(vi) Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại khoản (iii) này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại.

1.8.4. Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

(i) Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;
- b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;
- c) Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.

(ii) Người chịu trách nhiệm lập báo cáo quy định tại khoản (i) này chưa được lập và đệ trình các báo cáo đó nếu chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính của các công ty con.

(iii) Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con.

(iv) Người quản lý công ty mẹ sử dụng các báo cáo đó để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

(v) Trong trường hợp người quản lý công ty mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi thẩm quyền mà vẫn không nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như quy định từ công ty con thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm các thông tin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch.

(vi) Các báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm của công ty mẹ, của công ty con và các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ. Bản sao của các báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này phải có ở các chi nhánh của công ty mẹ trên lãnh thổ Việt Nam.

(vii) Đối với các công ty con, ngoài các báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp luật, còn phải lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và các giao dịch khác với công ty mẹ.

1.9. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

1.9.1. Chia doanh nghiệp

(i) Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

(ii) Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

b) Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty quy định tại điểm a khoản này.

(iii) Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới tương ứng với các trường hợp quy định tại khoản (i) này.

(iv) Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

(v) Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới. Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1.9.2. Tách doanh nghiệp

(i) Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

(ii) Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

(iii) Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

(iv) Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định tại điểm a khoản này.

(v) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

1.9.3. Hợp nhất doanh nghiệp

(i) Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất

(ii) Thủ tục hợp nhất công ty được quy định như sau:

a) Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

(iii) Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

(iv) Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật này và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Hợp đồng hợp nhất;

b) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.

(v) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

(vi) Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất. Trường hợp công ty bị hợp nhất có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty hợp nhất thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp nhất phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị hợp nhất để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1.9.4. Sáp nhập doanh nghiệp

(i) Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

(ii) Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:

a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;

c) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

(iii) Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

(iv) Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật này và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:

- a) Hợp đồng sáp nhập;
- b) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
- c) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.

(v) Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập.

Trường hợp công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty nhận sáp nhập thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị sáp nhập để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1.9.5. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

(i) Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

(ii) Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

(iii) Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(iv) Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

(v) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật doanh nghiệp; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1.9.6. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

(i) Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật này.

(ii) Việc chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần, phần vốn góp quy trình tại khoản (i) này phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.

(iii) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản (i) này và xảy ra trường hợp điểm c khoản (i) này, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(iv) Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

(v) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật doanh nghiệp; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1.9.7. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

(i) Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

(ii) Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(iii) Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

(iv) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật doanh nghiệp; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1.9.8. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

(i) Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật doanh nghiệp;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

(ii) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản (i) này.

(iii) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại khoản (ii) này, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật doanh nghiệp; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1.9.9. Tạm ngừng kinh doanh

(i) Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

(ii) Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

(iii) Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

1.9.10. Giải thể doanh nghiệp

(i) Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:⁶⁸

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

⁶⁸ Khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.⁶⁹

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

(ii) Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

- Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.⁷⁰

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

- Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:⁷¹

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác.

⁶⁹ Lưu ý: Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

⁷⁰ Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

⁷¹ Khoản 5 Điều 202 Luật doanh nghiệp

- Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

- Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(iii) Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Việc giải thể doanh nghiệp do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (điểm d khoản 1 Điều 201 của Luật doanh nghiệp) được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh, phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

- Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 202 của Luật doanh nghiệp.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

- Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Cá nhân người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định này.

(iv) Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

(v) Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

d) Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

1.9.11. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

(i) Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(ii) Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

a) Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

d) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

(iii) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

(iv) Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

(v) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định tại khoản (ii) này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1.9.12. Phá sản doanh nghiệp

Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.⁷²

⁷² Xem chi tiết vấn đề này tại Luật phá sản doanh nghiệp 2014.

CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

2.1. TỔNG QUAN VỀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Cơ sở pháp lý đầu tiên cho hoạt động đầu tư nước ngoài ở Việt Nam là Nghị định số 115/CP ngày 18-4-1977 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ về đầu tư nước ngoài ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kêu gọi đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam dưới các hình thức khác nhau, không phân biệt chế độ chính trị, kinh tế, xã hội.¹

Từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (tháng 12/1987, bổ sung, sửa đổi năm 1990, 1992), đã thu hút được một số lượng vốn đầu tư nước ngoài đáng kể. Nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn và yêu cầu mới của đất nước, tạo môi trường pháp lý an toàn và hấp dẫn hơn để thu hút FDI, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tăng cường hội nhập kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để tăng cường quản lý nhà nước đối với FDI, ngày 12/11/1996, Quốc hội đã thông qua luật mới về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 9/6/2000 một lần nữa khẳng định chủ trương mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài để phục vụ sự nghiệp công hoá, hiện đại hoá đất nước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2005, đã có 7.086 dự án được cấp phép với tổng số vốn đăng ký đạt 66,185 tỷ USD.²

Luật Đầu tư 2005 được Quốc hội XI, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006, thay thế Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước. Luật Đầu tư 2005 được thông qua vào thời điểm kinh tế tư nhân trong nước phát triển mạnh mẽ, hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đạt được những bước tiến lớn sau thời gian thực hiện những quy định thông thoáng của Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987, Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Doanh nghiệp năm 1999. Đây cũng là thời điểm Việt Nam chính thức trở thành Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với những cam kết mạnh mẽ về mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ và tự do hóa hoạt động đầu tư.

Việc ban hành Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư là một bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư tại Việt Nam.³ Cùng với Luật Doanh nghiệp 2005 được thông qua và có hiệu lực thi hành vào

¹ Xem thêm: Lê Minh Toàn (chủ biên), *Luật Kinh tế Việt Nam*, Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, 2002. Lê Minh Toàn (chủ biên), *Luật Kinh doanh Việt Nam* (2 tập), Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, 2009.

² Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê www.gso.gov.vn. Xem thêm bình luận về Luật đầu tư 2005 tại: Lê Minh Toàn (chủ biên), *Luật Kinh doanh Việt Nam* (2 tập), Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, 2009. Lê Minh Toàn, Vũ Quang, *Luật kinh doanh Việt Nam*, Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, 2012.

³ Tổng cộng, đã có 24 văn bản trực tiếp hướng dẫn và thi hành Luật Đầu tư 2005 được ban hành. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành cũng ban hành hơn 60 văn bản quy định những nội dung liên quan đến quy định của Luật Đầu tư. Ngoài ra, đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài, sau khi Luật Đầu tư 2005 có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 quy định về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí (được sửa đổi, sửa đổi bởi Nghị định số 17/2009/NĐ-CP ngày 16/2/2009); Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007 về mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Ngoài ra, hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài còn chịu

cùng một thời điểm (1/7/2006), đây là đầu tiên sau gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam có một khung pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp được áp dụng thống nhất cho tất cả các nhà đầu tư và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Những quy định của Luật Đầu tư 2005 và các điều khoản được quy định chi tiết tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP đã mở rộng quyền tự chủ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư bằng việc xóa bỏ về cơ bản một loạt rào cản đầu tư không phù hợp với thông lệ kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Những tác động tích cực của việc thi hành Luật Đầu tư 2005 bao gồm:⁴

Thứ nhất, Luật Đầu tư đã lần đầu tiên thực hiện nguyên tắc nhà đầu tư được thực hiện hoạt động đầu tư trong tất cả các lĩnh vực và ngành nghề mà pháp luật không cấm; được tự chủ quyết định lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, địa bàn, quy mô vốn đầu tư, đối tác đầu tư và thời hạn hoạt động của dự án... Với những quy định thông thoáng nêu trên, Luật Đầu tư đã tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi hơn để các nhà đầu tư bỏ vốn thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong hầu khắp các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

Sau khi Luật Đầu tư có hiệu lực và Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) bước vào một giai đoạn mới, với quy mô vốn đăng ký liên tục lập mức kỷ lục (năm 2006 đạt 12 tỷ USD, năm 2007 đạt 21 tỷ USD và đỉnh cao mới được thiết lập năm 2008 với 71,7 tỷ USD đăng ký). Từ năm 2009, dòng ĐTNN đăng ký biến động theo chiều hướng giảm do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu (năm 2009 đạt 23,1 tỷ USD, năm 2010 đạt 19,89 tỷ USD và năm 2011 đạt 15,62 tỷ USD). Từ năm 2012 dòng vốn đăng ký lại có xu hướng tăng lên, năm 2012 đạt 16,347 tỷ USD, năm 2013 đạt 22,35 tỷ USD, năm 2014 đạt 21,92 tỷ USD, năm 2015 (tính đến hết tháng 11/2015) đạt 20,22 tỷ USD (tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014).⁵

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và là khu vực có tốc độ phát triển năng động nhất. ĐTNN là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp; thúc đẩy chuyển giao công nghệ đồng thời đóng góp đáng kể vào NSNN và các cân đối vĩ mô. Bên cạnh đó ĐTNN cũng góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch của môi trường đầu tư Việt Nam; giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế quốc tế, đồng thời tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế khác. Về mặt xã hội, ĐTNN góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đào tạo và cải thiện nguồn nhân lực; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Nguồn vốn đầu tư trong nước tiếp tục được huy động với mức cao phù hợp định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật khác trong các lĩnh vực quản lý ngoại hối, tín dụng, tài chính – thuế, quản lý và sử dụng vốn nhà nước, một số lĩnh vực chuyên môn (như khoa học công nghệ). Nguồn: Bộ KH&ĐT.

⁴ Nguồn: “Báo cáo Tổng kết thi hành Luật đầu tư 2005”- Bộ KH&ĐT, tháng 3/2014, trang 1-6.

⁵ Nguồn số liệu: Cục ĐTNN www.fia.mpi.gov.vn

Thứ hai, Luật Đầu tư đã góp phần thiết lập môi trường pháp lý bình đẳng cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế, phù hợp với thông lệ và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Theo đó, Luật bảo đảm quyền của nhà đầu tư trong việc tiếp cận bình đẳng cơ hội đầu tư và các nguồn lực đầu tư (như tín dụng, ngoại tệ, đất đai, tài nguyên...); tiếp cận các thông tin về luật pháp, chính sách, các dữ liệu cơ bản của nền kinh tế quốc dân; khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi phạm pháp của các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước theo quy định của pháp luật....

Những quy định nêu trên thể hiện quyết tâm rất lớn của Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng môi trường đầu tư không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư được quy định phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế; các rào cản đầu tư có tính chất phân biệt đối xử không phù hợp với Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs) đã bị bãi bỏ (như yêu cầu bắt buộc nhà đầu tư phải xuất khẩu sản phẩm, sử dụng nguyên liệu hàng hóa trong nước, cân đối xuất nhập khẩu, cân đối ngoại tệ...). Những quy định này (được nghiên cứu sửa đổi ngay trong quá trình soạn thảo Luật) đã tạo điều kiện để Việt Nam thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập WTO và là tiền đề để tiếp tục tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào các hiệp định đầu tư, thương mại song phương và đa phương trong thời gian qua; qua đó, góp phần củng cố hơn nữa niềm tin của các nhà đầu tư ngoài vào sức hấp dẫn và cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam.

Thứ ba, Luật Đầu tư đã góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ chế bảo hộ đầu tư theo hướng Nhà nước cam kết thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm bảo hộ mọi loại tài sản hợp pháp của nhà đầu tư, kể cả quyền sở hữu trí tuệ; cam kết không quốc hữu hóa, trưng thu tài sản của nhà đầu tư một cách trực tiếp hay gián tiếp, trừ trường hợp vì mục đích công cộng, theo thủ tục luật định và bồi thường một cách thỏa đáng, công bằng; cho phép nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài vốn, lợi nhuận và mọi khoản thu nhập hợp pháp khác. Về cơ bản, những cam kết nêu trên là phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như những cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế và được nhà đầu tư hoan nghênh, đánh giá cao.

Thứ tư, Luật Đầu tư đã tạo cơ sở pháp lý cho việc cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư theo hướng áp dụng phổ biến chế độ đăng ký thay cho chế độ cấp phép, xóa bỏ những quy định xin-cho, phê duyệt bất hợp lý nhằm nâng cao vai trò chủ động, tự chịu trách nhiệm của nhà đầu tư trong quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể, Luật đã áp dụng thủ tục đăng ký đầu tư đơn giản đối với nhiều dự án, đồng thời thực hiện thống nhất thủ tục thẩm tra cho cả dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ VND trở lên và/hoặc dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Những quy định về thủ tục triển khai thực hiện dự án đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng được đơn giản hóa theo hướng bãi bỏ nhiều thủ tục mang tính phê duyệt đã được quy định trước đây (như thủ tục tăng vốn, chuyển nhượng vốn, điều chỉnh dự án...). Mặc dù việc thực hiện các quy định nêu trên còn một số hạn chế, cần được tiếp tục cải thiện hơn nữa, song nhìn chung, các quy định của Luật Đầu tư về vấn đề này đã góp phần cải thiện đáng kể thủ tục đầu tư, nhất là các thủ tục áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ năm, Luật Đầu tư đã góp phần đổi mới vai trò và chức năng của nhà nước trong quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh theo hướng giảm, tiến tới loại bỏ sự can thiệp hành chính không cần thiết, đồng thời tăng cường vai trò cũng như năng lực của nhà nước trong việc tạo điều kiện để thị trường phát triển và hoạt động hiệu quả. Theo đó, Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư phát triển, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và giải quyết những vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư. Đặc biệt, căn cứ quy định của Luật đầu tư 2014, Chính phủ đã thực hiện phân cấp mạnh mẽ, triệt để trong hoạt động cấp Giấy chứng nhận đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư cho các địa phương. Mặc dù còn một số hạn chế cần được tiếp tục hoàn thiện, song về cơ bản cơ chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư đã được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động các cơ quan quản lý ở địa phương trong toàn bộ quá trình quản lý hoạt động đầu tư, từ tổ chức xây dựng danh mục dự án, xúc tiến đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến kiểm tra, giám sát thực hiện dự án đầu tư.

Thực tiễn quá trình thi hành Luật Đầu tư 2005 nêu trên cho thấy yêu cầu cấp bách phải sửa đổi Luật nhằm:

a) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, minh bạch hơn nữa để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp nói riêng.

b) Tạo bước chuyển biến mới về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư; giải quyết những khó khăn trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt là những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư.

c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trên cơ sở hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý hoạt động đầu tư và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện công tác này.

d) Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để củng cố, tăng cường cơ chế khuyến khích, bảo hộ đầu tư nước ngoài nhằm tạo môi trường có sức hấp dẫn, cạnh tranh thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Để thực hiện những mục tiêu, quan điểm nêu trên, việc xây dựng Luật đầu tư 2015 phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây:

a) Đảm bảo kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy định thông thoáng của Luật còn phù hợp với thực tế và đã có tác động tích cực đối với môi trường đầu tư, đồng thời xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định đã phát sinh hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là các quy định về điều kiện, thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư.

b) Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về đầu tư theo hướng phân định rõ mối quan hệ và nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư, các luật liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

c) Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, nhưng phải đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường chế độ kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương.

d) Đảm bảo thực hiện cam kết mở cửa thị trường và tự do hóa đầu tư theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Luật Đầu tư 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Luật Đầu tư 2014 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.⁶ Về đối tượng áp dụng, Luật Đầu tư 2014 áp dụng đối với nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.⁷

2.1.1. Áp dụng Luật đầu tư, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

Hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật đầu tư 2014 và luật khác có liên quan. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật đầu tư và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật đầu tư, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật đầu tư thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. Đối với hợp đồng trong đó có ít nhất một bên tham gia là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư, các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng việc áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán đầu tư quốc tế nếu thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

2.1.2. Chính sách về đầu tư kinh doanh

- Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật đầu tư 2014 không cấm.

- Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật.

⁶ Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

⁷ Lưu ý: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

- Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư.

- Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế.

- Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư kinh doanh mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.1.3. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

(i) Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật đầu tư 2014;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật đầu tư 2014;

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật đầu tư 2014;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

(ii) Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản (i) này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2.1.4. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

(i) Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

(ii) Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư 2014.

(iii) Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản (ii) này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

(iv) Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản (i) này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

(v) Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

2.2. BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

2.2.1. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.2.2. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

(i) Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu sau đây:

a) Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước;

b) Xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;

c) Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;

d) Đạt được tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước;

đ) Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;

e) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;

g) Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(ii) Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chính sách quản lý ngoại hối và khả năng cân đối ngoại tệ trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác.

2.2.3. Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

- Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
- Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
- Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

2.2.4. Bảo lãnh của Chính phủ đối với một số dự án quan trọng

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác.

2.2.5. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

(i) Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

(ii) Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

(iii) Quy định tại khoản (ii) này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

(iv) Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản (iii) này thì được xem xét giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

- a) Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;
- b) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;
- c) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

(v) Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản (iv) này, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

2.2.5 Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

(i) Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định tại các khoản (ii), (iii) và (iv).

(ii) Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản (iii).

(iii) Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2014 được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

- a) Tòa án Việt Nam;

- b) Trọng tài Việt Nam;
- c) Trọng tài nước ngoài;
- d) Trọng tài quốc tế;
- đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

(iv) Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2.3. ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

2.3.1. Ưu đãi đầu tư

2.3.1.1. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

(i) Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

(ii) Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật đầu tư 2014;

b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật đầu tư 2014;

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

(iii) Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.

(iv) Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản (ii) này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa,

dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

2.3.1.2. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

(i) Ngành, nghề ưu đãi đầu tư:

a) Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; hoạt động nghiên cứu và phát triển;

b) Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

c) Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;

d) Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày và các sản phẩm quy định tại điểm c khoản này;

đ) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;

e) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;

g) Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;

h) Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;

i) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp;

k) Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới;

l) Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

m) Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;

n) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

(ii) Địa bàn ưu đãi đầu tư:

a) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2.3.1.3. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

(i) Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(ii) Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật đầu tư 2014, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

2.3.1.4. Mở rộng ưu đãi đầu tư

Chính phủ trình Quốc hội quyết định áp dụng các ưu đãi đầu tư khác với các ưu đãi đầu tư được quy định trong Luật đầu tư 2014 và các luật khác trong trường hợp cần khuyến khích phát triển một ngành đặc biệt quan trọng hoặc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

2.3.2. Hỗ trợ đầu tư

2.3.2.1. Hình thức hỗ trợ đầu tư

(i) Các hình thức hỗ trợ đầu tư:

- a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án;
- b) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;
- c) Hỗ trợ tín dụng;
- d) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị;
- đ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;
- e) Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;
- g) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

(ii) Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư quy định tại khoản (i) này đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.⁸

2.3.2.2. Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế⁹

⁸ Xem hướng dẫn về vấn đề này tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

⁹ Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các khu chức năng thuộc khu kinh tế.

Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách và vốn tín dụng ưu đãi để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách, vốn tín dụng ưu đãi và áp dụng các phương thức huy động vốn khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

2.3.2.3. Phát triển nhà ở và công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch và bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đối với các địa phương gặp khó khăn trong bố trí quỹ đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp để dành một phần diện tích đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng.

2.4. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

2.4.1. Hình thức đầu tư

2.4.1.1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.¹⁰ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật đầu tư 2014 và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:¹¹

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định;¹²

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.

Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

¹⁰ Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh

¹¹ Khoản 1 Điều 22 Luật đầu tư 2014.

¹² Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định trên, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.

2.4.1.2. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài¹³

(i) Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:¹⁴

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

(ii) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản (i) này thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

(iii) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

2.4.1.3. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

2.4.1.3.1. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

¹³ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Xem thêm hướng dẫn chi tiết về vấn đề này tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2014.

¹⁴Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư 2014. Lưu ý: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế

(i) Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

- a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
- b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
- c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

(ii) Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

- a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
- b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
- c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
- d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

(iii) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản (i) và (ii) này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật đầu tư 2014.

2.4.1.3.2. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

(i) Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2014 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

(ii) Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

(ii) Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản (ii) này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

b) Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật đầu tư 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

(iv) Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản (i) này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản (iii) này.

2.4.1.4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP¹⁵

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

2.4.1.5. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật đầu tư 2014. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây:¹⁶

a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

¹⁵ Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là hợp đồng PPP) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 27 của Luật đầu tư. Xem thêm hướng dẫn chi tiết về PPP tại Nghị định 25/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

¹⁶ Điều 29 Luật đầu tư 2014

Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

2.4.2. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

2.4.2.1. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

2.4.2.1.1. Thẩm quyền:

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

(i) Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

a) Nhà máy điện hạt nhân;

b) Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên;

(ii) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;

(iii) Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

(iv) Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2.4.2.1.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

(i) Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.¹⁷

(ii) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

(iii) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đầu tư 2014 và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ.

(iv) Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.¹⁸

¹⁷ Hồ sơ bao gồm: a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư 2014; b) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); c) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường; d) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; đ) Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

(v) Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra; giải trình về những vấn đề thuộc nội dung dự án khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội yêu cầu.

(vi) Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư¹⁹

2.4.2.2. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

2.4.2.2.1. Thẩm quyền:

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật đầu tư 2014, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

(i) Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

b) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;

c) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;

d) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí;

đ) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino;

e) Sản xuất thuốc lá điếu;

g) Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế;

h) Xây dựng và kinh doanh sân golf;

(ii) Dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản (i) này có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;

(iii) Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;

¹⁸ Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư gồm: a) Tờ trình của Chính phủ; b) Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định; c) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; d) Tài liệu khác có liên quan.

(vi) Nội dung thẩm tra: a) Việc đáp ứng tiêu chí xác định dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; b) Sự cần thiết thực hiện dự án; c) Sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên khác; d) Mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp bảo vệ môi trường; đ) Vốn đầu tư, phương án huy động vốn; e) Tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội; g) Cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).

¹⁹ Gồm các nội dung sau đây: a) Nhà đầu tư thực hiện dự án; b) Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, thời hạn thực hiện dự án; c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; d) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án; trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn; đ) Công nghệ áp dụng; e) Cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có); g) Thời hạn hiệu lực của Nghị quyết về chủ trương đầu tư.

(iv) Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

2.4.2.2.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

(i) Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.²⁰

(ii) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại khoản (i) này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đầu tư 2014.

(iii) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, gửi cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(iv) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(v) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quy định tại khoản (iv) này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đầu tư 2014, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

(vi) Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại khoản 8 Điều 33 của Luật đầu tư 2014.

2.4.2.3. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2.4.2.3.1. Thẩm quyền:

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật đầu tư 2014, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;²¹

b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

2.4.2.3.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

²⁰ Hồ sơ gồm: a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư 2014; b) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); c) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường; d) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.

²¹ Lưu ý: Dự án đầu tư quy định thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

(i) Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư 2014 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

(ii) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản (i) này cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

(iii) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung quy định tại khoản (vi) này.

(iv) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

(v) Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

(vi) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định gồm:

a) Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;

- b) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
 - c) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
 - d) Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
 - đ) Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 - e) Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư 2014.
- (vii) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.²²

2.4.3. Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.4.3.1. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- (i) Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 - a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 - b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2014.
- (ii) Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 - a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 - b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật đầu tư 2014;
 - c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
- (iii) Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật đầu tư 2014 thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.
- (iv) Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản (ii) này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật đầu tư 2014.

²² Nội dung quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm: a) Nhà đầu tư thực hiện dự án; b) Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, thời hạn thực hiện dự án; c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; d) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn; đ) Công nghệ áp dụng; e) Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có); g) Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư. Xem thêm hướng dẫn chi tiết về vấn đề này tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

2.4.3.2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(i) Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật đầu tư 2014, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

(ii) Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư 2014 cho cơ quan đăng ký đầu tư;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

2.4.3.3. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư²³

(i) Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

(ii) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản (iii) này.

(iii) Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

2.4.3.4. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.²⁴

²³ Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 1. Mã số dự án đầu tư; 2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; 3. Tên dự án đầu tư; 4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; 5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; 6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; 7. Thời hạn hoạt động của dự án; 8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn; 9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có); 10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

²⁴ Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; c) Quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.4.3.5. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định khoản 1 Điều 48 của Luật đầu tư 2014.²⁵

2.4.4. Triển khai thực hiện dự án đầu tư

2.4.4.1. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư²⁶

Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể.

Khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

2.4.4.2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

2.4.4.3. Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ

định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư; d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư 2014 liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

²⁵ Xem hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

²⁶ Xem hướng dẫn tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ hoặc để xác định căn cứ tính thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện giám định độc lập chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.

2.4.4.4. Chuyển nhượng dự án đầu tư

(i) Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật đầu tư 2014;

b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

(ii) Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư 2014 kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

2.4.4.5. Giảm tiến độ đầu tư

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giảm tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.

Nội dung đề xuất giảm tiến độ:

a) Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giảm tiến độ;

b) Giải trình lý do và thời hạn giảm tiến độ thực hiện dự án;

c) Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

d) Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

Tổng thời gian giảm tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giảm tiến độ đầu tư.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

2.4.4.6. Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

- a) Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa;
- b) Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường;
- c) Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;
- d) Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài;
- đ) Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.4.4.7. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

(i) Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

- a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
- b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
- c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
- d) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật đầu tư 2014 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
- đ) Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

e) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật đầu tư 2014;

h) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

(ii) Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản (i) này.

(iii) Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

(iv) Trừ trường hợp được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất.

2.4.4.8. Thành lập, chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC quyết định theo yêu cầu thực hiện hợp đồng. Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành.²⁷ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành.²⁸ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

²⁷ Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành: a) Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành; b) Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành; c) Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành; d) Bản sao hợp đồng BCC.

²⁸ Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành: a) Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn; b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; c) Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết; d) Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế; đ) Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội; e) Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu; g) Giấy chứng

2.5. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Trong giai đoạn 1989-1998, có 18 dự án ĐTRNN với tổng vốn đăng ký trên 13,6 triệu USD; quy mô vốn đầu tư bình quân đạt 0,76 triệu USD/dự án. Giai đoạn từ 1999 đến 6/2006, việc đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam đã được quy định tại Nghị định số 22/1999/NĐ-CP ngày 14/9/1999. Trong thời kỳ 1999-2005 sau khi ban hành Nghị định số 22/1999/NĐ-CP, có 131 dự án ĐTRNN với tổng vốn đăng ký đạt 731,4 triệu USD, gấp 7 lần về số dự án và gấp 53 lần về tổng vốn đầu tư đăng ký so với thời kỳ 1989-1998; quy mô vốn đầu tư bình quân đạt 5,58 triệu USD/dự án, cao hơn giai đoạn 1989-1998. Theo thống kê, tính đến hết năm 2005, đã có 150 dự án, với tổng số vốn hơn 620 triệu USD đã được các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Điều này thể hiện sự trưởng thành và không ngừng lớn mạnh của các nhà đầu tư Việt Nam trong xu hướng hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).²⁹

Trên cơ sở các quy định của Luật Đầu tư 2005, ngày 9/8/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2006/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thay thế cho các quy định tại Nghị định 22/1999/NĐ-CP.³⁰ Tính lũy kế đến 31/12/2014 đã có 930 dự án ĐTRNN với tổng vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư Việt Nam là 14,85 tỷ USD, điều chỉnh tăng vốn cho 92 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 4,93 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký (cả cấp mới và tăng thêm) là 19,78 tỷ USD. Riêng trong năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 153 hồ sơ dự án ĐTRNN, đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 109 dự án đầu tư sang 28 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký phía Việt Nam trên 1,047 tỷ đô la Mỹ và điều chỉnh GCNĐT cho 22 dự án với tổng vốn tăng thêm đạt 739 triệu USD. Tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài (gồm cả cấp mới và tăng vốn) đạt trên 1,786 tỷ USD.

Tính lũy kế đến tháng 4/2015, Việt Nam đã có 962 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 15 tỷ USD. Ngoài ra, còn có 115 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 5 tỷ USD. Như vậy, tính cả vốn cấp mới và vốn tăng thêm tính đến nay là 20 tỷ USD. Thị trường đầu tư ra nước ngoài vẫn tập trung nhiều tại một số thị trường truyền thống như Lào (có 259 dự án với 3,9 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư, chiếm 27% tổng số dự án và 26% tổng vốn đăng ký đầu tư), Campuchia (có 171 dự án và 3,2 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư, chiếm 18% tổng số dự án và 22% tổng vốn đăng ký đầu tư). Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đầu tư sang Liên bang Nga 18 dự án với tổng vốn đầu tư là 968 triệu USD, 2 dự án sang Venezuela với tổng vốn đầu tư là 1,8 tỷ USD và 6 dự án sang Peru với tổng vốn đầu tư là 1,3 tỷ USD tổng vốn đầu tư. Như vậy, có thể thấy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam gần đây không chỉ tăng trưởng nhanh chóng ở các thị trường truyền thống, mà còn mở rộng sang các quốc gia khác. Một số thị trường khác cũng tập trung nhiều vốn như An-giê-ri,

nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành; h) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; i) Bản sao hợp đồng BCC.

²⁹ Lũy kế đến thời điểm 30/12/2011: Có 627 dự án đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam đăng ký đạt 10,8 tỷ USD tại 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung chủ yếu tại Lào (3,4 tỷ USD), Campuchia (2,1 tỷ USD), Venezuela (1,8 tỷ USD), Nga (776 triệu USD), Peru (508 triệu USD), Malaysia (412 triệu USD), Mozambique (345 triệu USD)... Vốn thực hiện lũy kế đến nay ước đạt khoảng 2,7 tỷ USD; trong đó khoảng 1,4 tỷ USD trong lĩnh vực dầu khí; Lào đạt khoảng 480 triệu USD; Campuchia đạt khoảng trên 200 triệu USD... (Nguồn: Cục ĐTN <http://fia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&aID=1127>)

³⁰ Nguồn: Cục ĐTN, chi tiết xem tại:

<http://fia.mpi.gov.vn/Default.aspx?ctl=Article2&TabID=4&mID=238&aID=537>

Malaysia, Myanmar, Hoa Kỳ... Về lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam tập trung đầu tư vào ngành khai khoáng là nhiều nhất (111 dự án và 5,1 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 11,5% tổng số dự án và 34% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là ngành nông, lâm, ngư nghiệp (125 dự án và 2,7 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 13% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư). Đây là những lĩnh vực đầu tư mà Việt Nam có thế mạnh, tuy nhiên, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam còn đầu tư sang nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác như thông tin, truyền thông, sản xuất điện, bất động sản, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...³¹

Trên cơ sở quy định của Luật đầu tư 2014, ngày 25/9/2015 Chính phủ ban hành Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài thay thế cho Nghị định 78/2006/NĐ-CP.

2.5.1. Những quy định chung về đầu tư ra nước ngoài

2.5.1.1. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật đầu tư 2014, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

2.5.1.2. Hình thức đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

- a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
- b) Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;
- c) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;
- d) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
- đ) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

2.5.1.3. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn và huy động các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài. Việc vay vốn bằng ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải tuân thủ điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật về ngân hàng, về các tổ chức tín dụng, về quản lý ngoại hối.

³¹ Nguồn: Cục ĐTNN. Chi tiết xem tại <http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/2573/Tinh-hinh-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-cua-Viet-Nam-trong-nam-2014>

Căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ, chính sách quản lý ngoại hối trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cho nhà đầu tư vay vốn bằng ngoại tệ theo quy định trên để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

2.5.2. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

2.5.2.1. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

(i) Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

- a) Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;
- b) Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

(ii) Hồ sơ, trình tự, thủ tục Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật đầu tư 2014 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật đầu tư 2014.

Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.³²

Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư ra nước ngoài bao gồm các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 55 của Luật đầu tư 2014.

2.5.2.2. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

(i) Thẩm quyền:

Trừ các trường hợp Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

b) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

(ii) Hồ sơ, trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.³³ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy

³² Hồ sơ gồm: a) Tờ trình của Chính phủ; b) Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật đầu tư 2014; c) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; d) Tài liệu khác có liên quan.

ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.³⁴

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, gồm các nội dung sau đây:

- a) Nhà đầu tư thực hiện dự án;
- b) Mục tiêu, địa điểm đầu tư;
- c) Vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tiến độ góp vốn, huy động vốn và tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài;
- d) Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

2.5.3. Thủ tục cấp, điều chỉnh và chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

2.5.3.1. Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài

(i) Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

(ii) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại khoản (i) này do nhà đầu tư quyết định theo quy định của Luật đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(iii) Nhà đầu tư và cơ quan đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản (i) và (ii) này chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư ra nước ngoài.

2.5.3.2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

³³ Hồ sơ gồm: a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài; b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; c) Đề xuất dự án đầu tư gồm: mục tiêu, quy mô, hình thức, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án; d) Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; đ) Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư; e) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật đầu tư 2014; g) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

³⁴ Báo cáo thẩm định gồm các nội dung sau đây: a) Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 58 của Luật đầu tư 2014; b) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư; c) Sự cần thiết thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài; d) Sự phù hợp của dự án với quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật đầu tư 2014; đ) Những nội dung cơ bản của dự án: quy mô, hình thức đầu tư, địa điểm, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án, vốn đầu tư, nguồn vốn; e) Đánh giá mức độ rủi ro tại quốc gia đầu tư.

(i) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật đầu tư 2014.

(ii) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật đầu tư 2014.

(iii) Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật đầu tư 2014 thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(iv) Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật đầu tư 2014.

(v) Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

2.5.3.3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài³⁵

(i) Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

(ii) Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản (i) này, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.³⁶

(iii) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản (i) này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.³⁷

³⁵ Xem hướng dẫn chi tiết về vấn đề này tại Nghị định 83/2015/NĐ-CP.

³⁶ Hồ sơ gồm:

- a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
- b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- c) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật đầu tư 2014;
- d) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật đầu tư 2014;
- đ) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

³⁷ Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

- 1. Mã số dự án đầu tư.
- 2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
- 3. Tên dự án đầu tư.
- 4. Mục tiêu, địa điểm đầu tư.
- 5. Vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tiến độ góp vốn, huy động vốn và tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài.
- 6. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư.
- 7. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

2.5.3.4. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.³⁸ Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, khi điều chỉnh các nội dung quy định trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

2.5.3.5. Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Dự án đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

- a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
- b) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
- c) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
- d) Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;
- đ) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai;
- e) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư;

³⁸ Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gồm:

- a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
- b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- c) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
- d) Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật đầu tư 2014;
- đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
- e) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

g) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư;

h) Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

i) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong các trường hợp quy định trên.

2.5.4. Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài

2.5.4.1. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

2.5.4.2. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

(i) Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản (iii);

b) Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;

c) Có tài khoản vốn theo quy định tại Điều 63 của Luật đầu tư 2014.

(ii) Việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(iii) Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để phục vụ cho hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò thị trường và thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư khác theo quy định của Chính phủ.

2.5.4.3. Chuyển lợi nhuận về nước

(i) Trừ trường hợp sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điều 66 của Luật đầu tư 2014, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam.

(ii) Trong thời hạn quy định tại khoản (i) này mà chưa chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập khác về Việt Nam, nhà đầu tư phải có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn chuyển lợi nhuận về nước được gia hạn không quá hai lần, mỗi lần không quá 06 tháng và phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

2.5.4.4. Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài

Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó và phải đăng ký tài khoản vốn, tiền độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

3.1. SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA KHUNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

3.1.1. Giai đoạn trước năm 1960

Sau khi hoà bình được lập lại ở miền Bắc vào năm 1954, để tạo khung khổ pháp lý cho sản xuất phát triển, Nhà nước đã ban hành Điều lệ tạm thời số 735/TTg về chế độ hợp đồng kinh doanh.¹ Đây là văn bản đầu tiên có tên gọi là “hợp đồng kinh doanh” điều chỉnh riêng về hợp đồng với các mối quan hệ giữa hai hay nhiều chủ thể kinh doanh tự nguyện cam kết thực hiện kế hoạch của Nhà nước.

3.1.2. Giai đoạn 1960 - 1989

Giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1975 là giai đoạn của Điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh và cơ quan nhà nước (Nghị định số 04/TTg năm 1960). Sau 15 năm thi hành điều lệ tạm thời theo Nghị định số 04/TTg, ngày 10/3/1975, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 54/CP ban hành Điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế.² Đây là bản điều lệ chính thức đầu tiên về chế độ hợp đồng kinh tế của nước ta và có hiệu lực thi hành đến năm 1989. Cùng với việc ban hành Nghị định số 54/CP, Nhà nước ban hành hàng loạt văn bản hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng kinh tế. Hai bản điều lệ này điều chỉnh về chế độ hợp đồng kinh tế trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp, thực hiện theo chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.1.3. Giai đoạn từ năm 1989 đến ngày 31/12/2005

Ngày 25/9/1989, Hội đồng Nhà nước đã thông qua Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế để điều chỉnh các quan hệ hợp đồng kinh tế trong cơ chế mới.³ Các văn bản được ban hành sau đó như Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-1-1990, Quyết định số 18/HĐBT ngày 16-1-1990 và nhiều văn bản hướng dẫn khác của các cơ quan có liên quan hình thành nên một hệ thống pháp luật về hợp đồng kinh tế.⁴

3.1.4. Từ ngày 01/01/2006 đến hết năm 2016

Tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XI đã thông qua Bộ luật Dân sự năm 2005 (777 điều) thay thế cho Bộ luật Dân sự năm 1995 (838 điều). Theo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 của Quốc hội, từ ngày 01-01-2006, các quy định tại Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm sẽ hết hiệu lực, các quy định về hợp đồng sẽ tuân thủ theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005. Với việc ban hành Bộ luật Dân sự năm 2005, các quy định về hợp đồng dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2005 sẽ điều chỉnh chung cho các quan hệ về hợp đồng giữa các pháp nhân, cá nhân với nhau và thống nhất các quan hệ về hợp đồng.⁵

² Công báo số 10 ngày 5-5-1956, tr. 88-91.

³ Công báo số 3 ngày 15-3-1975, tr. 34-39.

⁴ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế có hiệu lực thi hành từ 25-9-1989.

⁵ Lưu ý: Các quy định về Hợp đồng dân sự được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự 1995; Hợp đồng trong lĩnh vực thương mại được điều chỉnh bởi Luật thương mại 1997; Luật thương mại 2005.

⁶ Xem thêm bình luận về vấn đề này tại Lê Minh Toàn (chủ biên), *Luật kinh doanh Việt Nam* (2 tập), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2009.

3.1.4. Từ 1/1/2017

Ngày 24/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự 2015 thay thế cho Bộ luật dân sự 2005 và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017. Theo đó, các quy định về Hợp đồng được điều chỉnh tại Bộ luật dân sự 2015, từ Điều 365-568.

3.2. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

3.2.1. Khái niệm hợp đồng

Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

3.2.2. Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng.

Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh.

3.2.3. Thông tin trong giao kết hợp đồng

- Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết.

- Trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác.

Bên vi phạm quy định trên mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3.2.3. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như sau:

a) Do bên đề nghị ấn định;

b) Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật khác có quy định khác.

Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng:

a) Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân;

b) Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị;

c) Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác.

3.2.4. Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị;

b) Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh.

Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đó là đề nghị mới.

3.2.5. Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng

Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể huỷ bỏ đề nghị nếu bên được đề nghị nhận được thông báo về việc huỷ bỏ đề nghị trước khi người này gửi thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Đề nghị giao kết hợp đồng không thể bị huỷ bỏ trong các trường hợp sau đây:

a) Đề nghị giao kết hợp đồng nêu rõ về việc không thể huỷ bỏ đề nghị;

b) Đề nghị giao kết hợp đồng nêu rõ thời hạn trả lời.

3.2.6. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng;
- Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận;
- Hết thời hạn trả lời chấp nhận;
- Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;
- Khi thông báo về việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực;
- Theo thoả thuận của bên đề nghị và bên nhận được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

3.2.7. Sửa đổi đề nghị do bên được đề nghị đề xuất

Bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng, nhưng có nêu điều kiện hoặc sửa đổi đề nghị thì coi như người này đã đưa ra đề nghị mới.

3.2.8. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.

Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên.

3.2.9. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng

Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời

khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời. Khi bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý.

Trong trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị.

Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn trả lời.

3.2.10. Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự

Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề nghị giao kết hợp đồng.

3.2.11. Trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự

Trường hợp bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng sau đó chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì việc trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên được đề nghị giao kết hợp đồng.

3.2.12. Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng

Bên được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng, nếu thông báo về việc rút lại này đến trước hoặc cùng với thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng.

3.2.13. Nội dung của hợp đồng

Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

- a) Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm;
- b) Số lượng, chất lượng;
- c) Giá, phương thức thanh toán;
- d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
- đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;
- e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
- g) Phương thức giải quyết tranh chấp.

3.2.14. Địa điểm giao kết hợp đồng

Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.

3.2.15. Thời điểm giao kết hợp đồng

Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn trả lời giao kết.

Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.⁶

Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

3.2.16. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật khác có quy định khác.

Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

3.2.17. Các loại hợp đồng chủ yếu

Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây:

- Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau;
- Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ;
- Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ;
- Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính;
- Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó;
- Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

3.2.18. Phụ lục hợp đồng

Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

⁶ Trong trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng được xác định theo này.

Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

3.2.19. Hợp đồng theo mẫu

(i) Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra.

Hợp đồng theo mẫu phải được công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về những nội dung của hợp đồng. Trình tự, thể thức công khai hợp đồng theo mẫu thực hiện theo quy định của pháp luật.

(ii) Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó.

(iii) Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi của bên kia thì điều khoản này không có hiệu lực.

Quy định tại khoản (ii), (iii) cũng được áp dụng cho điều khoản không đàm phán trong trường hợp hợp đồng có cả điều khoản có đàm phán và điều khoản không đàm phán.

3.2.20. Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng

Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng; nếu bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng thì coi như chấp nhận các điều khoản này.

Điều kiện giao dịch chung chỉ có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trong trường hợp điều kiện giao dịch này đã được công khai để bên xác lập giao dịch biết hoặc phải biết về điều kiện đó. Trình tự, thể thức công khai điều kiện giao dịch chung thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên. Trường hợp điều kiện giao dịch chung có quy định về miễn trách nhiệm của bên đưa ra điều kiện giao dịch chung, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi của bên kia thì quy định này không có hiệu lực.

3.2.21. Hợp đồng vô hiệu

Các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 123 đến Điều 133 của Bộ luật dân sự 2015 cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu.

Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này không áp dụng đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp

các bên thoả thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính.

3.2.22. Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

Trong trường hợp ngay từ khi giao kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được thì hợp đồng này bị vô hiệu.

Trong trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được, nhưng không thông báo cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được. Quy định này cũng được áp dụng đối với trường hợp hợp đồng có một hoặc nhiều phần đối tượng không thể thực hiện được, nhưng phần còn lại của hợp đồng vẫn có giá trị.

3.3. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

3.3.1. Thực hiện hợp đồng đơn vụ

Đối với hợp đồng đơn vụ, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thoả thuận; chỉ được thực hiện trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý.

3.3.2. Thực hiện hợp đồng song vụ

Trong hợp đồng song vụ, khi các bên đã thoả thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 410 và Điều 412 của Bộ luật dân sự 2015.

Trường hợp các bên không thoả thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.

3.3.3. Quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ

Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Bên phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn.

3.3.4. Cầm giữ tài sản trong hợp đồng song vụ

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền xác lập quyền cầm giữ tài sản đối với tài sản của bên có nghĩa vụ theo quy định từ Điều 346 đến Điều 350 của Bộ luật dân sự.

3.3.5. Nghĩa vụ không thể thực hiện được do lỗi của bên có quyền

Trong hợp đồng song vụ, khi một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên kia thì có quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.3.6. Không thực hiện được nghĩa vụ nhưng không do lỗi của các bên

Trong hợp đồng song vụ, nếu một bên không thực hiện được nghĩa vụ mà các bên đều không có lỗi thì bên không thực hiện được nghĩa vụ không có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Trường hợp một bên đã thực hiện được một phần nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện phần nghĩa vụ tương ứng đối với mình.

3.3.7. Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Khi thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các bên có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thì người thứ ba không có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết. Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

3.3.8. Quyền từ chối của người thứ ba

Trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình trước khi bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ, nhưng phải thông báo cho bên có quyền và hợp đồng được coi là bị huỷ bỏ, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình sau khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được xem là đã hoàn thành và bên có quyền vẫn phải thực hiện cam kết đối với bên có nghĩa vụ. Trong trường hợp này, lợi ích phát sinh từ hợp đồng thuộc về bên mà nếu hợp đồng không vì lợi ích của người thứ ba thì họ là người thụ hưởng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3.3.9. Không được sửa đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Khi người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích thì dù hợp đồng chưa được thực hiện, các bên giao kết hợp đồng cũng không được sửa đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng, trừ trường hợp được người thứ ba đồng ý.

3.3.10. Thỏa thuận phạt vi phạm

Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận.

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải nộp phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp các bên không có thỏa thuận về việc kết hợp phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

Một bên có thể yêu cầu Tòa án giảm bớt mức phạt vi phạm nếu chứng minh được rằng mức phạt là quá cao so với hậu quả mà bên bị vi phạm phải gánh chịu.

3.3.11. Thiệt hại được bồi thường do không thực hiện đúng hợp đồng

(i) Thiệt hại được bồi thường do không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định theo quy định tại Điều 360 của Bộ luật dân sự 2015 và khoản (ii).

(ii) Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả các khoản chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

(iii) Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc bên có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho bên có quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc.

3.3.12. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

(i) Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;

b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh;

c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;

d) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;

đ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.

(ii) Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

(iii) Trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án:

a) Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định;

b) Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.

(iv) Trong quá trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải quyết vụ việc, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3.4. SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

3.4.1. Sửa đổi hợp đồng

Các bên có thể thoả thuận sửa đổi hợp đồng. Hợp đồng có thể được sửa đổi theo quy định tại Điều 419 của Bộ luật dân sự. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.

3.4.2. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Hợp đồng đã được hoàn thành;
- Theo thoả thuận của các bên;
- Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
- Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
- Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
- Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 419 của Bộ luật dân sự 2015;
- Các trường hợp chấm dứt hợp đồng khác do luật định.

3.4.3. Huỷ bỏ hợp đồng

Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng,⁷ trừ trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3.4.4. Huỷ bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ

(i) Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có quyền có thể huỷ bỏ hợp đồng.

Trường hợp do tính chất của hợp đồng hoặc do ý chí của các bên, hợp đồng sẽ không đạt được mục đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời hạn đó bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền huỷ hợp đồng mà không phải tuân theo quy định tại khoản (i) này.

3.4.5. Huỷ bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có thể huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu có.

3.4.6. Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng

⁷ Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

Trường hợp một bên làm mất, làm hư hỏng tài sản là đối tượng của hợp đồng mà không thể hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc không thể sửa chữa, thay thế bằng tài sản cùng loại thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng.

Bên vi phạm phải bồi thường bằng tiền ngang với giá trị của tài sản bị mất, bị hư hỏng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo quy định tại các điều 351, 362 và 363 của Bộ luật dân sự.

3.4.7. Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng

Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã giao kết, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.

Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi các chi phí hợp lý trong việc thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản. Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả. Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện cùng một thời điểm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.

Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng dịch vụ liên quan đến các quyền nhân thân do Bộ luật dân sự 2015 và luật có liên quan quy định.

Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định tại các điều 422, 423, 424 và 425 của Bộ luật dân sự 2015 thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, luật có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ.

3.4.8. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, luật có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng hợp đồng của bên kia được bồi thường.

3.4.9. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.⁸

3.5. MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG

3.5.1. Hợp đồng mua bán tài sản

3.5.1.1. Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.⁹

3.5.1.2. Đối tượng của hợp đồng mua bán

Tài sản được quy định tại Bộ luật dân sự 2015 đều có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán.¹⁰ Trường hợp theo quy định của luật, tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng thì tài sản bán phải phù hợp với các quy định đó.

Tài sản bán thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán.

3.5.1.3. Chất lượng của tài sản mua bán

Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận.

Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo các tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi các bên không có thỏa thuận, thỏa thuận không rõ ràng về chất lượng tài sản mua bán và các bên cũng không có thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung này thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề.

Trường hợp không có tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng và theo quy định của Luật bảo vệ người tiêu dùng.

3.5.1.4. Giá và phương thức thanh toán

Giá và phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá và phương thức thanh toán phải

⁸ Lưu ý: Trình tự, thủ tục khởi kiện và giải quyết tranh chấp về hợp đồng, xem chi tiết tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

⁹ Hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 và Luật nhà ở.

¹⁰ Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản (Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; Quyền được xác lập đối với bất động sản) và động sản (là những tài sản không phải là bất động sản). Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.

Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá và phương thức thanh toán được xác định theo giá và phương thức thanh toán theo thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

3.5.1.5. Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán

Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý.

Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.

Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

3.5.1.6. Địa điểm giao tài sản

Địa điểm giao tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 276 của Bộ luật dân sự 2015.

3.5.1.7. Phương thức giao tài sản

Tài sản được giao theo phương thức do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận về phương thức giao tài sản thì tài sản do bên bán giao một lần, giao trực tiếp cho bên mua.

Trường hợp theo thỏa thuận, bên bán giao tài sản cho bên mua thành nhiều lần mà bên bán thực hiện không đúng nghĩa vụ ở một lần nhất định thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến lần vi phạm đó; nếu việc vi phạm này làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng thì bên mua có thể hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.5.1.8. Trách nhiệm do giao tài sản không đúng số lượng

Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì phải thanh toán đối với phần dôi ra theo giá được thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

- a) Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại;
- b) Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu;
- c) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc vi phạm làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.

3.5.1.9. Trách nhiệm do giao vật không đồng bộ

Trường hợp vật được giao không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

- a) Nhận và yêu cầu bên bán giao tiếp phần hoặc bộ phận còn thiếu, yêu cầu bồi thường thiệt hại và hoàn thanh toán phần hoặc bộ phận đã nhận cho đến khi vật được giao đồng bộ;
- b) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên mua đã trả tiền nhưng chưa nhận vật do giao không đồng bộ thì được trả lại đối với số tiền đã trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do giao vật không đồng bộ, kể từ thời điểm phải thực hiện hợp đồng cho đến khi vật được giao đồng bộ.

3.5.1.10. Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại

Trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

- Nhận và thanh toán theo giá do các bên thỏa thuận;
- Yêu cầu giao đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại;
- Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không đúng chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.

Trường hợp tài sản gồm nhiều chủng loại mà bên bán không giao đúng với thỏa thuận đối với một hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến loại tài sản đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.5.1.11. Nghĩa vụ trả tiền

Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự 2015.

3.5.1.12. Thời điểm chịu rủi ro

Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, còn bên mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký và giao tài sản

cho bên mua, bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký và nhận tài sản từ bên bán, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

3.5.1.13. Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu

Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Trường hợp các bên không có thoả thuận, thoả thuận không rõ ràng thì chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu được xác định theo chi phí đã được công bố, quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề.

Trường hợp không có căn cứ xác định theo quy định trên thì chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết **hợp đồng**.

Trường hợp các bên không có thoả thuận và pháp luật không quy định về chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu thì bên bán phải chịu chi phí vận chuyển đến địa điểm giao tài sản và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu.

3.5.1.14. Nghĩa vụ cung cấp thông tin và hướng dẫn cách sử dụng

Bên bán có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin cần thiết về tài sản mua bán và hướng dẫn cách sử dụng tài sản đó; nếu bên bán không thực hiện nghĩa vụ này thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán phải thực hiện trong một thời hạn hợp lý; nếu bên bán vẫn không thực hiện thì bên mua có quyền **hủy bỏ hợp đồng** và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.5.1.15. Bảo đảm quyền sở hữu của bên mua đối với tài sản mua bán

Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đã bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp.

Trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua; nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền **hủy bỏ hợp đồng** và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên mua biết hoặc phải biết tài sản mua bán thuộc sở hữu của người thứ ba mà vẫn mua thì phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu và không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.5.1.16. Bảo đảm chất lượng vật mua bán

Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật, giảm giá và bồi thường thiệt hại, nếu không có thoả thuận khác.

Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hoá hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn.

Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong các trường hợp sau đây:

- a) Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua;
- b) Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ;
- c) Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.

3.5.1.17. Nghĩa vụ bảo hành

Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời hạn bảo hành, nếu việc bảo hành do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật.

3.5.1.18. Quyền yêu cầu bảo hành

Trong thời hạn bảo hành nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

3.5.1.19. Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành

Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết.

Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua.

Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thỏa thuận hoặc trong một thời gian hợp lý; nếu bên bán không thể sửa chữa được hoặc không thể hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

3.5.1.20. Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành

Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành.

Bên bán không phải bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại xảy ra do lỗi của bên mua. Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

3.5.1.21. Mua bán quyền tài sản

Trường hợp mua bán quyền tài sản thì bên bán phải chuyển giấy tờ và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho bên mua, còn bên mua phải trả tiền cho bên bán.

Trường hợp quyền tài sản là quyền đòi nợ và bên bán cam kết bảo đảm khả năng thanh toán của người mắc nợ thì bên bán phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán, nếu khi đến hạn mà người mắc nợ không trả.

Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với quyền tài sản là thời điểm bên mua nhận được giấy tờ xác nhận về quyền sở hữu đối với quyền về tài sản đó hoặc từ thời điểm đăng ký việc chuyển quyền sở hữu, nếu pháp luật có quy định.

3.5.1.22. Bán đấu giá tài sản

Tài sản có thể được đem bán đấu giá theo ý muốn của chủ sở hữu hoặc pháp luật có quy định. Tài sản chung đem bán đấu giá phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Việc bán đấu giá tài sản phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia và được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

3.5.1.23. Mua sau khi sử dụng thử

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua được dùng thử vật mua trong một thời hạn gọi là thời hạn dùng thử. Trong thời hạn dùng thử, bên mua có thể trả lời mua hoặc không mua; nếu hết thời hạn dùng thử mà bên mua không trả lời thì coi như đã chấp nhận mua theo các điều kiện đã thỏa thuận trước khi nhận vật dùng thử. Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về thời hạn dùng thử thì thời hạn này được xác định theo tập quán của giao dịch có đối tượng cùng loại.

Trong thời hạn dùng thử, vật vẫn thuộc sở hữu của bên bán. Bên bán phải chịu mọi rủi ro xảy ra đối với vật, nếu không có thỏa thuận khác. Trong thời hạn dùng thử, bên bán không được bán, tặng cho, cho thuê, trao đổi, thế chấp, cầm cố tài sản khi bên mua chưa trả lời.

Trường hợp bên dùng thử trả lời không mua thì phải trả lại vật cho bên bán và phải bồi thường thiệt hại cho bên bán, nếu làm mất mát, hư hỏng vật dùng thử. Bên dùng thử không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn thông thường do việc dùng thử gây ra và không phải hoàn trả hoa lợi do việc dùng thử mang lại.

3.5.1.24. Mua trả chậm, trả dần

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận tài sản mua; bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng tài sản mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3.5.1.25. Chuộc lại tài sản đã bán

Bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại. Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thỏa thuận; trường hợp không có thỏa thuận thì thời hạn chuộc lại không quá một năm đối với động sản và năm năm đối với bất động sản, kể từ thời điểm giao tài sản. Trong thời hạn này bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua trong một thời gian hợp lý. Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, nếu không có thỏa thuận khác.

Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập giao dịch chuyển quyền sở hữu tài sản cho chủ thể khác và phải chịu rủi ro đối với tài sản, nếu không có thỏa thuận khác.

3.5.2. Hợp đồng vay tài sản

3.5.2.1. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

3.5.2.2. Quyền sở hữu đối với tài sản vay

Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.

3.5.2.3. Nghĩa vụ của bên cho vay

Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.

Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó.

Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 469 của Bộ luật dân sự 2015 hoặc luật có quy định khác.

3.5.2.4. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3.5.2.5. Sử dụng tài sản vay

Các bên có thể thỏa thuận về việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích vay; bên cho vay có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyền đòi lại tài sản vay trước thời hạn, nếu đã nhắc nhở mà bên vay vẫn sử dụng tài sản trái mục đích.

3.5.2.6. Lãi suất

Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất thì lãi suất do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì lãi suất được xác định theo lãi suất

luật định. Trường hợp không có lãi suất luật định thì coi như hợp đồng vay không có lãi, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

3.5.2.7. Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn

Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thỏa thuận khác.

Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý.

3.5.2.8. Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn

Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.

Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, đồng thời có nghĩa vụ trả lãi theo thỏa thuận.

3.5.3. Hợp đồng thuê tài sản

3.5.3.1. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.¹¹

3.5.3.2. Giá thuê

Giá thuê do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

3.5.3.3. Thời hạn thuê

Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

¹¹ Lưu ý: Hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 và Luật nhà ở.

Trường hợp các bên không thoả thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất kỳ khi nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời hạn hợp lý.

3.5.3.4. Cho thuê lại

Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.

3.5.3.5. Giao tài sản thuê

Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm đã thoả thuận và cung cấp những thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó.

Trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thoả thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.5.3.6. Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê

Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thoả thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê:

- a) Sửa chữa tài sản;
- b) Giảm giá thuê;
- c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết.

Trong trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

3.5.3.7. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê

Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.5.3.8. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất mát, hư hỏng thì phải bồi thường. Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự

nhiên do sử dụng tài sản thuê.

Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

3.5.3.9. Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích

Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thoả thuận.

Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.5.3.10. Trả tiền thuê

Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

Trường hợp các bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3.5.3.11. Trả lại tài sản thuê

Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thoả thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.

Trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên cho thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Trường hợp tài sản thuê là gia súc, bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được sinh ra trong thời gian thuê, nếu không có thoả thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.

Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê và trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thoả thuận.

Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

3.5.3.12. Quy định riêng về hợp đồng thuê khoán tài sản

3.5.3.12.1. Khái niệm

Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.

3.5.3.12.2. Đối tượng của hợp đồng thuê khoán

Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, súc vật, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3.5.3.12.3. Thời hạn thuê khoán

Thời hạn thuê khoán do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc có thỏa thuận nhưng không rõ ràng thì thời hạn thuê khoán được xác định theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh phù hợp với tính chất của đối tượng thuê khoán.

3.5.3.12.4. Giá thuê khoán

Giá thuê khoán do các bên thỏa thuận; nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán là giá được xác định theo kết quả đấu thầu.

3.5.3.12.5. Giao tài sản thuê khoán

Khi giao tài sản thuê khoán, các bên phải lập biên bản đánh giá tình trạng của tài sản thuê khoán và xác định giá trị tài sản thuê khoán.

Trường hợp các bên không xác định được giá trị thì mời người thứ ba xác định giá trị và phải lập thành văn bản.

3.5.3.12.6. Trả tiền thuê khoán và phương thức trả

Tiền thuê khoán có thể bằng hiện vật, bằng tiền hoặc bằng việc thực hiện một công việc.

Bên thuê khoán phải trả đủ tiền thuê khoán cho dù không khai thác công dụng tài sản thuê khoán.

Khi giao kết hợp đồng thuê khoán các bên có thể thỏa thuận điều kiện về việc giảm tiền thuê khoán; nếu hoa lợi, lợi tức bị mất ít nhất là một phần ba do sự kiện bất khả kháng thì bên thuê khoán có quyền yêu cầu giảm hoặc miễn tiền thuê khoán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp bên thuê khoán phải trả hiện vật theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác công dụng của tài sản thuê khoán thì phải trả vào thời điểm kết thúc thời vụ hoặc kết thúc chu kỳ khai thác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp bên thuê khoán phải thực hiện một công việc thì phải thực hiện đúng công việc đó.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác về thời hạn trả tiền thuê thì phải thanh toán vào tuần cuối mỗi tháng. Trường hợp thuê khoán theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì phải thanh toán chậm nhất khi kết thúc chu kỳ sản xuất, kinh doanh đó.

3.5.3.12.7. Khai thác tài sản thuê khoán

Bên thuê khoán phải khai thác tài sản thuê khoán đúng mục đích đã thỏa thuận và báo cho bên thuê khoán theo định kỳ về tình trạng tài sản và tình hình khai thác tài sản; nếu bên

cho thuê khoán có yêu cầu hoặc cần báo đột xuất thì bên thuê khoán phải báo kịp thời. Khi bên thuê khoán khai thác công dụng tài sản thuê khoán không đúng mục đích thì bên cho thuê khoán có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.5.3.12.8. Bảo quản, bảo dưỡng, định đoạt tài sản thuê khoán

Trong thời hạn khai thác tài sản thuê khoán, bên thuê khoán phải bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu bên thuê khoán làm mất mát, hư hỏng hoặc làm mất giá trị, giảm sút giá trị tài sản thuê khoán thì phải bồi thường thiệt hại. Bên thuê khoán không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê khoán.

Bên thuê khoán có thể tự mình thay thế, cải tạo tài sản thuê khoán, nếu có thỏa thuận và phải bảo toàn giá trị tài sản thuê khoán. Bên cho thuê khoán phải thanh toán cho bên thuê khoán chi phí hợp lý để thay thế, cải tạo tài sản thuê khoán theo thỏa thuận.

Bên thuê khoán không được cho thuê khoán lại, trừ trường hợp được bên cho thuê khoán đồng ý.

3.5.3.12.9. Hưởng hoa lợi, chịu thiệt hại về súc vật thuê khoán

Trong thời hạn thuê khoán súc vật, bên thuê khoán được hưởng một nửa số súc vật sinh ra và phải chịu một nửa những thiệt hại về súc vật thuê khoán do sự kiện bất khả kháng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3.5.3.12.10. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán

Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý; nếu thuê khoán theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác thì thời hạn báo trước phải phù hợp với thời vụ hoặc chu kỳ khai thác.

Trường hợp bên thuê khoán vi phạm nghĩa vụ, mà việc khai thác đối tượng thuê khoán là nguồn sống duy nhất của bên thuê khoán và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên cho thuê khoán thì bên cho thuê khoán không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bên thuê khoán phải cam kết với bên cho thuê khoán không được tiếp tục vi phạm hợp đồng.

3.5.3.12.11. Trả lại tài sản thuê khoán

Khi chấm dứt hợp đồng thuê khoán, bên thuê khoán phải trả lại tài sản thuê khoán ở tình trạng phù hợp với mức độ khấu hao đã thỏa thuận; nếu làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thuê khoán thì phải bồi thường thiệt hại.

3.5.4. Hợp đồng hợp tác

3.5.4.1. Khái niệm

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó cá nhân, pháp nhân thỏa thuận về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản; trường hợp pháp luật quy định thì hợp đồng này phải được công chứng, chứng thực.

3.5.4.2. Nội dung của hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Mục đích, thời hạn hợp tác;
- Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;
- Tài sản đóng góp, nếu có;
- Đóng góp bằng sức lao động, nếu có;
- Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức;
- Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác, người đại diện, nếu có;
- Điều kiện tham gia và ra khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;
- Điều kiện chấm dứt hợp tác.

3.5.4.3. Tài sản chung của các thành viên hợp tác

Tài sản do các thành viên đóng góp, cùng tạo lập và tài sản khác theo quy định của pháp luật là tài sản chung theo phần của các thành viên hợp tác. Trường hợp có thỏa thuận về góp tiền mà thành viên hợp tác chậm thực hiện thì phải có trách nhiệm trả lãi đối với phần tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự 2015 và phải bồi thường thiệt hại, nếu có.

Việc định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản xuất khác phải có thỏa thuận bằng văn bản của tất cả các thành viên; việc định đoạt tài sản khác do đại diện của các thành viên quyết định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Không được phân chia tài sản chung trước khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, trừ trường hợp tất cả các thành viên hợp tác có thỏa thuận. Việc phân chia tài sản chung quy định tại khoản này không làm thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ được xác lập, thực hiện trước thời điểm tài sản được phân chia.

3.5.4.4. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác

- Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động hợp tác.
- Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác.
- Bồi thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra.
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

3.5.4.5. Thực hiện giao dịch dân sự

Trường hợp các thành viên hợp tác cử người đại diện thì người này là người đại diện trong thực hiện giao dịch dân sự.

Trường hợp các thành viên hợp tác không cử ra người đại diện thì mỗi thành viên hợp tác đều có quyền đại diện trong thực hiện giao dịch dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác về phương thức thực hiện hợp đồng.

Giao dịch dân sự do người có quyền đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của tất cả thành viên.

3.5.4.6. Trách nhiệm dân sự của thành viên hợp tác

Các thành viên hợp tác chịu trách nhiệm dân sự chung bằng tài sản chung; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì thành viên hợp tác phải chịu trách nhiệm theo phần tương ứng với lợi ích mà mình nhận được trong hợp đồng, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc luật có quy định khác.

3.5.4.7. Rút khỏi hợp đồng hợp tác

Thành viên có quyền rút khỏi hợp đồng hợp tác theo các điều kiện đã thỏa thuận, trừ trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của hơn một nửa số thành viên hợp tác.¹²

Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền yêu cầu nhận lại tài sản đã đóng góp, được chia phần tài sản trong khối tài sản chung và phải thanh toán các nghĩa vụ theo thỏa thuận. Trường hợp việc phân chia tài sản bằng hiện vật làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác thì tài sản được tính giá trị thành tiền để chia. Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người này được xác lập, thực hiện trước thời điểm rút khỏi hợp đồng hợp tác.

3.5.4.8. Gia nhập hợp đồng hợp tác

Trường hợp hợp đồng không quy định khác thì một cá nhân, pháp nhân là thành viên mới của hợp đồng hợp tác nếu được sự đồng ý của hơn một nửa tổng số thành viên hợp tác.

3.5.4.9. Chấm dứt hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- a) Theo thỏa thuận của các thành viên hợp tác;
- b) Mục đích hoặc thời hạn hợp tác đã đạt được, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
- c) Không còn thành viên hợp tác;
- d) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Trường hợp khác về chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 và luật khác.

Khi chấm dứt, các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hợp tác phải được thanh toán; nếu tài sản chung không đủ để trả nợ thì phải lấy tài sản riêng của các thành viên hợp tác để thanh toán theo quy định tại Điều 508 của Bộ luật dân sự 2015.

¹² Lưu ý: Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều này thì được coi là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường thiệt hại, nếu có

Trường hợp các khoản nợ đã được thanh toán xong mà tài sản chung vẫn còn thì được chia cho các thành viên hợp tác theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp của mỗi người, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

3.5.5. Hợp đồng dịch vụ

3.5.5.1. Khái niệm

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, còn bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

3.5.5.2. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ phải là công việc có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm, không trái đạo đức xã hội.

3.5.5.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bảng 3.1. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng dịch vụ

Các bên	Quyền	Nghĩa vụ
Bên thuê dịch vụ	- Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác. - Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên thuê dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.	- Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thoả thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi. - Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thoả thuận.
Bên cung ứng dịch vụ	- Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện. - Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên thuê dịch vụ, mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên thuê dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên thuê dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên thuê dịch vụ. - Yêu cầu bên thuê dịch vụ trả tiền dịch vụ.	- Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác. - Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc, nếu không có sự đồng ý của bên thuê dịch vụ. - Bảo quản và phải giao lại cho bên thuê dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc. - Báo ngay cho bên thuê dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc. - Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. - Bồi thường thiệt hại cho bên thuê dịch vụ, nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

3.5.5.4. Trả tiền dịch vụ

Bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thoả thuận.

Khi giao kết hợp đồng nếu không có thoả thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.

Bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ, nếu không có thoả thuận khác.

Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thoả thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên thuê dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.5.5.5. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên thuê dịch vụ thì bên thuê dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên thuê dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên thuê dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.5.5.6. Tiếp tục hợp đồng dịch vụ

Sau khi đã kết thúc thời hạn dịch vụ mà công việc chưa hoàn thành và bên cung ứng dịch vụ vẫn tiếp tục thực hiện công việc, còn bên thuê dịch vụ biết nhưng không phản đối thì hợp đồng dịch vụ đương nhiên được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thoả thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.

3.5.6. Hợp đồng vận chuyển

3.5.6.1. Khái niệm

Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

3.5.6.2. Hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản

Hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể.

Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên.

3.5.6.3. Giao tài sản cho bên vận chuyển

Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thoả thuận; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Trường hợp bên thuê vận chuyển giao tài sản không đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thoả thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển hoặc phải nộp phạt vi phạm theo thoả thuận.

Trường hợp bên vận chuyển chậm nhận tài sản tại địa điểm đã thoả thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận hoặc phải nộp phạt vi phạm theo thoả thuận.

3.5.6.4. Cước phí vận chuyển

Mức cước phí vận chuyển do các bên thoả thuận; nếu pháp luật có quy định về mức cước phí vận chuyển thì áp dụng mức cước phí đó.

Bên thuê vận chuyển phải thanh toán đủ cước phí vận chuyển sau khi tài sản được chuyển lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

3.5.6.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bảng 3.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Các bên	Quyền	Nghĩa vụ
Bên vận chuyển	- Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác. - Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thoả thuận trong hợp đồng. - Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn. - Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển biết hoặc phải biết. - Yêu cầu bên thuê vận chuyển bồi thường thiệt hại.	- Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn. - Giao tài sản cho người có quyền nhận. - Chịu chi phí liên quan đến việc chuyển chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác. - Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. - Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất mát, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Bên thuê vận chuyển	- Yêu cầu bên vận chuyển chuyển chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thoả thuận. - Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển. - Yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại.	- Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thoả thuận. - Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển. - Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thoả thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

3.5.6.6. Giao tài sản cho bên nhận tài sản

Bên nhận tài sản có thể là bên thuê vận chuyển tài sản hoặc là người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định nhận tài sản.

Bên vận chuyển phải giao tài sản đầy đủ, đúng thời hạn và địa điểm cho bên nhận theo thoả thuận.

Trường hợp tài sản đã được chuyển đến địa điểm giao tài sản đúng thời hạn nhưng không có bên nhận thì bên vận chuyển có thể gửi số tài sản đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên thuê vận chuyển hoặc bên nhận tài sản. Bên thuê vận chuyển hoặc bên nhận tài sản phải chịu chi phí hợp lý phát sinh từ việc gửi giữ tài sản. Nghĩa vụ giao tài sản hoàn thành khi tài sản đã được gửi giữ đáp ứng các điều kiện đã thoả thuận và bên thuê vận chuyển hoặc bên nhận tài sản đã được thông báo về việc gửi giữ.

3.5.6.7. Nghĩa vụ của bên nhận tài sản

- Xuất trình cho bên vận chuyển vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác và nhận tài sản đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận.

- Chịu chi phí xếp, dỡ tài sản vận chuyển, nếu không có thoả thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác.

- Thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do việc chậm tiếp nhận tài sản.

- Thông báo cho bên thuê vận chuyển về việc nhận tài sản và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của bên đó; nếu không thông báo thì không có quyền yêu cầu bên thuê vận chuyển bảo vệ quyền, lợi ích liên quan đến tài sản vận chuyển của mình.

3.5.6.8. Quyền của bên nhận tài sản

- Kiểm tra số lượng, chất lượng tài sản được vận chuyển đến.

- Nhận tài sản được vận chuyển đến.

- Yêu cầu bên vận chuyển thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do phải chờ nhận tài sản, nếu bên vận chuyển chậm giao.

- Trực tiếp yêu cầu hoặc báo để bên thuê vận chuyển yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại do tài sản bị mất mát, hư hỏng.

3.5.6.9. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

- Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển, nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 535 của Bộ luật dân sự 2015.

- Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

- Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3.5.7. Hợp đồng gia công

3.5.7.1. Khái niệm

Hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

3.5.7.2. Đối tượng của hợp đồng gia công

Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

3.5.7.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bảng 3.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công

Các bên	Quyền	Nghĩa vụ
---------	-------	----------

Bên đặt gia công	1. Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận. 2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. 3. Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn đã thoả thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.	1. Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm cho bên nhận gia công, trừ trường hợp có thoả thuận khác; cung cấp các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công. 2. Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng. 3. Trả tiền công theo đúng thoả thuận.
Bên nhận gia công	1. Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận. 2. Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công. 3. Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận.	1. Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp. 2. Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội; trường hợp không báo hoặc không từ chối thì phải chịu trách nhiệm về sản phẩm tạo ra. 3. Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận. 4. Giữ bí mật các thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra. 5. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công. 6. Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

3.5.7.4. Trách nhiệm chịu rủi ro

Cho đến khi giao sản phẩm cho bên đặt gia công, bên nào là chủ sở hữu của nguyên vật liệu thì phải chịu rủi ro đối với nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Khi bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì phải chịu rủi ro trong thời gian chậm nhận, kể cả trong trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu của bên nhận gia công, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Khi bên nhận gia công chậm giao sản phẩm mà có rủi ro đối với sản phẩm gia công thì phải bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên đặt gia công.

3.5.7.5. Giao, nhận sản phẩm gia công

Bên nhận gia công phải giao sản phẩm và bên đặt gia công phải nhận sản phẩm theo đúng thời hạn và tại địa điểm đã thoả thuận.

3.5.7.6. Chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công

Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành công việc thì bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì bên nhận gia công có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên đặt gia công. Nghĩa vụ giao sản phẩm hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thoả thuận và bên đặt gia công đã được thông báo. Bên đặt gia công phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ.

3.5.7.7. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công

Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.

Bên đặt gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải trả tiền công tương ứng với công việc đã làm, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Bên nhận gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì không được trả tiền công, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.

3.5.7.8. Trả tiền công

Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm, nếu không có thoả thuận khác.

Trường hợp không có thoả thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm trả tiền.

Bên đặt gia công không có quyền giảm tiền công, nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của mình.

3.5.7.9. Thanh lý nguyên vật liệu

Khi hợp đồng gia công chấm dứt, bên nhận gia công phải hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

3.5.8. Hợp đồng ủy quyền

3.5.8.1. Khái niệm

Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

3.5.8.2. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

3.5.8.3. Ủy quyền lại

Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây:

- a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền;
- b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người được ủy quyền không thể thực hiện được.

Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.

Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

3.5.8.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bảng 3.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng ủy quyền

Các bên	Quyền	Nghĩa vụ
Bên được ủy quyền	1. Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền. 2. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.	1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó. 2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền. 3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền. 4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền. 5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.
Bên ủy quyền	1. Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền. 2. Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thoả thuận khác. 3. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 564 của Bộ luật dân sự 2015.	1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc. 2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 3. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thoả thuận về việc trả thù lao.

3.5.8.5. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo

trước cho bên được uỷ quyền một thời gian hợp lý. Bên uỷ quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên uỷ quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng uỷ quyền đã bị chấm dứt.

Trường hợp uỷ quyền không có thù lao, bên được uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên uỷ quyền biết một thời gian hợp lý; nếu uỷ quyền có thù lao thì bên được uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên uỷ quyền.

PDF

CHƯƠNG 4: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH

4.1. KHÁI QUÁT CHUNG

4.1.1. Khái niệm và các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Tranh chấp trong kinh doanh còn được hiểu là sự bất đồng về một hiện tượng pháp lý phát sinh trong đời sống kinh tế giữa các chủ thể tham gia kinh doanh và thông thường gắn liền với các yếu tố, lợi ích về mặt tài sản.¹

Tranh chấp là hệ quả tất yếu xảy ra trong hoạt động kinh doanh và vì vậy giải quyết các tranh chấp phát sinh được coi là đòi hỏi tự thân của các quan hệ kinh tế. Theo hiểu biết chung, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh chính là việc lựa chọn các hình thức, biện pháp thích hợp để giải toả các mâu thuẫn, bất đồng, xung đột lợi ích giữa các bên, tạo lập lại sự cân bằng về mặt lợi ích mà các bên có thể chấp nhận được.

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường phải đáp ứng các yêu cầu:

- Nhanh chóng, thuận lợi, không làm hạn chế, cản trở các hoạt động kinh doanh.
- Khôi phục và duy trì các quan hệ hợp tác, tín nhiệm giữa các bên trong kinh doanh.
- Giữ bí mật kinh doanh, uy tín của các bên trên thương trường.
- Kinh tế nhất (ít tốn kém nhất).

Các hình thức giải quyết tranh chấp chủ yếu được áp dụng rộng rãi trên thế giới bao gồm: thương lượng, hoà giải, trọng tài (phi chính phủ), và giải quyết thông qua toà án.

4.1.1.1. Thương lượng

Thương lượng là hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh không cần đến vai trò của người thứ ba. Đặc điểm cơ bản của thương lượng là các bên cùng nhau trình bày quan điểm, chính kiến, bàn bạc, tìm các biện pháp thích hợp, và đi đến thống nhất thoả thuận để tự giải quyết các bất đồng.

Thương lượng là hình thức phổ biến thích hợp cho việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Hình thức này từ lâu đã được giới thương nhân ưa chuộng vì nó đơn giản lại không bị ràng buộc bởi các thủ tục pháp lý phiền phức, ít tốn kém hơn và nói chung không làm phương hại đến quan hệ hợp tác vốn có giữa các bên trong kinh doanh cũng như giữ được các bí mật kinh doanh. Thương lượng đòi hỏi trước hết các bên phải có thiện chí, trung thực, hợp tác và phải có đầy đủ những am hiểu cần thiết về chuyên môn và pháp lý. Đối với sự việc phức tạp, mỗi bên có thể chỉ định những chuyên gia, những tổ chức có trình độ chuyên môn, "có tay nghề", thay mặt và đại diện cho mình để tiến hành thương lượng. Thông thường, việc giải quyết thành công thông qua thương lượng các vụ việc tranh chấp trong kinh doanh đều có sự kết hợp giữa các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật và các chuyên gia pháp lý. Thương lượng thật sự đã trở thành quá trình trao đổi ý kiến, bày tỏ ý chí giữa các bên để tìm giải pháp tháo gỡ. Do vậy, nói theo ngôn từ pháp lý là trong thương

1. Trần Đình Hào: "Hoà giải thương lượng trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế", Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 1 -2000, tr. 28.

lượng, các bên tiến hành bàn bạc, trao đổi ý kiến, thoả thuận thông qua "hành vi giao dịch". Cho nên cần lưu ý đến những yêu cầu đòi hỏi nhất định về mặt pháp lý như chế định đại diện, chế định uỷ quyền, giao dịch dân sự, năng lực hành vi... Kết quả của thương lượng là những cam kết, thoả thuận về những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những bế tắc hoặc bất đồng phát sinh mà các bên thường không ý thức được trước đó.

Pháp luật của các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển đều quy định hình thức pháp lý của việc ghi nhận kết quả thương lượng là biên bản. Nội dung chủ yếu của biên bản thương lượng phải đề cập đến các vấn đề sau: những sự kiện pháp lý có liên quan; chính kiến của mỗi bên (sự bất đồng); các giải pháp được đề xuất; những thoả thuận, cam kết đã đạt được.

Khi biên bản thương lượng được lập một cách hợp lệ, những thoả thuận trong biên bản thương lượng được coi là có giá trị pháp lý như hợp đồng và đương nhiên nó có ý nghĩa bắt buộc đối với các bên. Trong trường hợp kết quả thương lượng không được một bên tự giác thực hiện vì thiếu thiện chí, biên bản thương lượng sẽ được bên kia sử dụng như một chứng cứ quan trọng để xuất trình trước các cơ quan tài phán kinh tế, để yêu cầu các cơ quan này thừa nhận và cưỡng chế thi hành những thoả thuận nói trên. Do có những ưu điểm riêng của nó, thương lượng đã trở thành hình thức giải quyết tranh chấp phổ biến của các tập đoàn kinh doanh lớn trên thế giới, đặc biệt là các tập đoàn kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán... để bảo vệ một cách có hiệu quả những bí mật thương mại giữa họ.

4.1.1.2. Hoà giải

Hoà giải là hình thức giải quyết tranh chấp có sự tham gia của bên thứ ba độc lập, do hai bên cùng chấp nhận hay chỉ định, làm vai trò trung gian để hỗ trợ cho các bên để tìm kiếm những giải pháp thích hợp cho việc giải quyết xung đột nhằm chấm dứt các tranh chấp, bất hoà.

Hoà giải là giải pháp mang tính chất tự nguyện, tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bên. Đặc biệt là bên thứ ba với tính chất trung gian hoà giải phải có vị trí độc lập đối với các bên. Điều đó có nghĩa là, bên thứ ba này không ở vị trí xung đột lợi ích đối với các bên hoặc không có những lợi ích gắn liền với lợi ích của một trong các bên trong các vụ việc đang có tranh chấp. Bên thứ ba làm trung gian hoà giải không phải là những đại diện bất kỳ của bên nào và cũng không có quyền quyết định, phán xét như một trọng tài vụ việc (trọng tài Ad-hoc). Bên thứ ba làm trung gian hoà giải thường phải là những cá nhân, tổ chức có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm về những vụ việc có liên quan đến các tranh chấp phát sinh. Công việc của họ là: (i) Xem xét, phân tích, đánh giá và đưa ra những ý kiến, nhận định bình luận về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và những vấn đề có liên quan để các bên tham khảo (chẳng hạn như: tổ chức giám định, đánh giá, tư vấn chuyên môn, tư vấn pháp lý...); (ii) Đề ra những giải pháp, những phương án thích hợp để các bên tham khảo lựa chọn và quyết định.

Cho đến nay, người ta đã biết đến hai hình thức hoà giải chủ yếu là: hoà giải ngoài tổ tụng và hoà giải trong tổ tụng.

- Hoà giải ngoài tổ tụng: là hình thức hoà giải qua trung gian, được các bên tiến hành trước khi đưa vụ tranh chấp ra cơ quan tài phán. Khi thống nhất được các hình thức giải quyết tranh chấp, các bên phải tự nguyện thực hiện theo phương án đã thoả thuận. Đối với hoà giải ngoài tổ tụng, pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới đã coi đây là công việc riêng của các bên nên không điều

chính trực tiếp và chi tiết. Mặc dù vậy, ngay trong hình thức này cũng có những vấn đề pháp lý sau đây được đặt ra:

Một là, sự lựa chọn của các bên về trung gian hoà giải (ví dụ như giám định viên, hội đồng giám định...) có thể đã được quy định trước về mặt nguyên tắc trong hợp đồng và sau đó trong trường hợp xảy ra tranh chấp các bên sẽ chỉ định cụ thể. Trong trường hợp hợp đồng không có quy định như vậy, khi xảy ra tranh chấp các bên sẽ phải thoả thuận chỉ định trung gian hoà giải.

Hai là, các bên có thể xác định một quy trình tiến hành trung gian hoà giải, và trong trường hợp ngược lại, không có xác định như vậy thì có thể được hiểu là các bên dành cho trung gian hoà giải toàn quyền quyết định một quy trình mềm dẻo và linh hoạt.

Ba là, các ý kiến, nhận xét, biện luận và đề xuất của trung gian hoà giải có tính chất khuyến nghị đối với các bên; khi được các bên chấp thuận, chúng sẽ trở nên có giá trị bắt buộc thực hiện đối với các bên (conclusive).

Bốn là, việc thừa nhận giá trị pháp lý của những khuyến nghị như vậy của trung gian hoà giải, khi đã được các bên chấp nhận, phải được ghi nhận và đảm bảo thi hành bằng các quy định của pháp luật. Điều này cho đến nay, pháp luật nước ta còn bỏ ngỏ.

Năm là, một hợp đồng dịch vụ có liên quan đến trung gian hoà giải cần phải được thiết lập giữa các bên tranh chấp và trung gian hoà giải nhằm giải quyết các vấn đề như: ai phải chịu phí tổn, các chuẩn mực cần thiết cho trung gian hoà giải, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Thực chất hình thức trung gian hoà giải thường thích hợp cho việc giải quyết các tranh chấp mà ở đó ngoài yếu tố thiện chí của các bên, còn có các vấn đề đòi hỏi chuyên môn, mà tự các bên khó có thể xem xét đánh giá chính xác, khách quan được. ở nhiều quốc gia, hoà giải là hình thức giải quyết tranh chấp quan trọng và điều này cũng giải thích cho việc ra đời các trung tâm hoà giải (chẳng hạn như Trung tâm hoà giải Bắc Kinh để giải quyết các tranh chấp thương mại và hàng hải quốc tế...); và các quy trình hoà giải mẫu (chẳng hạn như Quy trình hoà giải Folloberg-Taylor, Quy trình hoà giải không bắt buộc của Phòng thương mại quốc tế tại Luân Đôn, Quy trình hoà giải mẫu của UNCITRAL năm 1980...).

Có thể nói rằng, hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải ở nước ta chưa phổ biến do thiếu các quy định, hướng dẫn cụ thể cũng như các điều kiện chuyên môn, thói quen trong thương mại và vì vậy dường như trung gian hoà giải còn mang nặng tính ý tưởng.

- Hoà giải trong tố tụng: là hoà giải được tiến hành tại toà án hay trọng tài khi các cơ quan này giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của các bên. Người trung gian hoà giải trong trường hợp này là toà án hoặc trọng tài (cụ thể là thẩm phán hoặc trọng tài viên phụ trách vụ việc).

Như vậy, hoà giải trong tố tụng được coi là một bước, một giai đoạn trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng con đường toà án hay trọng tài và chỉ có thể được tiến hành khi một bên có đơn khởi kiện đến toà án hoặc đơn yêu cầu trọng tài giải quyết và đơn này đã được thụ lý.

Do bản chất của hoà giải là sự tự quyết định của các bên tranh chấp nên trong quá trình hoà giải, thẩm phán hoặc trọng tài viên không được ép buộc mà phải tôn trọng tính tự nguyện, tự do ý chí của các bên cũng như không được tiết lộ phương hướng, đường lối xét xử... Khi các đương sự đạt được thoả thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp thì toà án hay trọng tài lập biên bản hoà giải thành và ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự; quyết định này có hiệu lực,

được thi hành như một bản án của toà án hay phán quyết của trọng tài. Đây chính là điểm khác cơ bản giữa hoà giải ngoài tố tụng và hoà giải trong tố tụng.

Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, hoà giải trong tố tụng (đặc biệt là trong tố tụng toà án) phải tuân theo một quy trình hết sức chặt chẽ. Trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự, hoà giải có thể thực hiện trước giai đoạn xét xử, trong giai đoạn xét xử và kể cả sau khi đã có phán quyết của toà án hay trọng tài. Sở dĩ có được điều này là vì theo quan điểm của họ, mục đích của việc giải quyết tranh chấp sẽ đạt được một cách hiệu quả nhất thông qua sự thoả thuận của các đương sự.

Ở Việt Nam, pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và các quy tắc tố tụng trọng tài hiện hành cho phép hiểu rằng, hoà giải trong tố tụng chỉ được tiến hành trước khi toà án hoặc trọng tài ra phán quyết.

4.1.1.3. Trọng tài

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng trọng tài là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của trọng tài viên, với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt xung đột bằng việc đưa ra một phán quyết buộc các bên tranh chấp phải thực hiện.

Một số đặc điểm cơ bản của hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài:

- Trọng tài thương mại là một loại hình tổ chức phi chính phủ, hoạt động theo pháp luật và quy chế trọng tài. ở phần lớn các nước có nền kinh tế thị trường phát triển không đặt ra vấn đề hỗ trợ của nhà nước đối với trọng tài, trừ việc cưỡng chế thi hành quyết định của trọng tài. ở nhiều nước châu á hoạt động của trọng tài được nhà nước hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt về tài chính như ở Hàn Quốc, Malaixia, Thái Lan, Philippin. Đặc biệt ở Thái Lan có Viện trọng tài nằm trong Bộ Tư pháp, được Bộ Tư pháp cấp trụ sở và trả lương hành chính cho tất cả nhân viên và chi phí văn phòng. Chỉ có các trọng tài viên hoạt động độc lập không thuộc Bộ Tư pháp². Nó có quyền phán quyết như toà án, quyết định của trọng tài được cưỡng chế thi hành.

- Cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là sự kết hợp giữa hai yếu tố thoả thuận và tài phán. Cụ thể, thoả thuận làm tiền đề cho phán quyết và không thể có phán quyết thoát ly những yếu tố đã được thoả thuận². Do đó về nguyên tắc thẩm quyền của trọng tài không bị giới hạn bởi pháp luật. Các đương sự có thể lựa chọn bất cứ lúc nào, bất cứ trọng tài vụ việc nào hoặc bất cứ một tổ chức trọng tài nào trên thế giới. Tuy nhiên, để bảo vệ lợi ích công, pháp luật của nhiều quốc gia chỉ thừa nhận thẩm quyền của trọng tài trong lĩnh vực luật tư (Private Law).

- Hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đã đảm bảo quyền tự do định đoạt của các đương sự cao hơn so với quyết định giải quyết tranh chấp bằng toà án như: các đương sự có quyền lựa chọn trọng tài viên; quyền lựa chọn địa điểm giải quyết tranh chấp; quyền lựa chọn quy tắc tố tụng; quyền lựa chọn luật áp dụng cho tranh chấp.

- Phán xét của trọng tài có giá trị chung thẩm và không thể kháng cáo trước bất cứ cơ quan, tổ chức nào. Về nguyên tắc, trọng tài không xét xử công khai, do đó ngoài nguyên đơn và bị đơn, trọng tài chỉ triệu tập các đương sự khác khi cần thiết.

1. Kỳ yếu dự án VIE/94/003, t. IV, ph. II, Chương III, tr. 83.

² Khoa Luật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội: *Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam*, Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội, 1997, tr. 472.

- Quy tắc tố tụng trọng tài ở các quốc gia rất khác nhau, nhưng nhìn chung quy tắc lựa chọn trọng tài viên và thủ tục của hầu hết các trung tâm trọng tài trên thế giới đều dựa theo khuôn mẫu của Quy tắc trọng tài mẫu UNCITRAL.

- Về nguyên tắc pháp luật của các quốc gia này đều quy định sự hỗ trợ từ phía toà án trong việc đảm bảo việc thực thi các quyết định của trọng tài. Thông qua trình tự công nhận và cho thi hành, toà án đảm bảo thực thi trên thực tế các quyết định của trọng tài khi một bên đương sự không tự nguyện thực hiện: (a) Quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời của trọng tài như: cấm hoặc cho phép thực hiện một số hành vi nhất định, kê biên tài sản... để đảm bảo hiệu lực thực tế của phán quyết trọng tài; (b) Phán quyết của trọng tài về giải quyết tranh chấp.

- Trọng tài thương mại ở các nước trên thế giới chủ yếu tồn tại dưới hai dạng cơ bản:

+ *Trọng tài vụ việc* là hình thức trọng tài được lập ra để giải quyết những tranh chấp cụ thể khi có yêu cầu và tự giải thể khi giải quyết xong những tranh chấp đó. Đặc điểm cơ bản của trọng tài vụ việc là không có trụ sở, không có bộ máy giúp việc, và không lệ thuộc vào bất cứ một quy tắc xét xử nào. Về nguyên tắc, các bên đương sự khi yêu cầu trọng tài vụ việc xét xử có quyền lựa chọn thủ tục, các phương thức tiến hành tố tụng. Trọng tài vụ việc là hình thức tổ chức đơn giản, khá linh hoạt và mềm dẻo về phương thức hoạt động nên nói chung phù hợp với những tranh chấp ít tình tiết phức tạp, có nhu cầu giải quyết nhanh chóng và nhất là các bên tranh chấp có kiến thức và hiểu biết về pháp luật, cũng như kinh nghiệm tranh tụng. Tuy vậy, trên thực tế số lượng các vụ tranh chấp được giải quyết thông qua trọng tài vụ việc không nhiều.

+ *Trọng tài thường trực* (còn gọi là trọng tài quy chế) là những trọng tài có hình thức tổ chức, có trụ sở ổn định, có danh sách trọng tài viên, và hoạt động theo điều lệ riêng. Phần lớn các tổ chức trọng tài lớn, có uy tín trên thế giới đều được thành lập theo mô hình này dưới các tên gọi như: Trung tâm trọng tài, Ủy ban trọng tài, Viện trọng tài, Hội đồng trọng tài quốc gia và quốc tế. Thông thường, cơ cấu tổ chức của trọng tài thường trực gồm có hai bộ phận: bộ phận thường trực (ban quản trị và phòng thư ký); các hội đồng trọng tài (được thành lập khi có vụ việc). Ngoài ra còn có bộ phận giúp việc.

Đặc điểm cơ bản của trọng tài thường trực là có quy chế tố tụng riêng và được quy định rất chặt chẽ. Về cơ bản, các đương sự không được phép lựa chọn thủ tục tố tụng.

4.1.1.4. Giải quyết tranh chấp bằng toà án

Giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng toà án là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của cơ quan tài phán nhà nước, nhân danh quyền lực nhà nước để đưa ra phán quyết buộc các bên có nghĩa vụ thi hành, kể cả bằng sức mạnh cưỡng chế. Do đó, các đương sự thường tìm đến sự trợ giúp của toà án như một giải pháp cuối cùng nhằm bảo vệ có hiệu quả các quyền, lợi ích của mình khi họ thất bại trong việc sử dụng cơ chế thương lượng hoặc hoà giải và cũng không muốn vụ tranh chấp giữa họ được giải quyết bằng con đường trọng tài.

Thông qua việc nghiên cứu và trực tiếp khảo sát tại các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển, đồng thời có hệ thống pháp luật phát triển như Pháp, Đức, Nhật Bản, Anh, Mỹ..., cho thấy việc giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng con đường toà án của các nước này có một số điểm đáng lưu ý như sau:

- Về nguyên tắc tổ chức hệ thống toà án

Hệ thống toà án của các quốc gia này đều được tổ chức theo cấp xét xử và dựa trên nguyên tắc hai cấp xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm). Số lượng các toà án không được xác định theo địa giới hành chính mà được xác định theo yêu cầu của công tác xét xử.

- Về nguyên tắc thẩm quyền theo vụ việc của toà án

Về nguyên tắc, theo pháp luật về tố tụng dân sự và thương mại của các quốc gia này, thẩm quyền theo vụ việc chỉ đặt ra để phân định thẩm quyền giữa các cơ cấu trong hệ thống toà án. Điều đó có nghĩa là, thẩm quyền toà án không bị giới hạn bởi các vụ việc phát sinh trong đời sống dân sự nói chung và thương mại nói riêng. Từ cách quan niệm, các đương sự tìm đến sự trợ giúp của toà án như một giải pháp cuối cùng để bảo vệ một cách có hiệu quả các quyền và lợi ích của mình nên pháp luật về tố tụng dân sự và thương mại của các quốc gia này đã thừa nhận một nguyên tắc: Thẩm phán không được phép từ chối xét xử với lý do pháp luật chưa có quy định về vấn đề này. Hơn thế nữa, hành vi từ chối xét xử của thẩm phán còn được xem là một tội danh bị xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự. Cách tiếp cận này đã cho phép chúng ta thấy được vai trò to lớn của hệ thống án lệ - một nguồn luật quan trọng do chính toà án sáng tạo ra để phục vụ hoạt động xét xử một cách có hiệu quả.

Thông thường, thẩm quyền của toà án của các quốc gia này không bị giới hạn bởi các tranh chấp sau: a) Tranh chấp giữa các thương gia trong các giao dịch thương mại; b) Tranh chấp liên quan đến hoạt động phát hành, lưu ký, bảo lãnh, kinh doanh chứng khoán; c) Tranh chấp giữa công ty với thành viên công ty, giữa thành viên công ty với nhau về thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể công ty; d) Tranh chấp liên quan đến thương phiếu; e) Tranh chấp mua bán, cho thuê, khoán kinh doanh một doanh nghiệp; g) Tranh chấp liên quan đến số hiệu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi và xuất xứ hàng hoá...); h) Tranh chấp lĩnh vực cạnh tranh không lành mạnh và kiểm soát độc quyền; i) Tranh chấp thương mại hàng hải...

- Về thủ tục tố tụng

Thủ tục tố tụng được áp dụng cho các tranh chấp trong kinh doanh được dựa trên nền tảng thủ tục tố tụng dân sự cùng với một số quy định đặc thù cho phù hợp với hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như: về hội đồng xét xử, về thời gian của các trình tự tố tụng... Vì vậy, các quốc gia này không ban hành luật tố tụng riêng cho các tranh chấp trong kinh doanh mà chỉ có luật về tố tụng dân sự.

- Về cơ cấu tổ chức toà án

Tuỳ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các điều kiện văn hoá, tập quán và truyền thống xây dựng pháp luật, toà án ở các quốc gia này được tổ chức hết sức khác nhau. Tuy nhiên, người ta thường thấy có hai mô hình tổ chức toà án để giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh là:

- Thành lập các toà chuyên trách với tên gọi là toà kinh tế hay toà thương mại độc lập về mặt tổ chức với toà án thường để giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh.

- Trao thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong kinh doanh cho toà dân sự. Ở các quốc gia theo mô hình này không có sự phân biệt rạch ròi giữa tranh chấp dân sự và tranh chấp kinh doanh, vì theo họ, về bản chất tranh chấp trong kinh doanh là một dạng của tranh chấp dân sự, và do đó

không cần phải phân hoá điều chỉnh pháp luật về thủ tục tố tụng đến mức phải có luật tố tụng cho các tranh chấp trong kinh doanh.

So với phương thức giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài, việc giải quyết tranh chấp tại toà án đã bộc lộ nhiều ưu thế hơn hẳn về trình tự, trình tự tố tụng chặt chẽ và tính khả thi của hiệu lực phán quyết. Mặc dù vậy, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng toà án thường dài hơn và chi phí cao hơn so với giải quyết bằng trọng tài. Thêm vào đó, nguyên tắc xét xử công khai tại toà án không được giới doanh nghiệp nhìn nhận là một nguyên tắc có thể bảo vệ được bí mật kinh doanh và uy tín của họ trên thương trường.

4.2. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI³

4.2.1. Thẩm quyền của trọng tài thương mại

- Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
- Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
- Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

4.2.2. Thỏa thuận trọng tài và điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.⁴

4.2.2.1. Hình thức

Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. Thỏa thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

- Thỏa thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
- Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;
- Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;
- Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;
- Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thỏa thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

4.2.2.2. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu

- Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài quy định tại Điều 2 của Luật TTTM 2010.

³ Luật Trọng tài thương mại năm 2010 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

⁴ Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

- Người xác lập thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.
- Hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 của Luật này.
- Một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài đó là vô hiệu.
- Thoả thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.

4.2.2.3. Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

- Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thoả thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
- Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
- Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

4.2.3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật và hình thức để giải quyết vụ tranh chấp

- Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp.
- Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn; nếu các bên không có thoả thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.
- Trường hợp pháp luật Việt Nam, pháp luật do các bên lựa chọn không có quy định cụ thể liên quan đến nội dung tranh chấp thì Hội đồng trọng tài được áp dụng tập quán quốc tế để giải quyết tranh chấp nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

4.2.4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

- Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thoả thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
- Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.
- Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
- Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

- Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

4.2.5. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài thương mại

4.2.5.1. Đơn kiện và thời hạn khởi kiện

4.2.5.1.1. Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo

Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

Đơn khởi kiện gồm có các nội dung sau đây: a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; b) Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có; c) Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp; d) Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có; đ) Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp; e) Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên. Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

4.2.5.1.2. Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài

Trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.

4.2.5.1.3. Thông báo đơn khởi kiện

Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật TTTM.

4.2.5.1.4. Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

4.2.5.1.5. Phí trọng tài

Phí trọng tài là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Phí trọng tài gồm: a) Thù lao Trọng tài viên, chi phí đi lại và các chi phí khác cho Trọng tài viên; b) Phí tham vấn chuyên gia và các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài; c) Phí hành chính; d) Phí chỉ định Trọng tài viên vụ việc của Trung tâm trọng tài theo yêu cầu của các bên tranh chấp; đ) Phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác được cung cấp bởi Trung tâm trọng tài.

Phí trọng tài do Trung tâm trọng tài ấn định. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài vụ việc, phí trọng tài do Hội đồng trọng tài ấn định.

Bên thua kiện phải chịu phí trọng tài, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng trọng tài quy định khác hoặc Hội đồng trọng tài có sự phân bổ khác.

4.2.5.1.6. Bản tự bảo vệ và việc gửi bản tự bảo vệ

Bản tự bảo vệ gồm có các nội dung sau đây: a) Ngày, tháng, năm làm bản tự bảo vệ; b) Tên và địa chỉ của bị đơn; c) Cơ sở và chứng cứ tự bảo vệ, nếu có; d) Tên và địa chỉ của người được bị đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, thời hạn này có thể được Trung tâm trọng tài gia hạn căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc.

Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng tài viên.

Trường hợp bị đơn cho rằng vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì phải nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ. Trường hợp bị đơn không nộp bản tự bảo vệ theo quy định trên thì quá trình giải quyết tranh chấp vẫn được tiến hành.

4.2.5.1.7. Đơn kiện lại của bị đơn

Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Trong trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi cho Hội đồng trọng tài và nguyên đơn. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện lại, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Hội đồng trọng tài và bị đơn.

Việc giải quyết đơn kiện lại do Hội đồng trọng tài giải quyết đơn khởi kiện của nguyên đơn thực hiện theo quy định của Luật này về trình tự, thủ tục giải quyết đơn khởi kiện của nguyên đơn.

4.2.5.1.8. Rút đơn khởi kiện, đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, đơn kiện lại hoặc bản tự bảo vệ

Trước khi Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài, các bên có quyền rút đơn khởi kiện, đơn kiện lại. Trong quá trình tố tụng trọng tài, các bên có thể sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, đơn kiện lại hoặc bản tự bảo vệ. Hội đồng trọng tài có quyền không chấp nhận các sửa đổi, bổ sung này nếu thấy rằng việc đó có thể bị lạm dụng nhằm gây khó khăn, trì hoãn việc ra phán quyết trọng tài hoặc vượt quá phạm vi của thỏa thuận trọng tài áp dụng cho vụ tranh chấp.

4.2.5.1.9. Thương lượng trong tố tụng trọng tài

Kể từ thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài, các bên vẫn có quyền tự mình thương lượng, thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp các bên tự thỏa thuận được với nhau chấm dứt việc giải quyết tranh chấp thì có quyền yêu cầu Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp.

4.2.5.2. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

4.2.5.2.1. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài, Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Luật TTTM và các quy định của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Việc yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không bị coi là sự bác bỏ thỏa thuận trọng tài hoặc khước từ quyền giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.

4.2.5.2.2. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Theo yêu cầu của một trong các bên, Hội đồng trọng tài có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các bên tranh chấp. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời bao gồm:

- a) Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp;
- b) Cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định nhằm ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng tài;
- c) Kê biên tài sản đang tranh chấp;
- d) Yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản nào của một hoặc các bên tranh chấp;
- đ) Yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên;
- e) Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu một trong các bên đã yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định trên mà sau đó lại có đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Hội đồng trọng tài phải từ chối.

Trước khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Hội đồng trọng tài có quyền buộc bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài chính.

Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác hoặc vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của bên yêu cầu mà gây thiệt hại cho bên yêu cầu, bên bị áp dụng hoặc người thứ ba thì người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

4.2.5.2.3. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài

Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải làm đơn gửi đến Hội đồng trọng tài. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải có các nội dung chính sau đây: a) Ngày, tháng, năm làm đơn; b) Tên, địa chỉ của bên có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; c) Tên, địa chỉ của bên bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; d)

Tóm tắt nội dung tranh chấp; đ) Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; e) Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

Kèm theo đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, bên yêu cầu phải cung cấp cho Hội đồng trọng tài chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

Theo quyết định của Hội đồng trọng tài, bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Hội đồng trọng tài ấn định tương ứng với giá trị thiệt hại có thể phát sinh do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng gây ra để bảo vệ lợi ích của bên bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá được gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng do Hội đồng trọng tài quyết định.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, ngay sau khi bên yêu cầu đã thực hiện biện pháp bảo đảm quy định trên thì Hội đồng trọng tài xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu, Hội đồng trọng tài thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho bên yêu cầu biết.

Việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

4.2.5.2.4 Thẩm quyền, thủ tục thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài

Theo yêu cầu của một bên, Hội đồng trọng tài có quyền thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình giải quyết tranh chấp. Thủ tục thay đổi, bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo quy định tại Điều 50 của Luật TTTM. Hội đồng trọng tài hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- a) Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ;
- b) Bên phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã nộp tài sản bảo đảm quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật TTTM, trừ trường hợp bên yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm bồi thường do yêu cầu không đúng gây thiệt hại cho bên bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba;
- c) Nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Thủ tục hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện như sau:

a) Bên yêu cầu phải có đơn đề nghị hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi Hội đồng trọng tài;

b) Hội đồng trọng tài xem xét ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và xem xét, quyết định để bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhận lại tài sản bảo đảm quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật TTTM, trừ trường hợp bên yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm bồi thường do yêu cầu không đúng gây thiệt hại cho bên bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba.

Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và Cơ quan thi hành án dân sự.

4.2.5.2.5. Trách nhiệm của bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình. Trong trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng và gây thiệt hại cho bên kia hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.

4.2.5.2.6. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Sau khi nộp đơn khởi kiện, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại hoặc có nguy cơ trực tiếp bị xâm hại, một bên có quyền làm đơn gửi đến Tòa án có thẩm quyền yêu cầu áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Chánh án Tòa án có thẩm quyền phân công một Thẩm phán xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét, quyết định áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Thẩm phán phải ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay sau khi người yêu cầu thực hiện biện pháp bảo đảm. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu thì Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết.

Một bên có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. Việc phân công Thẩm phán xem xét giải quyết đơn yêu cầu thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo quy định trên.

Trình tự, thủ tục áp dụng, thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu một trong các bên đã yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời mà lại có đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án phải từ chối và trả lại đơn yêu cầu, trừ trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài.

4.2.5.3. Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp

4.2.5.3.1. Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp

Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thời gian và địa điểm mở phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, giấy triệu tập tham dự phiên họp phải được gửi cho các bên chậm nhất 30 ngày trước ngày mở phiên họp.

4.2.5.3.2. Thành phần, thủ tục phiên họp giải quyết tranh chấp

Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.

Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.

4.2.5.3.3. Việc vắng mặt của các bên

Nguyên đơn đã được triệu tập họp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp giải quyết tranh chấp mà không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì bị coi là đã rút đơn khởi kiện. Trong trường hợp này, Hội đồng trọng tài tiếp tục giải quyết tranh chấp nếu bị đơn có yêu cầu hoặc có đơn kiện lại.

Bị đơn đã được triệu tập họp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp giải quyết tranh chấp mà không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì Hội đồng trọng tài vẫn tiếp tục giải quyết tranh chấp căn cứ vào tài liệu và chứng cứ hiện có.

Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài có thể căn cứ vào hồ sơ để tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp mà không cần sự có mặt của các bên.

4.2.5.3.4. Hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp

Khi có lý do chính đáng, một hoặc các bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp. Yêu cầu hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp phải được lập bằng văn bản, nêu rõ lý do kèm theo chứng cứ và được gửi đến Hội đồng trọng tài chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên họp giải quyết tranh chấp. Nếu Hội đồng trọng tài không nhận được yêu cầu theo thời hạn này, bên yêu cầu hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp phải chịu mọi chi phí phát sinh, nếu có. Hội đồng trọng tài xem xét, quyết định chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên họp và thông báo kịp thời cho các bên. Thời hạn hoãn phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.

4.2.5.3.5. Hoà giải, công nhận hòa giải thành

Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

4.2.5.3.6. Đình chỉ giải quyết tranh chấp

Vụ tranh chấp được đình chỉ giải quyết trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

b) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó;

c) Nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc được coi là đã rút đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật TTTM, trừ trường hợp bị đơn yêu cầu tiếp tục giải quyết tranh chấp;

d) Các bên thoả thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp;

đ) Tòa án đã quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại khoản 6 Điều 44 của Luật này.

Hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trường hợp Hội đồng trọng tài chưa được thành lập thì Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp.

Khi có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp, các bên không có quyền khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết lại vụ tranh chấp đó nếu việc khởi kiện vụ tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp quy định tại điểm c và điểm đ trên.

4.2.5.4. Phán quyết và thi hành phán quyết trọng tài

4.2.5.4.1. Nguyên tắc ra phán quyết

Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

4.2.5.4.2. Nội dung, hình thức và hiệu lực của phán quyết trọng tài

Phán quyết trọng tài phải được lập bằng văn bản và có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Ngày, tháng, năm và địa điểm ra phán quyết; b) Tên, địa chỉ của nguyên đơn và bị đơn; c) Họ, tên, địa chỉ của Trọng tài viên; d) Tóm tắt đơn khởi kiện và các vấn đề tranh chấp; đ) Căn cứ để ra phán quyết, trừ khi các bên có thoả thuận không cần nêu căn cứ trong phán quyết; e) Kết quả giải quyết tranh chấp; g) Thời hạn thi hành phán quyết; h) Phân bổ chi phí trọng tài và các chi phí khác có liên quan; i) Chữ ký của Trọng tài viên.

Khi có Trọng tài viên không ký tên vào phán quyết trọng tài, Chủ tịch Hội đồng trọng tài phải ghi việc này trong phán quyết trọng tài và nêu rõ lý do. Trong trường hợp này, phán quyết trọng tài vẫn có hiệu lực.

Phán quyết trọng tài được ban hành ngay tại phiên họp hoặc chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng.

Phán quyết trọng tài phải được gửi cho các bên ngay sau ngày ban hành. Các bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài vụ việc cấp bản sao phán quyết trọng tài. Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

4.2.5.4.3. Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc

Theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp, phán quyết của Trọng tài vụ việc được đăng ký tại Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trước khi yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành phán quyết trọng tài đó. Việc đăng ký hoặc không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài.

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành phán quyết trọng tài, bên yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc phải gửi đơn xin đăng ký phán quyết trọng tài tới Tòa án có thẩm quyền quy định trên kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ các tài liệu sau đây: a) Phán quyết trọng tài do Hội đồng trọng tài vụ việc ban hành; b) Biên bản phiên họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, nếu có; c) Bản chính hoặc bản sao thoả thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ. Bên yêu cầu phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu gửi cho Tòa án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn xin đăng ký phán quyết, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán xem xét đơn đăng ký phán quyết. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải kiểm tra tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo đơn và thực hiện việc đăng ký. Trường hợp xác định phán quyết trọng tài không có thật thì Thẩm phán từ chối đăng ký, trả lại đơn yêu cầu và các tài liệu kèm theo và phải thông báo ngay cho bên có yêu cầu biết, đồng thời nêu rõ lý do. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án, người yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án về việc từ chối đăng ký phán quyết trọng tài. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chánh án Tòa án phải xem xét và ra quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án là quyết định cuối cùng.

Nội dung đăng ký phán quyết Trọng tài: a) Thời gian, địa điểm thực hiện việc đăng ký; b) Tên Tòa án tiến hành việc đăng ký; c) Tên, địa chỉ của bên yêu cầu thực hiện việc đăng ký; d) Phán quyết được đăng ký; đ) Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của Tòa án.

4.2.5.4.4. Tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài

Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài.

4.2.5.4.5. Quyền yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài

Hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài theo quy định tại Điều 69 của Luật TTTM, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Đối với phán quyết của Trọng tài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài sau khi phán quyết được đăng ký theo quy định tại Điều 62 của Luật TTTM.

4.2.5.4.6. Thi hành phán quyết trọng tài

Phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

4.2.5.5. Huỷ phán quyết trọng tài

4.2.5.5.1. Căn cứ huỷ phán quyết trọng tài

Theo Điều 68 Luật TTTM, Tòa án xem xét việc huỷ phán quyết trọng tài khi có đơn yêu cầu của một bên. Phán quyết trọng tài bị huỷ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Không có thoả thuận trọng tài hoặc thoả thuận trọng tài vô hiệu;
- b) Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tổ tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;
- c) Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;
- d) Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;
- đ) Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Khi Tòa án xem xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài, nghĩa vụ chứng minh được xác định như sau:

- a) Bên yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài quy định tại các điểm a, b, c và d trên có nghĩa vụ chứng minh Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong các trường hợp đó;
- b) Đối với yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài quy định tại điểm đ trên, Tòa án có trách nhiệm chủ động xác minh thu thập chứng cứ để quyết định huỷ hay không huỷ phán quyết trọng tài.

4.2.5.5.2. Quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, nếu một bên có đủ căn cứ để chứng minh được rằng Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 68 của Luật TTTM, thì có quyền làm đơn gửi Tòa án có thẩm quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài là có căn cứ và hợp pháp.

Trường hợp gửi đơn quá hạn vì sự kiện bất khả kháng thì thời gian có sự kiện bất khả kháng không được tính vào thời hạn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài.

4.2.5.5.3. Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Ngày, tháng, năm làm đơn; b) Tên và địa chỉ của bên có yêu cầu; c) Yêu cầu và căn cứ huỷ phán quyết trọng tài.

Kèm theo đơn yêu cầu phải có các giấy tờ sau đây: a) Bản chính hoặc bản sao phán quyết trọng tài đã được chứng thực hợp lệ; b) Bản chính hoặc bản sao thoả thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ. Giấy tờ kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực hợp lệ.

4.2.5.5.4. Tòa án xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Sau khi thụ lý đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, Tòa án có thẩm quyền thông báo ngay cho Trung tâm trọng tài hoặc các Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc, các bên tranh chấp và Viện kiểm sát cùng cấp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý, Chánh án Tòa án chỉ định một Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm ba Thẩm phán, trong đó có một Thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được chỉ định, Hội đồng xét đơn yêu cầu phải phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Tòa án phải chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên họp để tham dự phiên họp của Tòa án xét đơn yêu cầu. Hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp xem xét đơn yêu cầu.

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của các bên tranh chấp, luật sư của các bên, nếu có, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp một trong các bên yêu cầu Hội đồng xét đơn vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được Hội đồng chấp thuận thì Hội đồng vẫn tiến hành xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Khi xét đơn yêu cầu, Hội đồng xét đơn yêu cầu căn cứ vào các quy định tại Điều 68 của Luật này và các tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định; không xét xử lại nội dung vụ tranh chấp mà Hội đồng trọng tài đã giải quyết. Sau khi xem xét đơn và các tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của những người được triệu tập, nếu có, Kiểm sát viên trình bày ý kiến của Viện kiểm sát, Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số.

Hội đồng xét đơn yêu cầu có quyền ra quyết định hủy hoặc không hủy phán quyết trọng tài. Trong trường hợp bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài rút đơn hoặc đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được Hội đồng chấp thuận thì Hội đồng ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi quyết định cho các bên, Trung tâm trọng tài hoặc Trọng tài viên Trọng tài vụ việc và Viện kiểm sát cùng cấp.

Theo yêu cầu của một bên và xét thấy phù hợp, Hội đồng xét đơn yêu cầu có thể tạm đình chỉ việc xem xét giải quyết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài trong thời hạn không quá 60 ngày để tạo điều kiện cho Hội đồng trọng tài khắc phục sai sót tố tụng trọng tài theo quan điểm của Hội đồng trọng tài nhằm loại bỏ căn cứ hủy bỏ phán quyết trọng tài. Hội đồng trọng tài phải thông báo cho Tòa án biết về việc khắc phục sai sót tố tụng. Trường hợp Hội đồng trọng tài không tiến hành khắc phục sai sót tố tụng thì Hội đồng tiếp tục xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Trường hợp Hội đồng xét đơn yêu cầu ra quyết định hủy phán quyết trọng tài, các bên có thể thỏa thuận lại để đưa vụ tranh chấp đó ra giải quyết tại Trọng tài hoặc một bên có quyền khởi kiện tại Tòa án. Trường hợp Hội đồng xét đơn yêu cầu không hủy phán quyết trọng tài thì phán quyết trọng tài được thi hành. Trong mọi trường hợp, thời gian giải quyết tranh chấp tại Trọng tài, thời gian tiến hành thủ tục hủy phán quyết trọng tài tại Tòa án không

tính vào thời hiệu khởi kiện. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.

Lệ phí về yêu cầu Tòa án chỉ định Trọng tài viên, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài và những lệ phí khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về án phí và lệ phí tòa án.

4.3. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN⁵

4.3.1. Thẩm quyền của Tòa án

4.3.1.1. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

- Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

- Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp của công ty hay thành viên công ty.

- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

- Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác.

4.3.1.2. Những yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

- Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

- Yêu cầu bắt giữ tàu bay, bắt giữ tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam.

- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.

- Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp theo quy định của pháp

⁵ Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

luật thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác.

4.1.1.3. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện⁶

(i) Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

(ii) Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

Yêu cầu về kinh doanh thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

(iii) Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản (i), (ii) này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện.

4.3.1.4. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(i) Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây:

a) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

b) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại 31 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trừ những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

c) Tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

(ii) Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

4.3.1.5. Thẩm quyền của các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:

a) Sơ thẩm những vụ việc kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

b) Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định kinh doanh, thương mại chưa có hiệu lực của Tòa án cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

⁶ Điều 35 Bộ luật TTDS 2015.

4.3.1.6. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

(i) Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

(ii) Thẩm quyền giải quyết việc dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi người phải thi hành bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài cư trú, làm việc, nếu người phải thi hành án là cá nhân hoặc nơi người phải thi hành án có trụ sở, nếu người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án nước ngoài;

b) Tòa án nơi người gửi đơn cư trú, làm việc, nếu người gửi đơn là cá nhân hoặc nơi người gửi đơn có trụ sở, nếu người gửi đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết yêu cầu không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

c) Tòa án nơi người phải thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài cư trú, làm việc, nếu người phải thi hành là cá nhân hoặc nơi người phải thi hành có trụ sở, nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài;

d) Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ giải quyết các yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

(iii) Trường hợp vụ án dân sự đã được Tòa án thụ lý, giải quyết theo đúng quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định thì phải được Tòa án đó tiếp tục giải quyết mặc dù trong quá trình giải quyết vụ án có sự thay đổi nơi cư trú, trụ sở hoặc địa chỉ giao dịch của đương sự.

4.3.1.7. Thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu

Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương

mại trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết;

b) Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết;

c) Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết;

d) Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết;

đ) Nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;

e) Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có một trong các bất động sản giải quyết.

4.3.1.8. Chuyển vụ việc dân sự cho Tòa án khác; giải quyết tranh chấp về thẩm quyền

Vụ việc kinh doanh, thương mại đã được thụ lý mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án đã thụ lý thì Tòa án đó ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự cho Tòa án có thẩm quyền và xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý. Quyết định này phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp, đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị quyết định này trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị, Chánh án Tòa án đã ra quyết định chuyển vụ việc dân sự phải giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Quyết định của Chánh án Tòa án là quyết định cuối cùng.

Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau hoặc giữa các Tòa án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao giải quyết.

4.3.1.9. Nguyên tắc giải quyết các vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

(i) Áp dụng tập quán

Tòa án được áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định. Tập quán không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.

Khi yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án xem xét áp dụng.

Tòa án có trách nhiệm xác định giá trị áp dụng của tập quán bảo đảm đúng quy định tại khoản 1 Điều 5 của Bộ luật dân sự.

(ii) Áp dụng tương tự pháp luật

Tòa án được áp dụng tương tự pháp luật để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của quan hệ dân sự mà các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định trực tiếp và không có tập quán được áp dụng theo quy định tại Điều 5 của Bộ luật dân sự và tại khoản (i) này.

Khi áp dụng tương tự pháp luật, Tòa án phải xác định rõ tính chất pháp lý của vụ việc dân sự, phải xác định một cách chắc chắn rằng trong hệ thống pháp luật hiện hành không có quy phạm pháp luật nào điều chỉnh quan hệ đó.

(iii) Áp dụng nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ và lẽ công bằng

Tòa án áp dụng nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ và lẽ công bằng để giải quyết vụ việc dân sự khi không thể áp dụng tương tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Bộ luật dân sự và khoản (ii) này.

Nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là những nguyên tắc được quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.

Án lệ là quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, trong đó chứa đựng sự giải thích, áp dụng pháp luật đã được Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn, công nhận và công bố là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ phải được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị và sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đó.

4.3.2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

Cơ quan tiến hành tố tụng gồm có:

- a) Tòa án nhân dân;
- b) Viện kiểm sát nhân dân.

Những người tiến hành tố tụng gồm có:

- a) Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án;
- b) Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.

Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

- Họ đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự;
- Họ đã tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vụ án đó;
- Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

4.3.3. Thành phần hội đồng xét xử

(i) Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Trong trường hợp đặc biệt thì Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm nhân dân.

(ii) Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm ba Thẩm phán.

(iii) Việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn do 01 Thẩm phán tiến hành.

(iv) Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

- Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán hoặc toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao.

- Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm 05 Thẩm phán hoặc toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

4.3.4. Đương sự trong vụ việc kinh doanh, thương mại

Đương sự trong vụ án kinh doanh, thương mại là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến giải quyết vụ án.⁷

Đương sự trong việc kinh doanh, thương mại là người yêu cầu giải quyết việc dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến giải quyết việc dân sự.

4.3.5. Chứng minh và chứng cứ

4.3.5.1. Nghĩa vụ chứng minh

Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

⁷ Nguyên đơn trong vụ án kinh doanh, thương mại là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.

Cơ quan, tổ chức do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định khởi kiện vụ án kinh doanh, thương mại để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên đơn.

Bị đơn trong vụ án kinh doanh, thương mại là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án kinh doanh, thương mại là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong trường hợp việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

b) Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp, giao nộp được cho Tòa án các tài liệu, chứng cứ vì lý do các tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án.

c) Các trường hợp pháp luật có quy định khác về nghĩa vụ chứng minh.

Đương sự phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải thể hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho sự phản đối đó.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước hoặc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc khởi kiện, yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

4.3.5.2. Những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh

Những tình tiết, sự kiện sau đây không phải chứng minh:

- a) Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Tòa án thừa nhận;
- b) Những tình tiết, sự kiện đã được xác định trong các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật;
- c) Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, chứng thực hợp pháp. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ tính khách quan của những tình tiết, sự kiện này hoặc tính khách quan của văn bản công chứng, chứng thực thì Thẩm phán có thể yêu cầu đương sự, cơ quan công chứng, chứng thực xuất trình bản gốc.

Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh.

Đương sự có người đại diện tham gia tố tụng thì sự thừa nhận của người đại diện được coi là sự thừa nhận của đương sự nếu không vượt quá phạm vi đại diện.

4.3.5.3. Chứng cứ

Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định mà Tòa án dùng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:⁸

- Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử;
- Các vật chứng;
- Lời khai của đương sự;
- Lời khai của người làm chứng;
- Kết luận giám định;
- Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ;
- Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản;
- Văn bản xác nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập;
- Văn bản công chứng, chứng thực;
- Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ giao nộp chứng cứ cho Tòa án; nếu đương sự không nộp hoặc nộp không đầy đủ chứng cứ do Tòa án yêu cầu mà không có lý do chính đáng thì Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ mà các đương sự đã giao nộp và Tòa án đã thu thập theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 để giải quyết.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình thu thập chứng cứ bằng những biện pháp sau đây:

- a) Thu thập tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được; thông điệp dữ liệu điện tử;
- b) Thu thập vật chứng;
- c) Xác định người làm chứng và lấy xác nhận của người làm chứng;
- d) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho sao chép những tài liệu có liên quan đến việc giải quyết vụ án mà cơ quan, tổ chức, cá nhân đó đang lưu giữ;
- đ) Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chứng thực lời khai của người làm chứng;
- e) Yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ nếu đương sự không thể thu thập tài liệu, chứng cứ;
- g) Yêu cầu giám định, định giá, thẩm định giá;
- h) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự. Quyền tự yêu cầu giám định được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

⁸ Việc xác thực chứng cứ được thực hiện theo quy định tại Điều 95 Bộ luật TTDS 2015.

Trong trường hợp chứng cứ bị tố cáo là giả mạo thì người đưa ra chứng cứ đó có quyền rút lại; nếu không rút lại thì người tố cáo có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Tòa án có quyền quyết định trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 102 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Đương sự có quyền cung cấp giá tài sản đang tranh chấp; thỏa thuận về giá tài sản đang tranh chấp. Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản tiến hành thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án. Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản. Báo cáo kết quả thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định giá được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật.

Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ. Khi yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ thì đương sự phải làm văn bản yêu cầu ghi rõ chứng cứ cần cung cấp; lý do cung cấp chứng cứ; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ cần cung cấp đó. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp chứng cứ cho đương sự trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp không cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người có yêu cầu biết. Trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được thì có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ chứng cứ cung cấp chứng cứ cho mình hoặc tiến hành thu thập chứng cứ nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự đúng đắn. Đương sự yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ phải làm đơn ghi rõ vấn đề cần chứng minh; chứng cứ cần thu thập; lý do vì sao tự mình không thu thập được; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ cần thu thập đó.

4.3.6. Các biện pháp khẩn cấp, tạm thời

4.3.6.1. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 187 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có quyền yêu cầu Tòa án đang giải quyết vụ án đó áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được hoặc bảo đảm việc thi hành án.

Trong trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó.

Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong trường hợp quy định tại Điều 135 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

4.3.6.2. Thẩm quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi mở phiên tòa do một Thẩm phán xem xét, quyết định.

Việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời tại phiên tòa do Hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

4.3.6.3. Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình. Trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.

Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì Tòa án phải bồi thường nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Tòa án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
- b) Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu;
- c) Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tòa án chậm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không có lý do chính đáng, gây thiệt hại cho người có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án phải bồi thường thiệt hại.

4.3.6.4. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

- Kê biên tài sản đang tranh chấp: Kê biên tài sản đang tranh chấp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản. Tài sản bị kê biên có thể được thu giữ, bảo quản tại cơ quan thi hành án hoặc lập biên bản giao cho một bên đương sự hoặc người thứ ba quản lý cho đến khi có quyết định của Tòa án.

- Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp: được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp cho người khác.

- Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp: được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tháo gỡ, lắp ghép, xây dựng thêm hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng tài sản đó.

- Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác: được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có tài sản đang tranh chấp hoặc liên quan đến tranh chấp mà có hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác ở thời kỳ thu hoạch hoặc không thể bảo quản được lâu dài.

- Phong toả tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong toả tài sản ở nơi gửi giữ: được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người có nghĩa vụ có tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc bảo đảm cho việc thi hành án.

- Phong toả tài sản của người có nghĩa vụ: được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người có nghĩa vụ có tài sản và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc bảo đảm cho việc thi hành án.

- Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện hành vi nhất định: được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoặc không thực hiện một số hành vi nhất định làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có liên quan trong vụ án đang được Tòa án giải quyết.

- Cấm người có nghĩa vụ đối với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân xuất cảnh: được áp dụng nếu có căn cứ cho thấy việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ của họ đối với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc để bảo đảm thi hành án.

- Tạm dừng việc đóng thầu, phê duyệt danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật đấu thầu: được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án nếu cho thấy việc áp dụng các biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

- Bắt giữ tàu biển, trừ bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, thi hành án dân sự, thực hiện tương trợ tư pháp; bắt giữ tàu bay.⁹

- Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật có quy định.

Trong trường hợp do pháp luật quy định, Tòa án có trách nhiệm giải quyết yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định tại khoản 17 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

4.3.6.5. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

(i) Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải làm đơn gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải có các nội dung chính sau đây:

- a) Ngày, tháng, năm viết đơn;
- b) Tên, địa chỉ; số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
- c) Tên, địa chỉ; số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

⁹ Xem chi tiết tại Điều 131 Bộ luật TTDS 2015.

d) Tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

đ) Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

e) Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

Tuỳ theo yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu phải cung cấp cho Tòa án chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

Trong trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 10, khoản 11 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì chỉ được phong toả tài khoản, tài sản có giá trị tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa vụ phải thực hiện.

Cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích của người khác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 187 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 kiến nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do kiến nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng; tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích hợp pháp cần được bảo vệ; tên, địa chỉ của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; chứng cứ để chứng minh cho việc kiến nghị của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 trong trường hợp đương sự không có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

4.3.6.6. Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm

Người yêu cầu Tòa án áp dụng một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại các khoản 6, 7, 8, 10, 11, 15 và 16 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 phải nộp cho Tòa án chứng từ bảo lãnh bằng tài sản của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Tòa án ấn định nhưng phải tương đương với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh do hậu quả của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng để bảo vệ lợi ích của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và ngăn ngừa sự lạm dụng quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ phía người có quyền yêu cầu.

Khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá phải được gửi vào tài khoản phong toả tại ngân hàng nơi có trụ sở của Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong thời hạn do Tòa án ấn định. Trong trường hợp thực hiện biện pháp bảo đảm vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ thì khoản tiền bảo đảm được gửi giữ tại Tòa án. Tòa án phải làm thủ tục giao nhận và gửi ngay khoản tiền đó vào ngân hàng vào ngày làm việc tiếp theo.

4.3.6.7. Thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời

Khi xét thấy biện pháp khẩn cấp tạm thời đang được áp dụng không còn phù hợp mà cần thiết phải thay đổi hoặc áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời khác thì thủ tục thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời khác được thực hiện theo quy định tại

Điều 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

4.3.6.8. Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Tòa án ra ngay quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng khi có một trong các trường hợp sau đây:

- a) Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị huỷ bỏ;
- b) Người phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nộp tài sản hoặc có người khác thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành nghĩa vụ đối với bên có yêu cầu;
- c) Nghĩa vụ dân sự của bên có nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của Bộ luật dân sự;
- d) Vụ án được đình chỉ theo quy định tại Điều 217 và Điều 295 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;
- đ) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;
- e) Căn cứ của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không còn;
- g) Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- h) Các trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Trong trường hợp huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, Tòa án phải xem xét, quyết định để người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhận lại chứng từ bảo lãnh bằng tài sản của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác hoặc khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá bảo đảm quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Thủ tục ra quyết định huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Trường hợp đã có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì việc giải quyết yêu cầu huỷ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Chánh án của Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phân công một Thẩm phán giải quyết.

Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu lực thi hành ngay. Tòa án phải cấp hoặc gửi quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay sau khi ra quyết định cho người có yêu cầu, người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và Viện kiểm sát cùng cấp.

4.3.6.9. Khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ án về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc việc Thẩm phán không ra quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. Thời hạn khiếu nại, kiến nghị là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định áp

dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc trả lời của Thẩm phán về việc không ra quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

4.3.7. Thời hiệu tố tụng

4.3.7.1. Thời hạn tố tụng

Thời hạn tố tụng là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác để người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hành vi tố tụng do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định.

Thời hạn tố tụng có thể được xác định bằng giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể xảy ra.

4.3.7.2. Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự về thời hạn

Cách tính thời hạn tố tụng, quy định về thời hạn tố tụng, thời điểm bắt đầu, kết thúc thời hạn tố tụng trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 được áp dụng theo các quy định tương ứng của Bộ luật dân sự.

4.3.7.3. Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.3.8. Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm

4.3.8.1. Khởi kiện và thụ lý

4.3.8.1.1. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

4.3.8.1.2. Phạm vi khởi kiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

Nhiều cơ quan, tổ chức cá nhân có thể cùng khởi kiện một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định có thể khởi kiện đối với một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

4.3.8.1.3. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

- a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
- b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
- c) Tên, nơi cư trú, làm việc (nếu có) của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
- d) Tên, nơi cư trú, làm việc (nếu có) của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
- đ) Tên, nơi cư trú, làm việc (nếu có) của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trong trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
- e) Tên, nơi cư trú, làm việc (nếu có) của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
- g) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có).

Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp các tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

4.3.8.1.4. Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

Người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

- a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;
- b) Gửi đến Tòa án qua dịch vụ bưu chính;
- c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử trong trường hợp Tòa án áp dụng hình thức nhận đơn trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án hoặc ngày có dấu của tổ chức bưu chính nơi gửi. Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện được xác định như sau:

- a) Trường hợp ngày Tòa án nhận được đơn do tổ chức bưu chính chuyển đến mà thời

hiệu khởi kiện vẫn còn thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn do tổ chức bưu chính chuyển đến;

b) Trường hợp ngày Tòa án nhận được đơn do tổ chức bưu chính chuyển đến mà thời hiệu khởi kiện đã hết thì Tòa án phải tiến hành xác minh ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức bưu chính. Trường hợp xác minh được ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức bưu chính thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức bưu chính ; trường hợp không xác minh được ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức bưu chính thì ngày khởi kiện là ngày ghi trong đơn khởi kiện;

c) Trường hợp người khởi kiện gửi đơn trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn;

d) Trường hợp chuyển vụ án cho Tòa án khác theo quy định tại Điều 41 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn khởi kiện đến Tòa án đã thụ lý nhưng không đúng thẩm quyền và được xác định theo quy định tại điểm a, điểm b và c khoản 2 Điều này.

4.3.8.1.5. Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trường hợp Tòa án nhận đơn trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn. Đơn khởi kiện ngoài việc ghi vào sổ nhận đơn đồng thời được ghi vào sổ nhận đơn trên máy vi tính và thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn qua thư điện tử thì Tòa án trả lời cho người khởi kiện biết qua thư điện tử. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây:

a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn theo quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

4. Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định tại khoản 3 Điều này phải được thông báo cho người khởi kiện, phải ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

4.3.8.1.6. Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện

Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp sau đây:

a) Người khởi kiện không có quyền khởi kiện theo quy định tại Điều 186 và Điều 187 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự;

b) Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Chưa có đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp pháp luật có quy định về các điều kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó.

c) Sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp vụ án mà Tòa án bác đơn xin ly hôn, xin thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, xin thay đổi người quản lý tài sản, thay đổi người quản lý di sản; hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu mà theo quy định của pháp luật được quyền khởi kiện lại;

d) Hết thời hạn được thông báo quy định tại khoản 2 Điều 195 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng;

đ) Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;

e) Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án quy định tại khoản 2 Điều 193 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

g) Người khởi kiện rút đơn khởi kiện.

Khi trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Thẩm phán phải có văn bản nêu rõ lý do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Đơn khởi kiện và các tài liệu mà Tòa án trả lại cho người khởi kiện phải được sao lại và lưu tại Tòa án để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu.

4.3.8.1.7. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Trong trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện biết để họ sửa đổi, bổ sung trong một thời hạn do Thẩm phán ấn định, nhưng không quá 30 ngày; trong trường hợp đặc biệt, Thẩm phán có thể gia hạn, nhưng không quá 15 ngày. Văn bản thông báo có thể được giao trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc gửi cho người khởi kiện qua dịch vụ bưu chính và phải ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không tính vào thời hiệu khởi kiện.

Trong trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Thẩm phán tiếp tục việc thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài

liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện.

4.3.8.1.8. Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Toà án đã trả lại đơn khởi kiện.

Ngay sau khi nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Toà án phải phân công một Thẩm phán khác xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có khiếu nại. Trường hợp đương sự vắng mặt thì Thẩm phán vẫn tiến hành phiên họp.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn khởi kiện, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và đương sự có khiếu nại tại phiên họp, Thẩm phán phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện và thông báo cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp biết;

b) Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trả lời khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện của Thẩm phán, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện;

b) Yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng. Quyết định của Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp phải được gửi ngay cho người khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát đã kiến nghị và Tòa án đã ra quyết định trả lại đơn khởi kiện.

4.3.8.1.9. Thụ lý vụ án

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Đối với vụ án do người tiêu dùng khởi kiện thì Tòa án phải niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án thông tin về việc thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ

án.

Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào phiếu báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

4.3.8.2. Thủ tục hòa giải và chuẩn bị xét xử

4.3.8.2.1. Thời hạn chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án quy định tại Điều 30 (trừ các vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài) là hai tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a và 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

4.3.8.2.2. Nguyên tắc tiến hành hoà giải

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hoà giải hoặc không tiến hành hoà giải được quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Việc hoà giải được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tôn trọng sự tự nguyện thoả thuận của các đương sự, không được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bắt buộc các đương sự phải thoả thuận không phù hợp với ý chí của mình;

b) Nội dung thoả thuận giữa các đương sự không được trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.

4.3.8.2.3. Ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự

Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.

Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự nếu các

đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.

Trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 210 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 mà các đương sự có mặt thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì thoả thuận đó chỉ có giá trị đối với những người có mặt và được Thẩm phán ra quyết định công nhận nếu không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt. Trong trường hợp thoả thuận của họ có ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì thoả thuận này chỉ có giá trị và được Thẩm phán ra quyết định công nhận nếu được đương sự vắng mặt tại phiên hoà giải đồng ý bằng văn bản.

Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng sự thoả thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa hoặc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

4.3.8.2.4. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải có các nội dung chính sau đây:

- a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
- b) Tên Tòa án ra quyết định;
- c) Vụ án được đưa ra xét xử;
- d) Tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn hoặc người khác khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- đ) Họ, tên Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án và họ, tên Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân dự khuyết, nếu có;
- e) Họ, tên Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên dự khuyết, nếu có;
- g) Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa;
- h) Xét xử công khai hoặc xét xử kín;
- i) Họ, tên những người được triệu tập tham gia phiên tòa.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho các đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

Trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Tòa án phải gửi hồ sơ vụ án cùng quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát cùng cấp; trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viện kiểm sát phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ cho Tòa án.

4.3.8.3. Phiên tòa sơ thẩm

4.3.8.3.1. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt thì

Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Tòa án thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự biết việc hoãn phiên tòa.

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, nếu vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng thì xử lý như sau:

a) Nguyên đơn vắng mặt thì coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;

b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

c) Bị đơn có yêu cầu phản tố thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố, Tòa án quyết định đình chỉ phần phản tố, trừ trường hợp có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;

d) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập của mình và Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;

đ) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

4.3.8.3.2. Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa

Tranh tụng tại phiên tòa bao gồm việc trình bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời và phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án dân sự, quan hệ pháp luật tranh chấp và pháp luật áp dụng giải quyết các yêu cầu của các đương sự trong vụ án.

Việc tranh tụng tại phiên tòa được tiến hành theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh tụng, tạo điều kiện cho những người tham gia tranh tụng trình bày hết ý kiến, nhưng có quyền cắt những ý kiến không có liên quan đến vụ án dân sự.

4.3.8.3.3. Nghị án và tuyên án

Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án. Chỉ có các thành viên của Hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, các thành viên của Hội đồng xét xử phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật, (nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì căn cứ vào án lệ dân sự có liên quan, tập quán, tương tự pháp luật, lẽ công bằng) để giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề. Hội thẩm nhân dân biểu quyết trước, Thẩm phán biểu quyết sau cùng. Người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được đưa vào hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án có mặt các đương sự. Trường hợp đương sự có mặt tại phiên tòa nhưng vắng mặt khi tuyên án hoặc vắng mặt theo quy định tại khoản 4 Điều 264 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Hội đồng xét xử vẫn tuyên đọc bản án.

4.3.9. Thủ tục xét xử phúc thẩm

Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị.

4.3.9.1. Người có quyền kháng cáo

Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm đơn kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.¹⁰

4.3.9.2. Thời hạn kháng cáo

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết. Đối với trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo kể từ ngày tuyên án.

Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú hoặc nơi có trụ sở trong trường hợp người có quyền kháng cáo là cơ quan, tổ chức.

Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào ngày dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được xác nhận của giám thị trại giam.

4.3.9.3. Thời hạn kháng nghị

Thời hạn kháng nghị đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 10 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày, kể từ ngày tuyên án. Trường hợp Kiểm sát viên không tham gia phiên tòa thì thời hạn kháng nghị tính từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản án.

Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 10 ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định.

Trường hợp tại thời điểm nhận được quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát mà đã quá thời hạn theo quy định trên thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu Viện kiểm sát giải thích bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.3.9.4. Thủ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

¹⁰ Về đơn kháng cáo, xem Điều 272 Bộ luật TTDS 2015.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng xét xử phúc thẩm và phân công một Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa.

4.3.9.5. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm

Trừ vụ án xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài, thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được quy định như sau:

(i) Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, Tòa án cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây:

- a) Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án;
- b) Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án;
- c) Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

(ii) Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 01 tháng.

(iii) Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm; trong trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

(iv) Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị.

(v) Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

4.3.9.6. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm

Hội đồng xét xử phúc thẩm có các quyền sau đây:

- Giữ nguyên bản án sơ thẩm;
- Sửa bản án sơ thẩm;
- Hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án;
- Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án;
- Đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
- Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án khi có văn bản của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà

nước cấp trên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời Tòa án kết quả xử lý.

4.3.10. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn

4.3.10.1. Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn

Thủ tục rút gọn là thủ tục tố tụng được áp dụng để giải quyết các vụ án dân sự có đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 với trình tự đơn giản so với thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thông thường nhằm giải quyết vụ án nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm đúng pháp luật.

4.3.10.2. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn

(i) Tòa án giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Vụ án có tính tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ đầy đủ, rõ ràng, đủ cơ sở giải quyết Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ;

b) Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng;

c) Không có đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài có thỏa thuận với đương sự ở Việt Nam đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn hoặc các đương sự đã xuất trình được chứng cứ về sở hữu hợp pháp tài sản và có thỏa thuận thống nhất về việc xử lý tài sản.

Đối với vụ án lao động được thụ lý, giải quyết theo thủ tục rút gọn mà người sử dụng lao động có quốc tịch nước ngoài đã rời khỏi địa chỉ nơi cư trú, nơi có trụ sở mà không thông báo cho đương sự khác, Tòa án biết thì được coi là trường hợp cố tình giấu địa chỉ. Tòa án vẫn giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại Phần này.

(ii) Trong quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn, nếu xuất hiện tình tiết mới sau đây làm cho vụ án không còn đủ điều kiện để áp dụng theo thủ tục rút gọn thì Tòa án ra quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường:

a) Phát sinh các tình tiết mới dẫn đến cần phải xác minh, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ hoặc cần phải tiến hành giám định;

b) Cần phải định giá, thẩm định giá tài sản tranh chấp mà các đương sự không thống nhất về giá hoặc chưa tự tiến hành định giá, thẩm giá tài sản;

c) Cần phải thực hiện Ủy thác tư pháp;

d) Cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

đ) Phát sinh người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

e) Phát sinh yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập;

g) Phát sinh đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản (i) này.

4.3.10.3. Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn

Trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định tại Điều 195 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án

phải ra quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn và mở phiên tòa xét xử trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định.

4.3.10.4. Hiệu lực của bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn

Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án theo thủ tục rút gọn có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

4.3.11. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp

4.3.11.1. Giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định tại Điều 326 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:

a) Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

b) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;

c) Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra quyết định, bản án không đúng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

Người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật khi có một trong các căn cứ quy định trên và có đơn đề nghị theo quy định tại Điều 328 và Điều 329 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; trường hợp xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba thì không cần thiết phải có đơn đề nghị.¹¹

Trong thời hạn một năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với những người có quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Trường hợp Tòa án, Viện kiểm sát hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản

¹¹ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì phải thông báo bằng văn bản cho người có quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nếu phát hiện có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 326 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Thời hạn kháng nghị Giám đốc thẩm: Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quyền kháng nghị trong thời hạn ba năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị theo quy định nhưng có các điều kiện sau đây thì thời hạn kháng nghị được kéo dài thêm hai năm, kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị:

a) Đương sự đã có đơn đề nghị theo quy định tại khoản 1 Điều 327 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và sau khi hết thời hạn kháng nghị quy định tại khoản 1 Điều này đương sự vẫn tiếp tục có đơn đề nghị;

b) Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 326 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, của người thứ ba, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị để khắc phục sai lầm trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó.

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có các quyền sau đây:

- Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa;
- Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại;
- Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã xét xử vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án;
- Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

4.3.11.2. Tái thẩm

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:

- Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án.
- Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ;
- Thảm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố

ý kết luận trái pháp luật;

- Bản án, quyết định hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước mà Tòa án căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị huỷ bỏ.

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là một năm, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy định tại Điều 352 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Hội đồng tái thẩm có các quyền sau đây:

- Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật;
- Huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định;
- Huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án.

CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN

5.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁ SẢN VÀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN

Các học thuyết về kinh tế thị trường hiện đại đều kết luận rằng: tự do kinh doanh, cạnh tranh và chống độc quyền, phá sản là những hiện tượng kinh tế - xã hội có tính quy luật của nền kinh tế thị trường hiện đại. Ba hiện tượng này có liên hệ tương hỗ với nhau và chuyển hoá cho nhau. Bởi vậy, để giải quyết những vấn đề về phá sản không thể không chú ý đúng mức đến vấn đề về tự do kinh doanh cũng như cạnh tranh và chống độc quyền.

Trong điều kiện của kinh tế thị trường, một doanh nghiệp không đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe, nghiêm ngặt của thương trường, thì doanh nghiệp đó sẽ bị đào thải. Cơ chế đào thải những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, đồng thời phòng ngừa, khắc phục những hậu quả và những rủi ro của những doanh nghiệp này gây ra là cơ chế phá sản. ở góc độ tiếp cận này, phá sản là yếu tố tự hiệu chỉnh bên trong của thị trường.

Phá sản được hiểu là sự đổ vỡ trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Phá sản - với tính cách là một hiện tượng có tính quy luật trong cơ chế kinh tế thị trường - trong một thời gian dài đã được nhiều nước khuyến khích vì hiểu theo nghĩa lợi ích chung của nền kinh tế thì nó giúp cơ cấu lại nền kinh tế quốc dân thông qua việc “nhổ đi những cỏ dại trong một vườn hoa đẹp”. Tuy nhiên, chỉ đến những năm cuối của thập kỷ 70 và sang những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, sự vận động của các nền kinh tế phát triển và nền kinh tế thế giới đã làm cho nhiều quốc gia phải hoài nghi về những lợi ích do phá sản đem lại. Quá trình phân công lao động ngày càng theo chiều rộng và chiều sâu ở mỗi thị trường quốc gia và thị trường toàn cầu đã làm tính phụ thuộc giữa các doanh nghiệp ngày càng lớn. Sự xuất hiện các công ty đa quốc gia cùng với quá trình toàn cầu hoá đã từng bước xoá nhoà đường biên giới về thị trường giữa các quốc gia trên thế giới và vì vậy làm cho tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các doanh nghiệp ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn. Trong bối cảnh như vậy, phá sản không còn là chuyện riêng của doanh nghiệp bị phá sản vì nó có liên quan đến các mặt kinh tế, chính trị và xã hội. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại phá sản được nhìn nhận là một hiện tượng xã hội tiêu cực khi xem xét các tác động của chúng trên các phương diện sau:

- Về mặt kinh tế, sự phá sản của một doanh nghiệp trong điều kiện ngày nay đều đưa đến những hậu quả tiêu cực. Nhiều doanh nghiệp phải gánh chịu hậu quả to lớn khi những đối tác làm ăn của mình bị phá sản. Khi quy mô của doanh nghiệp phá sản càng lớn, tham gia vào quá trình phân công lao động của ngành nghề đó càng sâu và rộng, số lượng bạn hàng ngày càng đông, thì sự phá sản của nó có thể dẫn đến sự phá sản hàng loạt của các doanh nghiệp bạn hàng theo “hiệu ứng Domino” - phá sản dây chuyền.

- Về mặt xã hội, doanh nghiệp phá sản để lại nhiều hậu quả tiêu cực về mặt xã hội. Một mặt nó làm tăng số lượng những người thất nghiệp và làm cho sức ép về việc làm ngày càng lớn, đặc biệt là ở các đô thị lớn và các khu công nghiệp. Trên thực tế, gánh nặng giải quyết việc làm, đào tạo lại nghề cho những người thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp... lại được chuyển giao cho nhà nước. Mặt khác, tỷ trọng người thất nghiệp cao do phá sản đem lại luôn ẩn chứa những nguy cơ bất ổn định về mặt xã hội và nếu như không giải quyết kịp thời sẽ trở thành nguyên nhân của các tệ nạn xã hội, các tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

- Về mặt chính trị, phá sản dây chuyền sẽ dẫn tới sự suy thoái và khủng hoảng nền kinh tế quốc gia, thậm chí là khủng hoảng kinh tế khu vực và đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những khủng hoảng sâu sắc về chính trị.

Nếu căn cứ vào nội dung của các tiêu chí xác định một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, thực tiễn điều chỉnh pháp luật về phá sản của các nước trên thế giới hiện nay đã và đang tiếp tục sử dụng ba tiêu chí sau đây:

- Tiêu chí “định lượng”: Theo tiêu chí này một doanh nghiệp bị coi là lâm vào tình trạng phá sản khi không thanh toán được một món nợ đến hạn có giá trị tối thiểu đã được ấn định trong luật phá sản. Theo Luật Phá sản của Vương quốc Anh số tiền này là 50 bảng, ở Singapore là trên 2.000 đôla... Ban đầu, tiêu chí “định lượng” được thiết kế nhằm hạn chế bớt những đối tượng cần phải áp dụng luật phá sản. Mặt khác, cách làm này đã cho phép toà án có thể mở thủ tục phá sản doanh nghiệp đối với bất cứ trường hợp nào mà không cần phải điều tra về tình hình tài chính của doanh nghiệp mắc nợ. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy, trong quá trình thực hiện tiêu chí “định lượng” cũng bộc lộ nhiều hạn chế, đó là: không bảo đảm tính chính xác trong việc đánh giá tình trạng tài chính của doanh nghiệp mắc nợ vì nhiều doanh nghiệp do những nguyên nhân khác nhau có thể mất khả năng thanh toán nhất thời; doanh nghiệp mắc nợ trước sức ép của thủ tục phá sản đã buộc phải bán tài sản của mình với mức giá quá thấp hoặc phải đi đến những thoả hiệp bất bình đẳng trước sức ép của các chủ nợ...

- Tiêu chí “kế toán”: Tiêu chí này được thực hiện thông qua sổ sách kế toán của doanh nghiệp mắc nợ. Nếu như các số liệu kế toán của doanh nghiệp cho thấy tổng giá trị tài sản nợ lớn hơn tổng giá trị tài sản có thì doanh nghiệp đó đã lâm vào tình trạng phá sản. So với tiêu chí “định lượng”, tiêu chí “kế toán” đã phản ánh chính xác hơn tình trạng tài chính của doanh nghiệp mắc nợ và do đó nó cho phép thu hẹp hơn phạm vi những doanh nghiệp bị mở thủ tục phá sản. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế vì có nhiều doanh nghiệp do những nguyên nhân khác nhau có thể mất khả năng thanh toán nợ tại một thời điểm nhất định nào đó mà khi có sự mất cân đối nghiêm trọng giữa tài sản cố định và tài sản lưu động của mình.

- Tiêu chí định tính “mất khả năng thanh toán”: Tiêu chí này quan tâm trực tiếp đến tính “tức thời của việc trả nợ”, khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp mắc nợ mà không dành sự quan tâm của mình đến số lượng tài sản hiện có của doanh nghiệp mắc nợ. ở góc độ tài chính - kế toán, tiêu chí này chỉ xem xét chủ yếu đến dòng tiền (cash flow) của doanh nghiệp mắc nợ khi đánh giá khả năng thanh toán của họ. Như vậy, với tiêu chí này, doanh nghiệp bị phá sản không chỉ là những doanh nghiệp không còn hoặc còn rất ít tài sản mà thậm chí còn rất nhiều tài sản song vì nhiều nguyên nhân khác nhau không hoặc chưa thể hiện thực hoá số tài sản đó ngay. So với hai tiêu chí đã được trình bày trên, tiêu chí này đã làm cho khả năng mở thủ tục phá sản đối với một doanh nghiệp đến sớm hơn để có thể có những giải pháp “phục hồi” hoặc cho phá sản doanh nghiệp đó một cách kịp thời nhằm bảo vệ một cách có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân doanh nghiệp mắc nợ và các chủ nợ, ngăn chặn hiện tượng phá sản dây chuyền.

Tiêu chí định tính “mất khả năng thanh toán” được sử dụng cả trong thủ tục phá sản mang tính chất của luật công và thủ tục phá sản mang tính chất của luật tư. Trong thủ tục phá sản mang tính chất của luật tư, việc chứng minh doanh nghiệp mắc nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán là công việc của các chủ nợ (trong trường hợp phá sản bắt buộc) và là nghĩa vụ của doanh

nghiệp mắc nợ (trong trường hợp phá sản tự nguyện). Trong thủ tục phá sản mang tính chất của luật công, việc chứng minh doanh nghiệp mắc nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hay không là công việc của toà án dựa trên sự đề nghị của các chủ nợ hoặc doanh nghiệp mắc nợ.¹

Luật phá sản được nhiều chuyên gia và nhà quản lý kinh tế xem là một công cụ sàng lọc doanh nghiệp, hạn chế những doanh nghiệp quá yếu kém, được coi là việc bình thường, không thể tránh khỏi trong nền kinh tế thị trường. Phá sản có thể coi là sự “tàn phá sáng tạo” (Joseph Alois Schumpeter), vì trong quá trình phá sản, nhà xưởng vẫn còn, đội ngũ người lao động vẫn tồn tại, chỉ có ông chủ không trả được nợ sẽ bị thay thế bằng một ông chủ khác mạnh hơn, giỏi hơn...

Luật phá sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2004 và thay thế Luật phá sản doanh nghiệp ngày 30/12/1993. Sau chín năm thi hành Luật phá sản năm 2004, có thể nói Luật Phá sản 2004 đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây viết tắt là DN, HTX) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. Bảo đảm trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản của DN, HTX, các chủ nợ và người lao động một cách dân chủ, công khai, thuận lợi cho người tiến hành thủ tục phá sản, người yêu cầu và các bên có liên quan thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; đề cao vai trò, trách nhiệm của DN, HTX và các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN, HTX. Bên cạnh đó, Luật Phá sản 2004 đã thể hiện được vai trò là một trong những công cụ pháp lý quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong việc thể chế hóa chính sách kinh tế của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, HTX đang trong tình trạng sản xuất kinh doanh khó khăn, thua lỗ có cơ hội để rút khỏi thị trường một cách có trật tự; thúc đẩy sự lưu thông vốn trong nền kinh tế thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và các chủ nợ. Tuy nhiên, theo tổng kết thi hành Luật phá sản 2004 thấy rằng, sau chín năm áp dụng Luật phá sản 2004 đã bộc lộ một số hạn chế tác động tiêu cực đến việc thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của DN, HTX, nền tảng của hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế; có những quy định của Luật Phá sản 2004 mâu thuẫn, chưa tương thích với các văn bản quy phạm pháp luật khác; có những quy định chưa phù hợp (hoặc không còn phù hợp), chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng và còn có những cách hiểu khác nhau; có những quy định chưa đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu mở thủ tục phá sản cũng như DN, HTX bị yêu cầu tuyên bố phá sản; có những

¹ Tại Mỹ pháp luật phá sản được xây dựng để bảo vệ những doanh nghiệp thua lỗ. Theo đó, những tổ chức, cá nhân kinh doanh thua lỗ được quyền mở thủ tục phá sản và được khuyến khích tiếp tục theo đuổi công việc kinh doanh sau đó. Ở Nhật, Luật Phá sản còn quy định sự phục quyền. Công ty phá sản vào bất cứ lúc nào đều có thể yêu cầu tòa án ra lệnh phục quyền khi đáp ứng được các quy định của pháp luật. Lệnh này được ban hành sẽ hủy bỏ tất cả các quyền đòi nợ khi đã trả tiền lãi, trừ một số khoản nợ như nợ thuế, các khoản tiền phạt hình sự. Ngoài ra, Nhật quy định tình trạng phá sản đối với pháp nhân là không có khả năng trả nợ khi khoản tiền nợ lớn hơn tài sản có của pháp nhân đó. Điều này giúp các doanh nghiệp bị mất cân đối tài chính tạm thời có thể xoay xở trả nợ nhằm tránh tình trạng phá sản hàng loạt. Trong khi đó, theo pháp luật Trung Quốc, khi doanh nghiệp không có khả năng thanh toán khoản nợ đến hạn thì sẽ bị xem xét khả năng phá sản.

quy định chưa tương thích với pháp luật quốc tế... dẫn đến hiệu quả áp dụng quy định Luật Phá sản 2004 vào thực tiễn không cao.²

Mặt khác, sau khi Luật phá sản 2004 được ban hành, ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.³ Bên cạnh đó, ngày 19/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013–2020, trên cơ sở tôn trọng, bảo đảm thực hiện bình đẳng quyền và nghĩa vụ của mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Triển khai tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 nêu trên và Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013–2020 của Chính phủ, nhận thức được những hạn chế, bất cập của thực tiễn thi hành Luật phá sản 2004, Tòa án nhân dân tối cao đã đề nghị và được Quốc hội quyết định đưa Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII (2011-2016). Có thể nói, việc triển khai xây dựng Luật Phá sản (sửa đổi) là cần thiết và cấp bách, nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của DN, HTX; đồng thời tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, tiếp tục từng bước hoàn thiện một cách căn bản hệ thống pháp luật kinh tế nói chung và Luật Phá sản nói riêng; khắc phục các quy định của Luật Phá sản chưa phù hợp, gây khó khăn cho việc áp dụng, cũng như các vấn đề mới phát sinh vướng mắc trong quá trình thực tiễn; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp

² Theo thống kê của TAND Tối cao, từ năm 2008 đến năm 2011, ngành tòa án đã nhận 636 đơn yêu cầu được phá sản. Trong đó, trả lại đơn 13 vụ, ra quyết định mở thủ tục phá sản 518 vụ, ra quyết định không mở thủ tục phá sản 9 vụ, ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản 18 vụ. Đặc biệt, Tòa án chỉ ra được quyết định tuyên bố phá sản 45 vụ. Có tới 12 trong số 52 TAND cấp tỉnh từ năm 2004 đến hết năm 2011 không thụ lý bất cứ yêu cầu phá sản nào. Báo cáo mới nhất (9/2013) của TAND Tối cao cũng cho thấy, qua tổng kết thi hành LPS của 63 TAND cấp tỉnh thì có 49 tòa án có nhận đơn và giải quyết tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản; 14 tòa án không nhận đơn, giải quyết đơn yêu cầu tuyên bố phá sản. Trong tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản được giải quyết này, Tòa án đã ra 236 quyết định mở thủ tục phá sản, trong đó ra 83 quyết định tuyên bố phá sản. Trong 83 quyết định tuyên bố phá sản có 7 trường hợp Tòa án ra quyết định tuyên bố DN, HTX bị phá sản trong trường hợp đặc biệt. Các tòa phúc thẩm TAND Tối cao nhận được 17 đơn khiếu nại các quyết định của TAND cấp tỉnh trong quá trình giải quyết phá sản và đã ra 9 quyết định giữ nguyên quyết định tuyên bố phá sản, 4 quyết định sửa và 4 quyết định hủy quyết định tuyên bố phá sản của TAND cấp tỉnh. Điều này cho thấy, mới chỉ có chưa đến 80 DN bị tuyên bố phá sản trong 9 năm qua, một tỷ lệ quá nhỏ bé so với số lượng DN giải thể, ngừng hoạt động. Xem thêm bình luận về vấn đề này <http://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/luat-pha-san-da-pha-san-12303.html>

³ Mục 3 Phần II về xây dựng và hoàn thiện pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh có nhận định: “Xác định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu nhà nước và các chủ sở hữu khác, cơ chế bảo đảm quyền sở hữu và hạn chế quyền sở hữu,... Hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền tự do kinh doanh theo nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Tạo cơ sở pháp luật để công dân tích cực huy động mọi tiềm năng, nguồn lực và phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và góp phần làm giàu cho đất nước. Tạo lập môi trường pháp lý cho cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, phù hợp với nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các cam kết quốc tế khác. Xây dựng một khung pháp luật chung cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, xóa bỏ đặc quyền và độc quyền kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; từng bước thống nhất pháp luật áp dụng đối với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo hướng tôn trọng thỏa thuận của các bên giao kết hợp đồng, không trái với đạo đức xã hội, không xâm phạm trật tự công cộng, phù hợp với tập quán, thông lệ thương mại quốc tế. Đổi mới cơ bản pháp luật về phá sản”.

của DN, HTX, cá nhân, cơ quan, tổ chức, đảm bảo thủ tục thương lượng, mở thủ tục phá sản, phục hồi DN, HTX, phá sản công khai, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng và đúng pháp luật.

Ngày 19/6/2014, Luật phá sản 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua. Luật phá sản 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015. Theo đó, Luật phá sản 2014 quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Về đối tượng áp dụng: Luật phá sản 2014 áp dụng đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Luật phá sản được áp dụng khi giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật phá sản 2014 thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

5.2. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁ SẢN

5.2.1. Khái niệm phá sản

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán (tức là không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán) và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.⁴

5.2.2. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Theo Luật phá sản 2014, những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm (Điều 5):

(i) Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.⁵

(ii) Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

⁴ Khoản 1, 2 Điều 4 Luật phá sản 2014.

⁵ Chủ nợ là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ, bao gồm chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần và chủ nợ có bảo đảm.

- Chủ nợ không có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.
- Chủ nợ có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.
- Chủ nợ có bảo đảm một phần là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó.

(iii) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

(iv) Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

(v) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

(vi) Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

5.2.3. Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 5 của Luật phá sản 2014.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức thông báo phải bảo đảm tính chính xác của thông báo. Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức cố ý thông báo sai mà gây thiệt hại cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

5.2.4. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc phá sản có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phá sản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.⁶

Cá nhân, cơ quan, tổ chức không cung cấp được tài liệu, chứng cứ theo quy định trên phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, nếu cố ý không cung cấp tài liệu, chứng cứ mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

5.2.5. Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân

(i) Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh

⁶ Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Xem thêm các Điều 12-17 Luật phá sản 2014. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hợp tác xã tại tỉnh đó và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

d) Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

(ii) Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và không thuộc trường hợp quy định tại khoản (i) này.

5.2.6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản

- Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp cần thiết.

- Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

- Quyết định chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Quyết định việc thực hiện kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong trường hợp cần thiết.

- Quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán sau khi mở thủ tục phá sản để bảo đảm chi phí phá sản.

- Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

- Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền dẫn giải đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức Hội nghị chủ nợ.

- Quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

- Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

- Quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

- Áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

- Tham khảo quyết định giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc phá sản tương tự theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

- Phải từ chối giải quyết phá sản nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật phá sản 2014.⁷

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5.2.7. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản

Người tham gia thủ tục phá sản là chủ nợ; người lao động; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ đông, nhóm cổ đông; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết phá sản.

Người tham gia thủ tục phá sản có các quyền, nghĩa vụ sau đây:⁸

- Thực hiện yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về phá sản.

- Cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc giải quyết phá sản.

- Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình để giao nộp cho Tòa án nhân dân.

- Đề nghị Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ mà tự mình không thể thực hiện được hoặc trưng cầu giám định, định giá, thẩm định giá tài sản; đề nghị Thẩm phán quyết định kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; đề nghị Thẩm phán triệu tập người làm chứng.

- Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người tham gia thủ tục phá sản khác xuất trình hoặc do Thẩm phán thu thập.

- Đề nghị áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

- Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

- Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

- Tham gia Hội nghị chủ nợ.

⁷ Thẩm phán phải từ chối tham gia giải quyết phá sản hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau:

a) Đồng thời là người tham gia thủ tục phá sản; người đại diện, người thân thích của người tham gia thủ tục phá sản trong vụ việc phá sản đó;

b) Đã tham gia với tư cách Kiểm sát viên, Quản tài viên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia thủ tục phá sản, người giám định, thẩm định giá, định giá, người phiên dịch trong vụ việc phá sản đó;

c) Cùng trong một Tổ Thẩm phán giải quyết phá sản đó và là người thân thích với nhau;

d) Đã tham gia ra quyết định tuyên bố phá sản đối với vụ việc phá sản đó;

đ) Có căn cứ rõ ràng cho rằng Thẩm phán có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Việc thay đổi Thẩm phán do Chánh án Tòa án nhân dân quyết định. Trường hợp Thẩm phán phụ trách việc phá sản là Chánh án thì việc thay đổi Thẩm phán do Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định. Quyết định thay đổi Thẩm phán của Chánh án là quyết định cuối cùng.

⁸ Điều 18 Luật phá sản

- Đề nghị thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 46 của Luật phá sản 2014.

- Đề nghị Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bổ sung chủ nợ, người mắc nợ vào danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ.

- Đề xuất với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản về việc thu hồi các khoản tiền, tài sản của người mắc nợ.

- Phải có mặt theo yêu cầu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, giấy triệu tập của Tòa án nhân dân và chấp hành các quyết định của Tòa án nhân dân trong quá trình giải quyết phá sản.

- Tham gia vào việc quản lý, thanh lý tài sản theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Đề nghị xem xét lại quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định của Luật phá sản 2014.

- Trường hợp cá nhân tham gia thủ tục phá sản chết thì người thừa kế hợp pháp của họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định trên.

5.2.8. Quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có các quyền, nghĩa vụ sau:

- Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 18 của Luật phá sản 2014.

- Đề xuất với Tòa án nhân dân tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trước khi mở thủ tục phá sản.

- Nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

- Việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải trung thực.

5.2.9. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

- Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 18 của Luật phá sản 2014.

- Được đưa ra ý kiến về việc chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

- Phải thông báo công khai về quyết định mở thủ tục phá sản ngay sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản.

5.2.10. Lệ phí phá sản

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân.⁹ Trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật phá sản 2014 không phải nộp lệ phí phá sản.

5.2.11. Chi phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

Chi phí phá sản là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Chi phí phá sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật phá sản 2014.

Tòa án nhân dân giao cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bán một số tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán để bảo đảm chi phí phá sản. Việc định giá, định giá lại và bán tài sản được thực hiện theo quy định tại các điều 122, 123 và 124 của Luật phá sản 2014.

Tòa án nhân dân quyết định mức tạm ứng chi phí phá sản, mức chi phí phá sản trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật và quyết định việc hoàn trả tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật phá sản 2014.

5.3. ĐƠN VÀ THỦ TỤC ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

5.3.1. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ

Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, chủ nợ quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật phá sản 2014 phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.¹⁰

Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

5.3.2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn

Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, người lao động, đại diện công đoàn quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật phá sản 2014 phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.¹¹

⁹ Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (sau đây gọi là lệ phí phá sản) là khoản tiền mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

¹⁰ Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- a) Ngày, tháng, năm;
- b) Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
- c) Tên, địa chỉ của người làm đơn;
- d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;
- đ) Khoản nợ đến hạn.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.

¹¹ Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- a) Ngày, tháng, năm;

Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Kể từ ngày nộp đơn, người lao động, đại diện công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ theo quy định của Luật phá sản 2014.

5.3.3. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán¹²

Doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Luật phá sản 2014 phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.¹³

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu sau:

a) Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn bộ thời gian hoạt động;

b) Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp, hợp tác xã mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;

c) Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;

đ) Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã;

e) Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Những người theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Luật phá sản 2014 không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp có thiệt hại phát sinh sau thời điểm

b) Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

c) Tên, địa chỉ của người làm đơn;

d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

đ) Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

¹² Điều 28 Luật phá sản 2014

¹³ Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm;

b) Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Tên, địa chỉ của người làm đơn;

đ) Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán do việc không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gây ra thì phải bồi thường.

5.3.4. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã

Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Luật phá sản 2014 phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật phá sản 2014 và gửi kèm các tài liệu (nếu có) theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 28 của Luật phá sản 2014.

5.3.5. Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong các phương thức sau:

- a) Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân;
- b) Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện.

Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

5.3.6. Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

5.3.7. Xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

(i) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau:

a) Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

b) Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 hoặc Điều 29 của Luật phá sản 2014 thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;

c) Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác;

d) Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(ii) Thông báo việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán biết.

5.3.8. Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền và giải quyết đề nghị xem xét lại việc chuyển đơn

Tòa án nhân dân xử lý đơn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 của Luật phá sản 2014 có trách nhiệm chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền và thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chuyển đơn thì người nộp đơn hoặc Tòa án nhân dân được chuyển đơn có quyền đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp xem xét lại việc chuyển đơn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp giải quyết đề nghị xem xét lại việc chuyển đơn. Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng.

5.3.9. Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ nội dung quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 hoặc Điều 29 của Luật phá sản 2014 thì Tòa án nhân dân thông báo cho người nộp đơn biết để sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung do Tòa án nhân dân ấn định, nhưng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp đơn nhận được thông báo; trường hợp đặc biệt, Tòa án nhân dân có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

5.3.10. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp sau:

- a) Người nộp đơn không đúng theo quy định tại Điều 5 của Luật phá sản 2014;
- b) Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 34 của Luật phá sản 2014;
- c) Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;
- d) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật phá sản 2014;
- đ) Người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải nêu rõ lý do trả lại đơn. Tòa án nhân dân có trách nhiệm gửi quyết định này cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

5.3.11. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân, người yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị

xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại, kiến nghị đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu phải ra một trong các quyết định sau:

- a) Giữ nguyên quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
- b) Huỷ quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn theo quy định của Luật phá sản 2014.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kiến nghị đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, người yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu xem xét lại, kiến nghị về việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp phải ra một trong các quyết định sau:

- a) Giữ nguyên quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
- b) Huỷ quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và yêu cầu Tòa án nhân dân thụ lý đơn theo quy định của Luật phá sản 2014.

Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng. Quyết định này phải được gửi cho người yêu cầu, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân đã kiến nghị và Tòa án nhân dân đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu.

5.3.12. Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị bằng văn bản gửi Tòa án nhân dân để các bên thương lượng việc rút đơn. Tòa án nhân dân ấn định thời gian thương lượng nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ.

Trường hợp các bên thỏa thuận được với nhau về việc rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Tòa án nhân dân trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Trường hợp thương lượng không thành hoặc hết thời hạn thương lượng mà các bên không tiến hành thương lượng thì Tòa án nhân dân thông báo cho người nộp đơn nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.

Việc thương lượng của các bên theo quy định tại Điều này không được trái với quy định của pháp luật về phá sản.

5.3.13. Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Tòa án nhân dân dự tính số tiền tạm ứng chi phí phá sản và thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp có đề nghị thương lượng thì việc thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 của Luật phá sản 2014.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải thực hiện việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản như sau:

- a) Nộp lệ phí phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự;
- b) Nộp tạm ứng chi phí phá sản vào tài khoản do Tòa án nhân dân mở tại ngân hàng.

5.3.14. Thủ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thì thời điểm thụ lý được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ.

5.3.15. Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án nhân dân phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, các cơ quan, tổ chức đang giải quyết vụ việc liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán do các bên cung cấp và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì Tòa án nhân dân phải thông báo cho các chủ nợ do doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp.

Trường hợp người nộp đơn không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xuất trình cho Tòa án nhân dân các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật phá sản 2014.

5.3.16. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân thụ lý vụ việc phá sản, việc tạm đình chỉ thực hiện nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện như sau:

- Cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án, trừ bản án, quyết định buộc doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc trả lương cho người lao động. Việc tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

- Tòa án nhân dân, Trọng tài phải tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự. Thủ tục tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật về trọng tài thương mại.

Tòa án nhân dân phải tách và tạm đình chỉ giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự. Thủ tục tách và tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, tố tụng hành chính;

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạm đình chỉ việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với các chủ nợ có bảo đảm.

Trường hợp tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị thì xử lý theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 53 của Luật phá sản 2014.

5.4. MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

5.4.1. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật phá sản 2014.

Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.¹⁴ Tòa án nhân dân ra quyết định không mở thủ tục phá sản nếu xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã không thuộc trường hợp quy định này. Trong trường hợp này, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được trả lại tiền tạm ứng chi phí phá sản; yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản đã bị tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 41 của Luật phá sản 2014 được tiếp tục giải quyết. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

5.4.2. Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính và đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng

¹⁴ Quyết định mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- a) Ngày, tháng, năm;
- b) Tên của Tòa án nhân dân; họ và tên Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản;
- c) Ngày và số thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; tên, địa chỉ của người làm đơn yêu cầu;
- d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;
- đ) Thời gian, địa điểm khai báo của các chủ nợ và hậu quả pháp lý của việc không khai báo.

thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và 02 số báo địa phương liên tiếp nơi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có trụ sở chính.

Quyết định không mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Thời hạn gửi và thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản là 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định.

5.4.3. Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Tòa án nhân dân đã ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản gửi hồ sơ vụ việc phá sản cho Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp giải quyết.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc phá sản kèm theo đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán xem xét, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị và gửi hồ sơ vụ việc phá sản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc phá sản do Tòa án nhân dân chuyển đến, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phải trả lại hồ sơ cho Tòa án nhân dân.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc phá sản do Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trả lại, Tổ Thẩm phán phải tổ chức phiên họp để xem xét, giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị. Phiên họp của Tổ Thẩm phán có Viện kiểm sát nhân dân tham gia và có Thư ký Tòa án nhân dân ghi biên bản phiên họp. Trong trường hợp cần thiết có thể triệu tập người khác để hỏi thêm về những vấn đề chưa rõ. Tổ Thẩm phán có quyền ra một trong các quyết định sau:

- a) Giữ nguyên quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản;
- b) Hủy quyết định không mở thủ tục phá sản và giao cho Tòa án nhân dân đã ra quyết định không mở thủ tục phá sản xem xét ra quyết định mở thủ tục phá sản;
- c) Hủy quyết định mở thủ tục phá sản và thông báo cho Tòa án nhân dân đã ra quyết định mở thủ tục phá sản và những người tham gia thủ tục phá sản.

Quyết định của Tổ Thẩm phán là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.

5.4.4. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Trường hợp xét thấy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều hành, doanh nghiệp, hợp tác xã có dấu hiệu vi phạm khoản 1 Điều 48 của Luật phá sản 2014 thì Thẩm phán ra quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đó theo đề nghị của Hội nghị chủ nợ hoặc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

5.4.5. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau:

- a) Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;
- b) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật phá sản 2014;
- c) Từ bỏ quyền đòi nợ;
- d) Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Giao dịch quy định trên là vô hiệu và xử lý theo quy định tại Điều 60 của Luật phá sản 2014.

5.4.6. Giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

(i) Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã phải báo cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trước khi thực hiện các hoạt động sau:

- a) Hoạt động liên quan đến việc vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản; bán, chuyển đổi cổ phần; chuyển quyền sở hữu tài sản;
- b) Chấm dứt thực hiện hợp đồng có hiệu lực;
- c) Thanh toán khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản; trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã.

(ii) Hình thức báo cáo gồm báo cáo trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, thư điện tử, fax, telex.

(iii) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp, hợp tác xã thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm trả lời cho doanh nghiệp, hợp tác xã việc được thực hiện hoặc không được thực hiện các hoạt động quy định tại khoản (i) này và phải chịu trách nhiệm về việc trả lời của mình. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải báo cáo Thẩm phán về nội dung trả lời của mình.

(iv) Các hoạt động quy định tại khoản (i) này được thực hiện mà không có sự đồng ý của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì bị đình chỉ thực hiện, khôi phục lại tình trạng ban đầu và giải quyết hậu quả theo quy định của pháp luật.

5.5. NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN

5.5.1. Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản

Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập trước khi Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản được xác định vào thời điểm ra quyết định mở thủ tục phá sản.

Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập sau khi Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản được xác định vào thời điểm ra quyết định tuyên bố phá sản.

Trường hợp nghĩa vụ về tài sản quy định trên không phải là tiền thì Tòa án nhân dân xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản đó bằng tiền.

5.5.2. Xác định tiền lãi đối với khoản nợ

Kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, các khoản nợ được tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận nhưng được tạm dừng việc trả lãi. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 86 của Luật phá sản 2014, đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 của Luật phá sản 2014 thì việc tạm dừng trả lãi chấm dứt, các bên tiếp tục thực hiện việc trả lãi theo thỏa thuận.

Đối với khoản nợ mới phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản đến thời điểm tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì tiền lãi của khoản nợ đó được xác định theo thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì khoản nợ không được tiếp tục tính lãi.

5.5.3. Thứ tự phân chia tài sản

(i) Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

(ii) Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản (i) này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

- a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;
- b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;
- c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;
- đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

(iii) Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản (i) này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

5.5.4. Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh

Trường hợp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ liên đới về một khoản nợ mà một hoặc tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã đó mất khả năng thanh toán thì chủ nợ có quyền đòi bất cứ doanh nghiệp, hợp tác xã nào trong số các doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện việc trả nợ cho mình theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người bảo lãnh mất khả năng thanh toán thì việc bảo lãnh được giải quyết như sau:

- a) Nếu nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Trường hợp bên bảo lãnh không thanh toán đầy đủ trong phạm vi bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thanh toán phần còn thiếu;
- b) Nếu nghĩa vụ bảo lãnh chưa phát sinh thì bên được bảo lãnh phải thay thế biện pháp bảo đảm khác, trừ trường hợp người được bảo lãnh và người nhận bảo lãnh có thỏa thuận khác.

Trường hợp người được bảo lãnh hoặc cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều mất khả năng thanh toán thì người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm thay cho người được bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

5.5.5. Trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố phá sản, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn để dùng vào hoạt động kinh doanh phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với cơ quan thi hành án dân sự để nhận lại tài sản của mình.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì người cho thuê chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán số tiền thuê tương ứng với thời gian thuê còn lại để cơ quan thi hành án dân sự nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã chuyển nhượng tài sản thuê hoặc mượn cho người khác mà không đòi lại được thì người cho thuê hoặc cho mượn có quyền yêu cầu bồi thường đối với tài sản đó như khoản nợ không có bảo đảm.

5.5.6. Trả lại tài sản nhận bảo đảm

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán chỉ trả lại tài sản nhận bảo đảm cho cá nhân, tổ chức đã giao tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trước khi Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản trong trường hợp cá nhân, tổ chức đó đã thực hiện nghĩa vụ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

5.5.7. Nhận lại hàng hoá đã bán

Người bán đã gửi hàng hóa cho người mua là doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nhưng chưa được thanh toán và người mua cũng chưa nhận được hàng hóa thì người bán được nhận lại hàng hoá đó. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán đã nhận hàng hóa đó và không thể trả lại được thì người bán trở thành chủ nợ không có bảo đảm.

5.6. CÁC BIỆN PHÁP BẢO TOÀN TÀI SẢN

5.6.1. Giao dịch bị coi là vô hiệu

(i) Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;
- b) Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
- c) Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn;
- d) Tặng cho tài sản;
- đ) Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
- e) Giao dịch khác với mục đích tâu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

(ii) Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán quy định tại khoản (i) này được thực hiện với những người liên quan trong thời gian 18 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản thì bị coi là vô hiệu.¹⁵

¹⁵ Những người liên quan bao gồm:

- a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đối với công ty con;
- b) Công ty con đối với công ty mẹ; doanh nghiệp do hợp tác xã thành lập đối với hợp tác xã;
- c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định của cơ quan quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;
- d) Người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với doanh nghiệp, hợp tác xã;
- đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- e) Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho những người quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm xem xét giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, nếu phát hiện giao dịch quy định tại khoản (i) và (ii) này thì đề nghị Tòa án nhân dân xem xét tuyên bố giao dịch vô hiệu.¹⁶

5.6.2. Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu xét thấy việc thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện sẽ có khả năng gây bất lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp xử lý các khoản nợ có bảo đảm theo quy định tại Điều 53 của Luật phá sản 2014.¹⁷

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, nếu chấp nhận thì Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng; nếu không chấp nhận thì thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu biết.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân phải xem xét các hợp đồng bị tạm đình chỉ để ra một trong các quyết định sau:

a) Tiếp tục thực hiện hợp đồng nếu việc thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc nếu được thực hiện sẽ không gây bất lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Đình chỉ thực hiện hợp đồng và giải quyết hậu quả theo quy định tại Điều 62 của Luật phá sản 2014.

Trường hợp Tòa án nhân dân quyết định không mở thủ tục phá sản thì Tòa án nhân dân đã quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định trên quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ.

5.6.3. Thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện

Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện, nếu tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nhận được từ hợp đồng vẫn còn tồn tại trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã thì bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền đòi lại tài sản và thanh toán số tiền đã nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã; nếu tài sản đó không còn thì bên giao kết có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm đối với phần chưa được thanh toán.

Trường hợp việc đình chỉ thực hiện hợp đồng gây thiệt hại cho bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã thì bên giao kết có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm đối với khoản thiệt hại.

g) Doanh nghiệp trong đó những người quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;

h) Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thu góp phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.

¹⁶ Xem thêm Điều 60 Luật phá sản 2014.

¹⁷ Văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này phải có nội dung chủ yếu sau: a) Ngày, tháng, năm; b) Tên, địa chỉ của người có yêu cầu; c) Số, tên hợp đồng; ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng; d) Bên giao kết với doanh nghiệp, hợp tác xã trong hợp đồng; đ) Nội dung cụ thể của hợp đồng; e) Căn cứ của việc yêu cầu tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng.

5.6.4. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

(i) Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán gồm:

- a) Tài sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời điểm Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản;
- b) Tài sản và quyền tài sản có được sau ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản;
- c) Giá trị của tài sản bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải thanh toán cho chủ nợ có bảo đảm;
- d) Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai;
- đ) Tài sản thu hồi từ hành vi cất giấu, tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
- e) Tài sản và quyền tài sản có được do thu hồi từ giao dịch vô hiệu;
- g) Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

(ii) Tài sản của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh mất khả năng thanh toán gồm:

- a) Tài sản quy định tại khoản (i) này;
- b) Tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh; trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh có tài sản thuộc sở hữu chung thì phần tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đó được chia theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì việc xử lý tài sản không chia được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

5.6.5. Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải tiến hành kiểm kê tài sản và xác định giá trị tài sản đó; trong trường hợp cần thiết thì phải có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. Việc xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã vắng mặt thì người được Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản chỉ định làm đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện công việc kiểm kê và xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bảng kiểm kê tài sản đã được xác định giá trị phải gửi ngay cho Tòa án nhân dân tiến hành thủ tục phá sản.

Trường hợp xét thấy việc kiểm kê, xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định trên là không chính xác thì Tòa án nhân dân yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức kiểm kê, xác định lại giá trị một phần hoặc toàn bộ tài sản

của doanh nghiệp, hợp tác xã. Giá trị tài sản được xác định, định giá theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê.

Trường hợp đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và những người khác không hợp tác về việc kiểm kê tài sản hoặc cố tình làm sai lệch việc kiểm kê tài sản thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

5.6.6. Gửi giấy đòi nợ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.¹⁸ Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn quy định trên.

Việc lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện.¹⁹

5.6.7. Đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán cho người khác vay tài sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký giao dịch bảo đảm nhưng chưa đăng ký thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện ngay việc đăng ký; trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm.

5.6.8. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn theo quy định tại Điều 5 của Luật phá sản 2014, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động sau đây:

a) Cho bán hàng hoá dễ bị hư hỏng, hàng hoá sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hoá không bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ; cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác;

b) Kê biên, niêm phong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã tại ngân hàng; phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ;

¹⁸ Giấy đòi nợ phải có các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ;

b) Tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

¹⁹ Xem các Điều 67-68 Luật phá sản 2014.

d) Niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên quan của doanh nghiệp, hợp tác xã;

đ) Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

e) Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

g) Cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện một số hành vi nhất định;

h) Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

i) Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của pháp luật.

Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải có văn bản yêu cầu gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền.²⁰

Thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, giải quyết đề nghị xem xét lại việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và thi hành quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời thực hiện theo quy định của Luật phá sản 2014, pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật về thi hành án dân sự.

5.7. HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

5.7.1. Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ

Thời hạn Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ, trừ trường hợp không phải tổ chức Hội nghị chủ nợ theo quy định tại Điều 105 của Luật phá sản 2014.

Thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ và tài liệu khác có liên quan phải được gửi cho người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 77 và Điều 78 của Luật phá sản 2014, chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc Hội nghị. Giấy triệu tập Hội nghị chủ nợ phải ghi rõ thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị chủ nợ, chương trình, nội dung Hội nghị chủ nợ.

Thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ, tài liệu gửi bằng phương thức giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, fax, telex, thư điện tử hoặc bằng phương thức khác có ghi nhận việc gửi này.

²⁰ Văn bản yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm;

b) Tên, địa chỉ của người có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

c) Tên, địa chỉ của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

d) Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

đ) Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

Tùy theo yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu phải cung cấp cho Tòa án nhân dân chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

5.7.2. Nguyên tắc tiến hành Hội nghị chủ nợ

- Tôn trọng thoả thuận của người tham gia thủ tục phá sản nếu thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.
- Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản.
- Công khai trong việc tiến hành Hội nghị chủ nợ.

5.7.3. Quyền tham gia Hội nghị chủ nợ

Những người sau đây có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ:

- Chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. Chủ nợ có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;
- Đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động uỷ quyền; trường hợp này đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;
- Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; trường hợp này người bảo lãnh trở thành chủ nợ không có bảo đảm.

5.7.4. Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 5 của Luật phá sản 2014, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ; trường hợp không tham gia được thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như người uỷ quyền.

Trường hợp người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán cố ý vắng mặt không có lý do chính đáng thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân xử lý theo quy định của pháp luật.

5.7.5. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ²¹

- Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến về những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 83 của Luật phá sản 2014 thì được coi như chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ.
- Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ.

5.7.6. Hoãn Hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ được hoãn nếu không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 79 của Luật phá sản 2014; trường hợp hoãn Hội nghị chủ nợ thì Thẩm phán lập biên bản và ghi ý kiến của người tham gia Hội nghị chủ nợ. Thẩm phán phải thông báo ngay trong ngày hoãn Hội nghị chủ nợ cho người tham gia thủ tục phá sản về việc hoãn Hội nghị chủ nợ.

²¹ Điều 79 Luật phá sản 2014.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoãn Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ. Trường hợp triệu tập lại Hội nghị chủ nợ mà vẫn không đáp ứng quy định tại Điều 79 của Luật phá sản 2014 thì Thẩm phán lập biên bản và quyết định tuyên bố phá sản.

5.7.7. Nội dung và trình tự Hội nghị chủ nợ

(i) Hội nghị chủ nợ được tiến hành như sau:

a) Thẩm phán được phân công phụ trách khai mạc Hội nghị chủ nợ;

b) Hội nghị chủ nợ biểu quyết thông qua việc cử Thư ký Hội nghị chủ nợ theo đề xuất của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để ghi biên bản Hội nghị chủ nợ;

c) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của người tham gia Hội nghị chủ nợ theo thông báo triệu tập của Tòa án nhân dân, lý do vắng mặt và kiểm tra căn cước của người tham gia Hội nghị chủ nợ;

d) Thẩm phán thông báo với Hội nghị chủ nợ về những người tham gia Hội nghị chủ nợ và nội dung việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

đ) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thông báo cho Hội nghị chủ nợ về tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; kết quả kiểm kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết;

e) Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày ý kiến về nội dung do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đã thông báo cho Hội nghị, đề xuất phương án, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, khả năng và thời hạn thanh toán nợ;

g) Chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ trình bày về những vấn đề cụ thể yêu cầu giải quyết, lý do, mục đích và căn cứ của việc yêu cầu giải quyết phá sản;

h) Người có liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ trong việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản;

i) Người làm chứng trình bày ý kiến; người giám định, đại diện cơ quan thẩm định giá trình bày kết luận giám định, kết quả định giá; người thực hiện biện pháp bảo trợ tư pháp khác giải thích những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn;

k) Trường hợp có người vắng mặt thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho công bố ý kiến bằng văn bản, tài liệu, chứng cứ do người đó cung cấp;

l) Hội nghị chủ nợ thảo luận về các nội dung do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đã thông báo và ý kiến của những người tham gia Hội nghị chủ nợ;

m) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, người tham gia Hội nghị chủ nợ có quyền đề nghị Thẩm phán ra quyết định thay người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

n) Các chủ nợ có quyền thành lập Ban đại diện chủ nợ.²²

(ii) Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được thông qua khi có quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả các chủ nợ.²³

(iii) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, Tòa án nhân dân gửi Nghị quyết Hội nghị chủ nợ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 77 và Điều 78 của Luật phá sản 2014.

(iv) Trường hợp không đồng ý với Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 77 và Điều 78 của Luật phá sản 2014 có quyền gửi đơn đề nghị, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân đang giải quyết phá sản xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ.²⁴ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, kiến nghị, Chánh án Tòa án nhân dân đang giải quyết phá sản xem xét và ra một trong các quyết định sau:

- a) Không chấp nhận đề nghị, kiến nghị;
- b) Tổ chức lại Hội nghị chủ nợ.

Quyết định giải quyết này là quyết định cuối cùng.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 77, Điều 78 của Luật phá sản 2014.

5.7.8. Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản

(i) Kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản đến trước ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không mất khả năng thanh toán thì Tòa án nhân dân ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hoàn trả tạm ứng chi phí phá sản cho người nộp đơn, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật phá sản 2014.

(ii) Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản phải được gửi cho những người được thông báo quyết định mở thủ tục phá sản quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật phá sản 2014 trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại,

²² Xem thêm Điều 82 Luật phá sản 2014.

²³ Xem thêm Điều 83 Luật phá sản 2014.

²⁴ Văn bản đề nghị, kiến nghị có các nội dung chủ yếu sau:

- a) Ngày, tháng, năm;
- b) Tên, địa chỉ của người đề nghị, Viện kiểm sát kiến nghị;
- c) Nội dung đề nghị, kiến nghị.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân đang giải quyết thủ tục phá sản về quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

(iii) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xem xét lại, kiến nghị quy định tại khoản (ii) này, Chánh án Tòa án nhân dân đang giải quyết thủ tục phá sản phải xem xét, giải quyết kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản và ra một trong các quyết định sau:

- a) Giữ nguyên quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản;
- b) Hủy quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản và giao cho Thẩm phán tiến hành giải quyết phá sản.

(iv) Quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản phải gửi cho những người được thông báo quyết định mở thủ tục phá sản quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật phá sản 2014 trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

5.8. THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

5.8.1. Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

(i) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho ý kiến.

(ii) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã thì chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi ý kiến cho doanh nghiệp, hợp tác xã để hoàn thiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh báo cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chủ nợ, Ban đại diện chủ nợ (nếu có).

(iii) Ngay sau khi nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản (ii) này, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có nhiệm vụ báo cáo Thẩm phán.

(iv) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Thẩm phán xem xét trước khi đưa phương án ra Hội nghị chủ nợ xem xét thông qua.

3.8.2. Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải nêu rõ các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ.

Các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh gồm:

- a) Huy động vốn;
- b) Giảm nợ, miễn nợ, hoãn nợ;

- c) Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;
- d) Đổi mới công nghệ sản xuất;
- đ) Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất;
- e) Bán cổ phần cho chủ nợ và những người khác;
- g) Bán hoặc cho thuê tài sản;
- h) Các biện pháp khác không trái quy định của pháp luật.

3.8.3. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Thời hạn để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác định được thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

5.8.3. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã

- Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% số nợ không có bảo đảm. Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến cụ thể về việc thông qua hoặc không thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã thì coi như chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ.

- Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ.

5.8.4. Nội dung và trình tự Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

(i) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định đưa phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán ra Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

(ii) Hội nghị chủ nợ được tiến hành như sau:

- a) Thẩm phán được phân công phụ trách khai mạc Hội nghị chủ nợ;
- b) Hội nghị chủ nợ biểu quyết thông qua việc cử Thư ký Hội nghị chủ nợ theo đề xuất của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để ghi biên bản Hội nghị chủ nợ;
- c) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của người tham gia Hội nghị chủ nợ theo thông báo triệu tập của Tòa án nhân dân, lý do vắng mặt và kiểm tra căn cước của người tham gia Hội nghị chủ nợ;

d) Thẩm phán thông báo với Hội nghị chủ nợ về những người tham gia Hội nghị chủ nợ;

đ) Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

e) Người tham gia Hội nghị chủ nợ trình bày ý kiến của mình về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

g) Hội nghị chủ nợ thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

(iii) Hội nghị chủ nợ được hoãn một lần trong trường hợp không đáp ứng điều kiện hợp lệ. Việc tổ chức lại Hội nghị chủ nợ được thực hiện theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 của Luật phá sản 2014.

(iv) Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.

Trường hợp phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có sử dụng tài sản bảo đảm thì phải quy định rõ thời gian sử dụng tài sản có bảo đảm, phương án xử lý tài sản bảo đảm và phải được chủ nợ có bảo đảm bằng tài sản đó đồng ý.

(v) Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả các chủ nợ.

(vi) Trường hợp không tổ chức lại được Hội nghị chủ nợ hoặc Hội nghị chủ nợ không thông qua được Nghị quyết theo khoản (v) này thì Tòa án nhân dân tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

5.8.5. Công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã

Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Nghị quyết này có hiệu lực đối với tất cả người tham gia thủ tục phá sản có liên quan. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thì những điều cấm, chịu sự giám sát đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Điều 48 và Điều 49 của Luật phá sản 2014 chấm dứt.

Tòa án nhân dân gửi quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

5.8.6. Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chủ nợ giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Sáu tháng một lần, doanh nghiệp, hợp tác xã phải lập báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo Thẩm phán và thông báo cho chủ nợ.

5.8.7. Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Trong quá trình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, các chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được chấp nhận khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả thuận về sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Quyết định công nhận sự thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và chủ nợ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

5.8.8. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh²⁵

(i) Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;
- b) Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;
- c) Hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả năng thanh toán.

(ii) Tòa án nhân dân thông báo công khai quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật phá sản 2014.

5.8.9. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

Trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 của Luật phá sản 2014 thì doanh nghiệp, hợp tác xã được coi là không còn mất khả năng thanh toán. Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

²⁵ Điều 95 Luật phá sản 2014.

Trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 95 của Luật phá sản 2014, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

5.9. TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

5.9.1. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn

(i) Tòa án nhân dân giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn đối với các trường hợp sau:

a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật phá sản 2014 mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

b) Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản.

(ii) Trường hợp Tòa án nhân dân xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp quy định tại khoản (i) này, Tòa án nhân dân thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản biết về việc Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

(iii) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân thông báo theo quy định tại khoản (ii) này, Tòa án nhân dân xem xét, tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản đối với những trường hợp quy định tại khoản (i) này hoặc tiếp tục giải quyết theo thủ tục thông thường và thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản biết.

(iv) Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo quy định tại điểm b khoản (i) này thì người nộp đơn không được hoàn lại lệ phí phá sản, tiền tạm ứng chi phí phá sản đã nộp.

5.9.2. Quyết định tuyên bố phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả họp Hội nghị chủ nợ, Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 80, khoản 4 Điều 83 và khoản 6 Điều 91 của Luật phá sản 2014.

5.9.3. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết của Hội nghị chủ nợ đề nghị tuyên bố phá sản theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 83 của Luật phá sản 2014 thì Tòa án nhân dân xem xét quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Sau khi Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã không xây dựng được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật phá sản 2014;

b) Hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

5.9.4. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- a) Ngày, tháng, năm;
- b) Tên của Tòa án nhân dân; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;
- c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;
- d) Căn cứ của việc tuyên bố phá sản;
- đ) Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; đình chỉ giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã; chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; giải quyết hậu quả của giao dịch bị đình chỉ; tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu; chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, giải quyết quyền lợi của người lao động;
- e) Chấm dứt quyền hạn của đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã;
- g) Thanh lý tài sản và bán đấu giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã;
- h) Phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 54 của Luật phá sản 2014;
- i) Chuyển yêu cầu giải quyết tranh chấp cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền;
- k) Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 130 của Luật phá sản 2014;
- l) Giải quyết vấn đề khác theo quy định pháp luật.

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

5.9.5. Gửi và thông báo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân phải thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật phá sản 2014; đồng thời gửi trích lục tuyên bố phá sản trong trường hợp quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có nội dung cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã cho Sở Tư pháp nơi Tòa án nhân dân có trụ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân phải gửi quyết định cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; trong trường hợp Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị theo quy định tại Điều 113 của Luật phá sản 2014 thì thời hạn có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định.

5.9.6. Nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản quy định tại các điều 105, 106 và 107 của Luật phá sản 2014 không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.9.7. Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Những người được thông báo quy định tại khoản 1 Điều 109 của Luật phá sản 2014 có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Tòa án nhân dân đã ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải gửi hồ sơ vụ việc phá sản kèm theo đơn đề nghị, kháng nghị cho Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp để xem xét, giải quyết.

5.9.8. Giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định một tổ gồm 03 Thẩm phán xem xét, giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và gửi hồ sơ vụ việc phá sản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc phá sản do Tòa án nhân dân chuyển đến, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phải trả lại hồ sơ cho Tòa án nhân dân.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc phá sản kèm theo đơn đề nghị, kháng nghị, Tổ Thẩm phán phải tổ chức phiên họp và ra một trong các quyết định sau:

- a) Không chấp nhận đơn đề nghị, kháng nghị và giữ nguyên quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;
- b) Sửa quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;
- c) Huỷ quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân cấp dưới có thẩm quyền giải quyết lại.

Phiên họp của Tổ Thẩm phán có Viện kiểm sát nhân dân tham gia và có Thư ký Tòa án nhân dân ghi biên bản phiên họp; trường hợp cần thiết, Tòa án nhân dân triệu tập người đề nghị, người khác có liên quan tham gia phiên họp để trình bày ý kiến.

Quyết định giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị của Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

5.9.9. Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản

Người giữ chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản không được đảm đương các chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào kể từ ngày doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản.

Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp có vốn nhà nước mà doanh nghiệp đó bị tuyên bố phá sản không được đảm đương các chức vụ quản lý ở bất kỳ doanh nghiệp nào có vốn của Nhà nước.

Người giữ chức vụ quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản mà có ý vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 18, khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 48 của Luật phá sản 2014 thì Thẩm phán xem xét, quyết định về việc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án nhân dân có quyết định tuyên bố phá sản.

Quy định trên không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản với lý do bất khả kháng.